

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Legislazione Bancaria 2

Dispensa del corso

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Contenuto:

12 capitoli · 91 slide di riferimento

Anno Accademico:

2026/2027

Appunti rielaborati dal materiale didattico ufficiale del corso. Documento a uso personale di studio.

Indice

1	L'evoluzione e l'importanza degli Accordi di Basilea	1
2	La Vigilanza Informativa	5
3	La vigilanza regolamentare: adeguatezza patrimoniale e contenimento dei rischi (Art. 53 TUB)	14
4	Vigilanza Regolamentare: le Partecipazioni Detenibili dalle Banche (Art. 53 TUB)	24
5	Vigilanza Regolamentare e Governo Societario (Art. 53 TUB)	32
6	Vigilanza regolamentare: i poteri di intervento della Banca d'Italia (art. 53-bis TUB)	49
7	La Vigilanza Ispettiva	53
8	La disciplina sanzionatoria bancaria	64
9	Altre forme di vigilanza: modificazioni statutarie, fusioni e scissioni, cessione di rapporti giuridici, tutela della concorrenza	68
10	La vigilanza su base consolidata e i gruppi bancari	76
11	La disciplina della crisi bancaria	79
12	Decreto Legislativo 180/2015 — La risoluzione delle banche	91

1 | L'evoluzione e l'importanza degli Accordi di Basilea

Fonte: LEGB2_Appunti_01_Accordi-di-Basilea.pdf — 5 pagine

1.1. Premessa: rapporto con la prima parte del corso

Quanto definito nella seconda parte del corso non esclude, ma integra i concetti visti nella prima parte, come ad esempio la vigilanza del paese d'origine (*home country control*)¹ o il principio per cui le norme di vigilanza servono a perseguire le finalità descritte ai sensi dell'art. 5 TUB, in particolare la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e la concorrenzialità all'interno del sistema. (pagina 3)

1.2. Nota lessicale: controllo, vigilanza, supervisione

Normalmente vengono trattati come sinonimi i termini **controllo**, **vigilanza** e **supervisione**, ma non sono esattamente la stessa cosa.

- Il legislatore italiano non usa mai il termine *supervisione*: solo negli ultimi anni è stato ripreso dalla giurisprudenza come traduzione del termine inglese “*supervision*”.
- Non bisogna confondere **controllo** e **vigilanza**. Il concetto di controllo deriva dal diritto amministrativo² e fa riferimento alle verifiche e ai riscontri realizzati *ex-post* sulle banche (ad esempio i controlli sui requisiti patrimoniali minimi).
- Il termine **vigilanza** si riferisce a qualcosa di più ampio, che comprende anche la nozione di controllo ma non si esaurisce con esso: nel caso della vigilanza regolamentare, ad esempio, le regole prima si applicano e dopo si controlla che vengano rispettate. La vigilanza prevede infatti che vengano scritte le norme, verificate e, laddove necessario, che vengano adottate misure di carattere correttivo (si agisce quindi sia *ex-ante* che *ex-post*).

(pagina 3)

1.3. Dalla vigilanza strutturale alla vigilanza regolamentare

Come già visto, la precedente legge bancaria era molto elastica e concedeva a Banca d'Italia la possibilità di incidere sulla struttura del mercato: si parlava infatti di **vigilanza strutturale**.

¹fatti salvi i casi di *host country control* già citati.

²non è il controllo definito ai sensi degli artt. 23 TUB e 2359 c.c.

Con l'entrata in vigore del TUB si è passati a una forma di **vigilanza regolamentare**, caratterizzata da parametri oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione e dalla valorizzazione dell'autonomia imprenditoriale, fatte salve regole minime comuni.

Vale la pena sottolineare come anche questo modello di vigilanza rischi di andare sempre più in crisi, poiché le finalità sembrano inadatte rispetto all'evoluzione della disciplina.

Il passaggio da una forma di vigilanza all'altra non è dipeso soltanto dai fenomeni sovranazionali visti nella prima parte del corso, ma anche dall'evoluzione degli accordi di Basilea, illustrata nelle sezioni seguenti. (pagina 3)

1.4. Le origini: il Comitato di Basilea e i concordati del 1975 e del 1983

1974 — I governatori delle banche centrali degli otto paesi finanziariamente più evoluti, insieme ai governatori delle banche centrali di Svizzera e Lussemburgo, si riunirono in un apposito comitato (il Comitato di Basilea).

1975 — Venne varato un primo concordato, un primo tentativo di regolare la vigilanza sui gruppi bancari e finanziari internazionali. Nonostante avesse portato a una minima armonizzazione delle prassi di vigilanza fra i paesi partecipanti, il suo limite principale era l'**assenza di vincolatività** delle parti: si trattava più di un *gentleman's agreement*, privo quindi di vincoli giuridici, soprattutto perché i governatori non erano (e non sono) dotati di poteri legislativi.

1983 — Venne elaborato un secondo concordato, nel quale si introdussero i concetti che avrebbero poi preso il nome di **Home country control** e **Host country control** (ripresi in seguito dalla II Direttiva UE), oltre ad alcune regole tipiche del “bravo banchiere” (ad esempio in termini di patrimonio detenuto dalla banca). Anche in questo caso il limite era l'assenza di vincolatività delle parti; tuttavia, essendosi allargato il numero dei partecipanti, si iniziò a pensare che, almeno a livello europeo, queste regole potessero diventare vincolanti tramite l'adozione di regolamenti e direttive. (pagina 3-4)

1.5. Basilea I (1988)

Nel **1988** si ebbe il primo vero accordo di Basilea, passato alla storia come **Basilea I**, nel quale si concordava una convergenza a livello internazionale in merito alla misurazione del capitale e ai coefficienti patrimoniali minimi per una banca.

Questo primo accordo pone le basi per lo sviluppo della vigilanza regolamentare, perché si inizia a dare maggiore attenzione a parametri tecnici piuttosto che a regole discrezionali.

(pagina 4)

1.6. Basilea II (2001–2004) e i tre pilastri

Nel **2001** si iniziò a lavorare a un secondo accordo, varato nel **2004**, che prese il nome di **Basilea II** (in altri testi si fa riferimento al 2007 o ad altri anni ancora, perché per alcune discipline era stato consentito un tempo maggiore per potersi adattare).

Basilea II rappresenta un punto di svolta poiché contiene una serie di principi validi tuttora; in particolare, questo nuovo accordo si articolava su **tre pilastri fondamentali**:

1. **requisiti patrimoniali minimi**;
2. **regole di controllo prudenziale**, volte alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati;
3. introduzione di una **disciplina relativa alla trasparenza del mercato** (in particolare trasparenza nei confronti del mercato, quindi verso investitori sia al dettaglio che qualificati).

La **direttiva 48/2006/UE** è figlia proprio di Basilea II. In Italia è stata data attuazione agli accordi di Basilea II tramite l'emanazione, da parte di Banca d'Italia, della **circolare 263**, attualmente quasi completamente abrogata. (pagina 4)

1.7. La crisi del 2008 e i limiti della normativa previgente

Le autorità europee erano convinte di aver varato una legislazione solida, ma la crisi del 2008 ha costretto a rimettere tutto in discussione. In particolare:

- non erano stati regolamentati adeguatamente i **derivati**;
- ci si era resi conto che la legislazione emanata fino a quel momento fosse **prociclica**, ovvero tendeva ad accelerare le crisi e quindi a peggiorare la situazione dell'intero sistema. Un esempio lampante: si stabiliva che le banche dovessero erogare credito soltanto ai soggetti ritenuti sani; concetto facilmente applicabile in una situazione di crescita dell'economia, ma in caso di crisi sistemica non ci sono soggetti sani.

Uno dei motivi per cui si riteneva che la precedente normativa fosse inadatta era che tutte le previsioni riguardavano la banca in una prospettiva solo **microeconomica**, senza considerare la sua capacità di resistere a una crisi di sistema. (pagina 4)

1.8. Basilea III (2011/2013)

Basilea III, entrata in vigore in parte nel **2011** (per la disciplina relativa alla liquidità) e in parte nel **2013** (per altri aspetti), introduce strumenti tecnici di tipo **macro-prudenziale** (come lo *stress test*) e migliora quelli già esistenti di tipo **micro-prudenziale**.

In più, fino a Basilea II la vigilanza era basata principalmente su strumenti di analisi di tipo **quantitativo**; con Basilea III si inizia a dare maggiore importanza anche ad aspetti di natura **qualitativa**, come ad esempio la **governance** (tema successivamente ripreso anche dalla CRD4), e viene ripresa la disciplina sulla trasparenza.

I meccanismi unici europei sono, in un certo senso, figli di Basilea III.

(pagina 4–5)

1.9. Basilea IV

In ultimo abbiamo **Basilea IV**: questo accordo, che per alcuni aspetti è già stato implementato tramite regolamenti e direttive UE del 2019, sarebbe dovuto entrare in vigore già a partire dal primo gennaio 2022, ma è stato aumentato il periodo di implementazione a causa del covid.

In questo accordo si è deciso di optare per:

- una **semplificazione della metodologia di calcolo dei requisiti patrimoniali**;
- l'introduzione di **metodologie relative alla comparabilità fra le banche**.

(pagina 5)

2 | La Vigilanza Informativa

Fonte: LEGB2_Appunti_02_Vigilanza-Informativa.pdf — 9 pagine

2.1. Introduzione: le tre forme di vigilanza nel TUB

Prima di trattare la vigilanza informativa è necessaria una precisazione lessicale: all'interno del TUB, salvo qualche norma, non compare mai l'aggettivo **prudenziale** in riferimento alla vigilanza (il titolo III è rubricato semplicemente *vigilanza*). Inizialmente era stata elaborata una bozza di TUB in cui compariva l'aggettivo *prudenziale*, ma a seguito di un convegno a Bari, dedicato alla discussione della prima formulazione del TUB, il termine venne eliminato per due motivazioni:

1. il termine *prudenziale* in italiano non esprime lo stesso concetto del termine “*prudential*” presente nella versione inglese della II direttiva;
2. non avrebbe senso parlare di vigilanza ex-post: di per sé la vigilanza o è già prudenziale, oppure non è proprio un'attività di vigilanza (non si può svolgere attività di vigilanza per garantire la sana e prudente gestione di un istituto già in crisi; bisogna vigilare ex-ante sulle banche e sul sistema bancario).

Il TUB affronta la vigilanza sotto **tre profili**:

- **art. 51** — vigilanza **informativa**: BCE e Banca d'Italia (BI) hanno diritto di chiedere e ottenere informazioni dalle banche;
- **art. 53** — vigilanza **regolamentare**: viene data alle autorità la possibilità di regolamentare alcuni ambiti;
- **art. 54** — vigilanza **ispettiva**: le autorità possono recarsi presso i soggetti vigilati per verificarne i comportamenti e ottenere ulteriori dati e informazioni.

Queste modalità di vigilanza avrebbero potuto essere ordinate diversamente: prima regolamentare, poi informativa e infine ispettiva. Le norme sulla vigilanza sono replicate e applicate sia ai gruppi bancari sia agli intermediari del titolo V; se ne parla anche nel TUF e nel CAP (Codice delle Assicurazioni Private).

Nell'ambito della vigilanza non si ha più a che fare con le **autorità creditizie** (CICR o MEF) ma con le **autorità di vigilanza** (BI e BCE).

(pagina 1)

2.2. Art. 51 TUB: la vigilanza informativa

L'articolo 51 TUB è stato modificato molte volte nel corso del tempo; i commi 1-bis e successivi sono stati aggiunti in attuazione della CRD4. Le banche sono tenute al rispetto di una **duplice disciplina di trasparenza**:

- quella **bancaria** (rapporto banca–cliente);
- quella relativa alla **vigilanza informativa** (rapporto banca–BI).

Nell'ambito della vigilanza informativa esistono diverse motivazioni che spingono una banca a segnalare correttamente i propri dati:

- evitare sanzioni particolarmente pesanti da parte di BI e/o BCE (si può arrivare anche a centinaia di migliaia di euro);
- non rischiare di essere processati per il reato di **ostacolo alle funzioni di vigilanza** (art. 2638 c.c.);
- interessi personali: vista la possibilità di ricevere un flusso di ritorno di informazioni, è la banca stessa ad avere interesse nel fornire segnalazioni veritiere.

Comma 1: *“Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.”*

Con vigilanza informativa si fa riferimento al potere attribuito a BI di esigere dalle banche tutte le informazioni che ritiene necessarie. L'unico documento a cui si fa esplicito riferimento nel comma 1 è il **bilancio** (che segue regole di redazione diverse rispetto alle altre società); tuttavia l'articolo presenta anche una parte di **delegificazione**, poiché oltre al bilancio si fa riferimento alle “segnalazioni periodiche” e a “ogni altro dato o documento richiesto”. Anche le modalità e i termini della consegna sono definiti da BI.

Inizialmente questa norma ha suscitato qualche perplessità, perché si riteneva che il potere attribuito alle autorità di vigilanza fosse eccessivo; in realtà si tratta di poteri solo astrattamente enormi, dal momento che le informazioni possono essere richieste solo tenendo conto del perseguimento delle finalità di cui all'**art. 5 TUB**.

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte III (altre disposizioni di vigilanza prudenziale), Capitolo 7 (Vigilanza informativa su base individuale e consolidata), Sezione I (Disposizioni di carattere generale), Premessa:

“L'acquisizione di elementi informativi da parte della Banca d'Italia riveste particolare rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza su banche e gruppi bancari. Essi consentono di verificare l'osservanza delle disposizioni da parte degli intermediari bancari, di valutarne la situazione e seguire l'evoluzione degli aggregati finanziari a fini di vigilanza e di politica monetaria. Le banche e le capogruppo pongono quindi in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio alla Banca d'Italia, con le modalità e nei tempi stabiliti. Sulla base degli elementi informativi acquisiti,

la Banca d'Italia produce un flusso informativo di ritorno volto a permettere agli intermediari di analizzare la propria attività aziendale in raffronto con il resto del sistema.”

(pagina 1-2)

2.3. La matrice dei conti (PUMA)

La **matrice dei conti**, identificata dall'acronimo **PUMA** (*Procedura Unificata di Matrice Aziendale*), è uno schema valido a livello nazionale, molto articolato in voci e sotto-voci, che ogni banca deve implementare e redigere una volta al mese (entro il 25 del mese considerato, con le informazioni relative al mese precedente).¹

Inizialmente le banche inviavano documenti e moduli in forma **cartacea** a BI, per cui si parlava di **vigilanza cartolare**² (perché le informazioni erano scritte su carta); attualmente documenti e dati sono stati trasformati in formato digitale.

Il processo si svolge come segue:

1. la banca invia la matrice dei conti implementata a BI;
2. BI svolge una prima verifica formale tramite un **sistema automatizzato** (il software verifica eventuali anomalie, ad esempio se i dati relativi al bilancio sono stati modificati durante l'anno³ o se alcuni dati inseriti risultano poco verosimili);
3. BI può o meno chiedere conferma alla banca in merito ad alcuni dati (anche questa fase oggi è digitale, ma un tempo c'erano dei fogli turchesi chiamati “puffi”);
4. la banca risponde nuovamente a BI confermando o correggendo i dati trasmessi;
5. BI analizza la banca in una **duplice prospettiva**: come singola banca (situazione complessiva) e in prospettiva comparata con le altre banche (analizzando le matrici dei conti fornite dalle altre banche). Una volta completata l'analisi — svolta attraverso modelli che non possono essere resi noti al pubblico — alcune informazioni restano esclusivamente a BI, mentre altre costituiscono un **flusso di ritorno** per la banca analizzata. In tale flusso è presente una valutazione sia sulla banca singolarmente sia in prospettiva comparata (ad esempio rispetto alla media regionale delle banche con la stessa forma giuridica). Sulla base di questo flusso di ritorno, BI fornisce dei **punteggi** sui quali basa la futura attività di vigilanza.

Attualmente non è ancora avvenuto un pieno passaggio della “vigilanza” sulla matrice dei conti al livello europeo: le *more significant bank* seguono ancora un **doppio canale** (invio della matrice dei conti sia alla BCE sia a BI), mentre le *less significant bank* la inviano solo a BI. La matrice dei conti “italiana” è comunque perfettamente in linea con le disposizioni di diritto europeo, ma è in corso un processo di armonizzazione su questa disciplina. *(pagina 2-3)*

¹Non tutte le voci necessitano di essere implementate a scadenza mensile.

²Non bisogna confondere questo concetto di *cartolare* con quello tipico del diritto commerciale relativo alla disciplina dei titoli di credito.

³Il bilancio viene redatto e approvato con cadenza annuale, quindi eventuali modifiche infrannuali non sono ammesse.

2.4. Altri documenti della vigilanza informativa

Nonostante la maggior parte della documentazione sia stata digitalizzata, vi sono ancora documenti esclusivamente cartacei: uno di questi è la **lettera di attestazione**. Tramite tale lettera (redatta secondo un apposito schema riportato nelle disposizioni di vigilanza), la banca attesta che le segnalazioni di vigilanza trasmesse a BI sono basate sui dati provenienti dalla contabilità e dal sistema informativo aziendale.

Questa lettera viene firmata da:

- il presidente del CDA (organo amministrativo);
- il presidente del collegio sindacale (organo di controllo interno);
- il direttore generale (esponente aziendale);
- il dirigente preposto (capo contabile).

Deve essere rinviata a BI ogni qual volta cambi uno di questi soggetti.

I dati e le informazioni richiesti da BI non si esauriscono con la matrice dei conti: ciascuna delle basi segnaletiche, per scelta di BI, è identificata da un **acronimo corrispondente al nome di un animale** (le segnalazioni **OR.SO** riguardano gli organi sociali, le segnalazioni **APE** si riferiscono all'assetto partecipativo dell'ente, etc.).

Oltre a questo, esistono delle **relazioni**, redatte su base mensile, trimestrale, semestrale e annuale (quella annuale è la più importante), stilate da BI e volte a giudicare lo stato di salute di una banca. In passato, per l'analisi annuale, gli analisti di BI valutavano le banche giudicando (con un punteggio coerente con il proprio giudizio) i seguenti profili, su una scala da 1 a 5, con media finale:

- adeguatezza patrimoniale;
- redditività;
- rischiosità;
- organizzazione;
- liquidità.

1 era il punteggio attribuito alle banche migliori, 5 quello assegnato alle banche peggiori, per le quali sarebbero scattate misure di rigore come il **commissariamento**. Il punteggio non teneva conto solo di questi elementi tecnici, perché l'analista valutava anche le **prospettive future** dell'impresa.

(pagina 3-4)

2.5. Il processo di controllo prudenziale (ICAAP, ILAAP, SREP)

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte I (Recepimento in Italia della direttiva CRD4), Titolo III (Processo di controllo prudenziale), Capitolo I (Processo di controllo prudenziale), Sezione I (Disposizioni di carattere generale), Premessa:

“Il processo di controllo prudenziale (Supervisory Review Process – SRP) si articola in due fasi integrate. La prima, rappresentata dai processi interni di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) e dell’adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP), fa capo alle banche, le quali effettuano un’autonoma valutazione, attuale e prospettica, dell’adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) ed è di competenza dell’autorità di vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell’ICAAP e dell’ILAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive.”

Il processo di controllo prudenziale si svolge quindi in **due fasi**:

1. una fase **“interna” alla banca**, che svolge in autonomia una valutazione dell’adeguatezza patrimoniale e della gestione del rischio di liquidità (la valutazione deve essere anche **prospettica** e tenere conto delle strategie aziendali) — è il momento di ICAAP e ILAAP;
2. una fase di competenza delle **autorità di vigilanza** (SREP), che formulano un giudizio complessivo sulla banca tenendo conto dell’ICAAP, dell’ILAAP, dei rischi sostenuti, del bilancio, etc.

Sempre dalla stessa Premessa della Circolare 285:

“I processi ICAAP e ILAAP sono imperniati su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppongono adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, efficaci sistemi di controllo interno.”

Questo costituisce il primo richiamo, nel materiale, all’importanza dei **sistemi di controllo interni**.

Infine:

“La responsabilità di tali processi è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l’organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative. Essi curano l’attuazione e promuovono l’aggiornamento dell’ICAAP e dell’ILAAP, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la banca opera.”

Viene appositamente specificato che la responsabilità di questi processi è rimessa agli **organi societari**: l’interlocuzione fra intermediari e autorità di vigilanza non implica in alcun modo **corresponsabilità** di queste ultime.

(pagina 4–5)

2.6. Le esposizioni creditizie deteriorate

Le modalità di definizione della qualità del credito sono cambiate nel tempo. Inizialmente si parlava di **posizioni in difficoltà** ed esistevano solo due categorie: le **sofferenze** e gli **incagli**.

Sofferenze — definizione: *“esposizioni nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche se non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario”*.

Alcune precisazioni:

- l'**insolvenza** non è sinonimo di inadempimento, ma di incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni; l'insolvenza è inoltre un presupposto oggettivo per essere dichiarati falliti;
- un soggetto fallito è sicuramente una sofferenza per la banca, ma non è scontato giungere alla stessa conclusione nel caso della sola insolvenza (va valutato caso per caso);
- la locuzione “anche se non accertato giudizialmente (o in situazioni equiparabili)” è stata aggiunta perché ci si potrebbe trovare davanti a soggetti che, a livello giuridico, non possono fallire;
- si prescinde dall’eventuale recupero (o meno) del credito.

Incagli — rappresentavano una difficoltà del cliente di tipo **temporaneo**. La banca doveva valutare in ogni singolo caso il motivo dell’inadempimento, fornire una propria valutazione e decidere in quale categoria inserire ogni esposizione; BI, ad esempio nell’esercizio delle funzioni di vigilanza informativa/ispettiva, poteva modificarla (si parlava in particolare di **sofferenze ispettive** laddove un incaglio fosse trasformato in una sofferenza; oggi la sofferenza ispettiva è riferita all'**inadempienza probabile**).

Con **Basilea II** ci si è resi conto che due categorie erano troppo limitative, per cui ne è stata aggiunta una terza. Attualmente il **Meccanismo Unico di Vigilanza** prevede tre categorie:

1. le **sofferenze** (identiche a prima);
2. le **inadempienze probabili** (che hanno sostituito gli incagli);
3. le **esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**.

Inadempienze probabili — definizione: esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia alle sue obbligazioni creditizie. L’accento non è più posto sulla **temporaneità**, ma sul fatto che, in assenza di azioni da parte della banca, la stessa non rientrerà del credito concesso.

Queste categorie entrano a far parte di un macro-gruppo definito **esposizioni creditizie deteriorate** (in inglese *Non Performing Loans*, NPL).

Un tempo esisteva inoltre il concetto di **dubbio esito** (quote di crediti vivi e di sofferenze di una banca che è ragionevole prevedere si traducano in perdite, già inserite a bilancio come perdita), attualmente sostituito da **perdite su crediti**⁴. (pagina 5–6)

⁴Hanno cambiato solo il nome, ma sostanzialmente è la stessa identica cosa.

2.7. Art. 52 TUB: comunicazioni del collegio sindacale e dei revisori legali

L'articolo 52 svolge una funzione di raccordo fra l'art. 51 (vigilanza informativa) e l'art. 53 (vigilanza regolamentare), poiché riguarda il collegio sindacale. Il collegio sindacale delle banche, a differenza del collegio sindacale delle società disciplinate dal diritto commerciale, ha l'obbligo, laddove rilevi anomalie, di segnalarle immediatamente a BI (o alla BCE). Secondo alcuni, il collegio sindacale rappresenterebbe quindi una specie di “**longa manus**” di BI nell'esercizio delle funzioni di vigilanza informativa.

2.7.1. La vecchia formulazione e i suoi problemi

La vecchia formulazione dell'art. 52 recitava:

Comma 1: *“I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti irregolarità nella gestione delle banche ovvero violazioni delle norme che ne disciplinano l'attività sono trasmessi in copia alla Banca d'Italia”.* **Comma 2:** *“La trasmissione del verbale deve avvenire, entro 10 giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale”.*

Laddove il collegio avesse rilevato irregolarità nella gestione della banca durante lo svolgimento di accertamenti, queste sarebbero dovute risultare dal verbale, che il presidente del collegio sindacale avrebbe poi dovuto trasmettere. Questa disciplina presentava tre problemi:

1. **il riferimento al verbale:** il verbale può essere redatto solo dal collegio sindacale in quanto organo, non dal singolo sindaco, che, laddove avesse rinvenuto un'irregolarità, non avrebbe potuto far nulla da solo;
2. **la trasmissione affidata al solo presidente:** se l'irregolarità fosse stata compiuta dal presidente stesso (o lo avesse comunque coinvolto), questi avrebbe potuto prendere tempo semplicemente ritardando la convocazione del collegio sindacale;
3. **le tempistiche di comunicazione:** anche una volta convocato il collegio, il presidente avrebbe avuto comunque a disposizione 10 giorni prima di trasmettere il verbale; 10 giorni che, in caso di una grave irregolarità, potrebbero essere fatali per una banca.

Questa disciplina si poneva inoltre in contrasto con quanto previsto dal **d.lgs. 231/2007** (disciplina antiriciclaggio), il cui art. 52 (relativo agli organi di controllo) disponeva che il collegio sindacale dovesse comunicare **senza ritardo** atti o fatti che potessero costituire una violazione delle disposizioni antiriciclaggio. Seguendo il principio per cui la legge speciale prevale su quella generale, ci si chiedeva quale fosse la legge prevalente: ragionando per materia, la legge antiriciclaggio era quella speciale; ragionando per soggetti (poiché la legge antiriciclaggio si applica a diversi soggetti), la legge speciale era invece il TUB.

Per tutti questi motivi l'art. 52 del TUB è stato **completamente riscritto** e, a seguito del regolamento 575/2013 UE, sono stati aggiunti gli **art. 52-bis e 52-ter**.

2.7.2. La nuova formulazione

Comma 1: *“Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.”*

Comma 2: *“Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d’Italia ogni altro dato o documento richiesto.”*

Osservazioni sulla nuova formulazione:

- la comunicazione del collegio sindacale deve ora avvenire **senza indugio** (non più entro 10 giorni);
- vengono distinti i concetti di **irregolarità** e **violazione**: la violazione è il mancato rispetto di una norma; l’irregolarità si riferisce a situazioni che non costituiscono formalmente violazione di una norma, ma rappresentano comunque qualcosa che può mettere a repentaglio la sana e prudente gestione dell’intermediario⁵;
- in ragione della riforma del diritto societario del 2003, si specifica “indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato”, perché i sistemi dualistico e monistico non prevedono il collegio sindacale;
- nel comma 2 si estende l’obbligo di comunicazione (sempre senza indugio) anche al **revisore legale dei conti**.

(pagina 6–7)

2.8. Art. 52-bis TUB: sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)

Comma 1: *“Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.”*

Si sancisce che le banche debbano adottare procedure specifiche per la segnalazione, da parte del personale, di atti o fatti che costituiscano una violazione. Viene data la **possibilità** (non l’obbligo) di segnalare le violazioni anche al personale. Questa norma “ufficializza” quello che negli ordinamenti anglosassoni è definito **whistleblowing**. In questo comma si parla solo di violazioni, non di irregolarità.

⁵Si può intendere al massimo come sinonimo di anomalia.

Comma 2: *“Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a: a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.”*

Il dipendente che effettua una segnalazione deve essere protetto sotto diversi punti di vista, per evitare ritorsioni da parte della banca. Le violazioni vengono segnalate e gestite da un determinato ufficio (di solito se ne occupa l’internal auditor o un addetto alla compliance)⁶.

Comma 3: *“La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.”* Comma autoesplicativo. (pagina 8)

2.9. Art. 52-ter TUB: segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia

Comma 1: *“La Banca d’Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonché atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.”*

Le segnalazioni possono quindi essere inoltrate anche **direttamente a BI**, oltre che internamente alla banca.

Comma 2: *“La Banca d’Italia tiene conto dei criteri di cui all’articolo 52 bis, comma 2, lettere a) e b), e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.”* BI rispetta quindi i medesimi criteri di riservatezza e tutela previsti dall’art. 52-bis comma 2, e predispone una procedura per ricevere le segnalazioni (in concreto, molto simile a quella in vigore per l’antiriciclaggio).

Comma 3: *“La Banca d’Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall’articolo 5.”* Il legislatore specifica che BI utilizza le informazioni solo se rilevanti ed esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, per le finalità di cui all’art. 5 TUB (previsione considerata ridondante).

Comma 4-bis: *“La Banca d’Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d’Italia può ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d’Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalità stabiliti dalle disposizioni del MVU.”*

Laddove le segnalazioni abbiano rilevanza anche per la BCE, BI le trasmette immediatamente all’autorità europea. (pagina 8-9)

⁶Cosa succede se la segnalazione riguarda proprio l’internal auditor, che è il soggetto a cui giungono queste segnalazioni? Nel materiale del corso resta una domanda aperta (“Boh”).

3 | La vigilanza regolamentare: adeguatezza patrimoniale e contenimento dei rischi (Art. 53 TUB)

Fonte: LEGB2_Appunti_03_Vigilanza-Regolamentare-Adeguatezza-e-Rischi.pdf — 9 pagine

3.1. Art. 53 TUB: struttura generale e potere regolamentare di Banca d'Italia

L'art. 53 TUB è stato nel tempo modificato e integrato. Inizialmente era previsto che Banca d'Italia (BI) potesse emanare:

- disposizioni di carattere **generale** (comma 1);
- disposizioni di carattere **particolare** (comma 3),

entrambe previa deliberazione del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio).

Attualmente BI opera in **autonomia**: è venuta meno l'approvazione del CICR e il comma 3 è stato abrogato. Le disposizioni di carattere particolare sono state trasferite nell'**art. 53-bis TUB**.

Ai sensi del **comma 1**, la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, fra le altre cose: - a) l'**adeguatezza patrimoniale**; - b) il **contenimento del rischio** nelle sue diverse configurazioni.

Queste due lettere costituiscono il filo conduttore del capitolo: la prima riguarda la dotazione di patrimonio della banca, la seconda l'insieme (in continua espansione) delle tipologie di rischio che la banca deve fronteggiare. (pagina 1)

3.2. L'adeguatezza patrimoniale: dal patrimonio di vigilanza ai fondi propri

Perché il patrimonio conta. A partire dal 1993 il patrimonio della banca ha assunto un'importanza crescente nella vigilanza prudenziale: rappresenta l'indice della capacità della

banca di gestire i rischi. La maggior parte degli indici (in inglese *ratios*) di vigilanza è infatti relativa alla dotazione patrimoniale della banca.

Il vecchio patrimonio di vigilanza. Inizialmente si parlava di *patrimonio di vigilanza* (termine ancora usato in alcune norme), concetto diverso dal patrimonio netto. Era composto da due elementi:

- **patrimonio di base:** elementi di maggiore certezza (capitale sociale interamente versato, meno le azioni proprie della banca — perché queste ultime non danno la stessa certezza delle azioni acquisite da terzi); era **interamente computabile**;
- **patrimonio supplementare:** frutto di una somma algebrica di voci considerate meno sicure (ad esempio i prestiti subordinati, computabili ma in misura limitata); era ammesso solo **in misura non superiore** al patrimonio di base.

Il livello minimo di patrimonio di vigilanza coincideva con la soglia minima di capitale sociale prevista per quella tipologia di banca. Queste regole risalgono ai primi accordi di Basilea.

Il passaggio ai fondi propri (Regolamento 575/2013 UE). Con l'entrata in vigore del Regolamento 575/2013 UE il quadro cambia terminologia e struttura:

- non si parla più di *patrimonio di vigilanza* ma di **fondi propri** (riprendendo la terminologia delle primissime direttive UE sulla vigilanza);
- l'art. 61 (titolo I, capo 1) del Regolamento definisce il **capitale primario e aggiuntivo di classe 1** (corrispondente al vecchio patrimonio di base); non si parla più di somma algebrica ma di **filtri prudenziali e deduzioni**;
- l'art. 62 definisce il **capitale di classe 2** (corrispondente al vecchio patrimonio supplementare).

Sono cambiate le soglie e i valori di alcuni indici, ma i concetti sottostanti restano quelli. Il livello di patrimonio minimo non è cambiato, ma è **venuto meno il vincolo** per cui il capitale di classe 2 non può superare il capitale di classe 1. La circolare 285 di BI non aggiunge nulla in materia perché la disciplina è già regolata interamente dal diritto europeo: la circolare riassume e rimanda al diritto UE senza deroghe di alcun tipo. (pagina 1–2)

3.3. Il coefficiente di solvibilità e i requisiti di fondi propri

Il vecchio coefficiente di solvibilità. Rappresentava il punto di contatto fra adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio, relativo al rischio di credito (principale rischio sopportato da una banca). Consisteva nel rapporto fra il credito erogato dalla banca e il suo patrimonio di vigilanza:

$$\text{Coefficiente di solvibilità} = \frac{\text{Credito erogato}}{\text{Patrimonio di vigilanza}}$$

Tale rapporto non doveva mai essere inferiore all'8% (se la banca faceva parte di un gruppo bancario poteva scendere al 7%, purché il gruppo nel complesso non scendesse sotto l'8%).

La ponderazione per rischio. La componente di credito era ponderata in base alla “categoria” del soggetto prestatore di fondi (il rischio di erogare fondi a uno Stato o a una pubblica amministrazione non è lo stesso di erogare credito alle imprese). Il limite di questo approccio era la mancanza di differenziazione **all'interno** della stessa categoria: ad esempio gli Stati avevano un coefficiente di ponderazione dello 0%, le imprese con bilanci in negativo un coefficiente del 200%, ma non tutti gli Stati meritavano uno 0% — esempio lampante è la crisi del debito greco: la Germania deteneva molti titoli di Stato greci con rendimento elevato e ponderazione 0%, ma questi titoli erano in realtà molto più rischiosi di quelli di altri Paesi.

Per adeguarsi al coefficiente, una banca poteva: (i) dotarsi di maggior capitale (rischiando proporzionalmente di più), oppure (ii) mantenere lo stesso patrimonio modificando la qualità del credito (riducendo il rischio sostenuto).

Il regime attuale. Il coefficiente di solvibilità non esiste più: è stato sostituito dai **requisiti di fondi propri** definiti agli artt. 92 e seguenti del Regolamento 575/2013 UE. Il **coefficiente di capitale totale** ne è l'erede diretto: la soglia resta l'8%, e continua ad esserci la ponderazione in base all'esposizione al rischio di credito (soggetto, garanzie, rischio Paese). Il cambiamento più significativo è che oggi si considera non solo il rischio di credito, ma **tutte** le altre tipologie di rischio emerse nel tempo (rischio di mercato, reputazionale, strategico, ecc.). *(pagina 2)*

3.4. Il contenimento del rischio: building block approach e mappa dei rischi bancari

Lett. b) art. 53 comma 1 TUB: *il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni.*

Questa lettera rappresenta la massima espressione di **delegificazione**. La chiave di lettura è la locuzione “nelle sue diverse forme”: i rischi supportati dalla banca sono aumentati nel tempo e il legislatore, invece di elencarli tutti in modo tassativo, ha optato per un processo di delegificazione, lasciando alla normazione secondaria (BI) il compito di individuarli e disciplinarli.

Building block approach. I rischi vengono affrontati dalle banche secondo un approccio detto *building block approach*: ogni rischio è considerato un blocco a sé stante, e la banca accantona una quota del proprio patrimonio per farvi fronte laddove necessario; i blocchi vengono poi sommati per ottenere un quadro complessivo.

Le principali tipologie di rischio individuate sono:

- **il rischio di credito** (o di controparte);
- **i rischi connessi alla funzione di trasformazione delle scadenze:** a seguito della despecializzazione le banche possono operare a breve o a medio/lungo termine; qui rientrano i rischi da eccessive immobilizzazioni, che a loro volta comprendono:
 - i rischi da investimenti in **immobili** (non prontamente liquidabili, aumentano il rischio di liquidità);
 - i rischi legati agli investimenti in **partecipazioni** (le partecipazioni in società non quotate non sono facilmente liquidabili);

- **i rischi di mercato**, che comprendono a loro volta: i rischi nel comparto finanza (titoli), i rischi su merci (prezzo di petrolio, gas, mais — esempio: impatto della guerra), i rischi valutari (esempio: rublo, sempre legato alla guerra);
- **i rischi operativi** nelle sue varie dimensioni, inclusi quelli non considerati inizialmente come il rischio informatico;
- **i rischi legali** (un tempo pochi clienti facevano causa alla banca, oggi è molto più frequente);
- **i rischi reputazionali**;
- **i rischi sistemici**: nei primi giorni di marzo (di un anno recente) è stata modificata la circolare 285 di BI inserendo questa nuova tipologia di rischio, con l'obbligo per le banche di destinare riserve di capitale e adottare misure macroprudenziali basandosi sulle caratteristiche tecniche dei finanziamenti erogati e dei propri clienti.

(pagina 2-3)

3.5. Il rischio di credito

Il rischio di credito è connesso alla probabilità che il prestatore di fondi non restituisca il capitale alla scadenza.

Strumenti storici di limitazione a monte. - La vecchia legge bancaria dava a BI la possibilità di stabilire un **limite mensile all'accrescimento degli impieghi** delle banche; questo strumento oggi non può più esistere perché costituirebbe vigilanza strutturale (vietata dall'attuale impianto normativo). Regola pratica: bisogna sempre diffidare da un aumento eccessivo degli impieghi di una banca, perché o la banca non ci guadagna nulla da quegli impieghi, oppure sta acquisendo clientela marginale (soggetti a cui nessun altro voleva dare denaro). - Un altro strumento di prudenza frazionale al rischio erano i **limiti ai grandi fidi** (oggi confluiti nella disciplina delle grandi esposizioni).

Il regime attuale (Regolamento 575/2013 UE). I limiti agli impieghi sono stati aboliti; il rischio di credito viene ora determinato attraverso le metodologie previste dal Regolamento 575/2013. In particolare, ai sensi dell'**art. 107** ("Metodi relativi al rischio di credito") sono previsti due metodi per la quantificazione del rischio di credito:

1. il **metodo standard**, proposto dalle autorità di vigilanza;
2. una metodologia alternativa basata su un **sistema di rating interno**, possibile solo per le banche di maggiori dimensioni che abbiano ottenuto apposita autorizzazione dalle autorità di settore, oppure da agenzie esterne a loro volta autorizzate dalle autorità di settore.

Gli aspetti più tecnici sono definiti agli artt. **111** (Valore dell'esposizione) e **112** (Classi di esposizioni) del Regolamento.

Resta un interrogativo aperto sulla parità concorrenziale: consentire ad alcune banche di costruirsi in casa il proprio sistema di rating, rispetto a chi usa il metodo standard, potrebbe alterare la parità competitiva fra intermediari.

(pagina 3-4)

3.6. La disciplina delle grandi esposizioni

Le banche devono operare anche tenendo conto della disciplina relativa alla **concentrazione del rischio**, cioè della normativa sulle grandi esposizioni (in passato si parlava di “grandi fidi”).

Regolamento 575/2013 UE, art. 392 (Definizione di grande esposizione), comma 1: *L'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande esposizione quando il suo valore è pari o superiore al 10% del capitale ammissibile dell'ente.*

Rispetto al passato, in cui si faceva riferimento al patrimonio di vigilanza, oggi si utilizza il concetto di **capitale ammissibile** dell'ente (sottovoce dei fondi propri). La grande esposizione non riguarda solo il singolo cliente, ma anche il **gruppo di clienti connessi**: quando una banca analizza un cliente deve tener conto di tutte le sue possibili connessioni, non solo in senso giuridico (appartenenza a un gruppo consolidato) ma anche in senso economico (con quali altri clienti opera il soggetto a cui si vuole erogare denaro). Va inoltre tenuta presente la differenza fra società di persone (responsabilità illimitata) e società di capitali (responsabilità limitata).

Regolamento 575/2013 UE, art. 395 (Limiti delle grandi esposizioni), comma 1: *(...) l'ammontare dell'esposizione di un ente verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera il 25% del capitale ammissibile dell'ente stesso.*

In passato erano previsti sia un **limite globale** (l'insieme delle grandi esposizioni non poteva superare 8 volte il patrimonio di vigilanza) sia un **limite individuale**; oggi è rimasto solo un limite quantitativo individuale: il valore di ciascuna grande esposizione deve restare entro il 25% del capitale ammissibile.

Norme organizzative. Esistono inoltre norme di carattere organizzativo (Regolamento 575/2013 UE, art. 393, “Capacità di individuare e gestire grandi esposizioni”), riprese e spiegate nella circolare 285 di BI anche tramite esempi concreti: nel caso delle grandi esposizioni la banca dovrebbe valutare attentamente la richiesta, usare una forma tecnica adeguata, svolgere un monitoraggio più frequente, ecc.

Parti correlate e soggetti collegati. Un ulteriore aspetto è quello del potenziale conflitto di interesse nei confronti dei soggetti collegati, affrontato nella parte III (“Altre disposizioni di vigilanza prudenziale”), capitolo 11, delle disposizioni di vigilanza relative alle **operazioni con parti correlate**. Quando la banca ha a che fare con parti correlate (ad esempio i propri esponenti) deve adottare particolari cautele di natura qualitativa. L'intera sezione III delle disposizioni riguarda le procedure deliberative: quando il richiedente del finanziamento è una parte correlata è necessaria un'istruttoria particolare, la votazione deve essere realizzata da amministratori indipendenti, serve documentazione particolare, ecc. Il tema si collega anche al principio di **separatezza banca-industria**, motivo per cui servono norme specifiche.

Art. 136 TUB (Obbligazioni degli esponenti aziendali), comma 1: *Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od*

indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.

La norma prevede quindi la possibilità per una banca di erogare credito ai propri esponenti (non c'è un divieto di finanziamento nei confronti di sindaci o consiglieri di amministrazione), a condizione che il soggetto interessato informi preventivamente la banca e non prenda parte alla votazione. (pagina 4-5)

3.7. La centrale dei rischi

Origini. Non è chiaro se la centrale dei rischi sia stata un'invenzione prettamente italiana, ma l'Italia è stata fra i primi Paesi ad adottarla, già nel **1962**. È una banca dati gestita da BI che raccoglie le informazioni di tutte le banche (e di tutti gli intermediari non bancari che erogano credito, disciplinati dal titolo V TUB) in materia di crediti e finanziamenti erogati.

La disciplina non è mai stata completamente armonizzata a livello europeo: nella maggior parte dei Paesi europei esistono centrali dei rischi con proprie regole, che si scambiano informazioni fra loro.

Evoluzione delle soglie. Sono sempre esistite centrali dei rischi sia pubbliche che private. Censire tutto il credito erogato, a prescindere dalla dimensione dell'operazione, sarebbe troppo oneroso sia per BI sia per le singole banche; per questo si era inizialmente optato per un obbligo di comunicazione solo per le operazioni di valore superiore a **75.000 euro**. Le banche avevano poi creato una centrale dei rischi privata, la **centralina dei rischi**, per gestire le operazioni di ammontare compreso fra **30.000** e **75.000 euro**. Per le banche specializzate che erogano molti finanziamenti di importo contenuto (ad esempio il credito al consumo) fu creata un'ulteriore centrale dei rischi per le operazioni di valore inferiore a 30.000 euro (che si occupa anche di analizzare le anomalie dei sistemi di pagamento, ad esempio quelle relative alle carte di credito).

BI ha poi riconosciuto l'importanza delle centrali dei rischi private, imponendo alle banche la partecipazione alla centralina dei rischi, per poi eliminare direttamente il doppio canale "inglobando" la centralina dei rischi nella centrale dei rischi principale. **Attualmente** si viene registrati nella centrale dei rischi sia a seguito dell'apertura di un'operazione di valore superiore a 30.000 euro, sia se un'esposizione di valore inferiore dovesse passare a **sofferenza**.

I due servizi offerti dalla centrale dei rischi. Le disposizioni di vigilanza non si soffermano sulla disciplina della centrale dei rischi, disciplinata da un'apposita circolare pubblicata sul sito di BI. La centrale dei rischi offre alle banche due servizi:

1. **Il flusso di ritorno** (gratuito): basato sui nominativi che la banca segnala inserendo in centrale dei rischi. Quando la banca eroga un finanziamento superiore a 75.000 euro,

segnala il cliente e riceve il flusso di ritorno; la banca segnala non solo l'erogazione del credito, ma anche ogni peggioramento dell'esposizione creditizia. Il flusso è inviato da BI una volta al mese sotto forma di comunicazione che presenta la situazione del soggetto in termini di esposizione verso il sistema bancario (ad esempio se ha ricevuto finanziamenti da altre banche, o se vi sono anomalie come un'esposizione passata a sofferenza). Queste informazioni sono importanti sia per la banca (anche a fini di marketing, per "sponsorizzare" operazioni verso clienti affidabili, o per valutare la capacità di rimborso) sia per BI, che può monitorare la situazione complessiva.

2. **Il servizio di prima informazione** (a pagamento): utilizzato dalle banche per richiedere a BI informazioni su soggetti che sono alla loro prima operazione con un intermediario.

Criticità del meccanismo. Le informazioni sono inserite dalla banca stessa: una banca che ha concesso un finanziamento a un cliente inadempiente potrebbe cercare accordi sottobanco per non doverlo segnalare come sofferenza.

Segnalazioni erronee o mancate. Il concetto di segnalazione erronea può comprendere diversi casi: essere segnalati pur non avendo mai ricevuto un finanziamento, importo del finanziamento inserito errato, esposizione passata a sofferenza nonostante il pagamento regolare. In questi casi il soggetto **non può agire legalmente contro BI**, ma può agire nei confronti della banca che ha realizzato la segnalazione errata (si tratta di una forma di responsabilità contrattuale). Un errore di segnalazione può generare anche conflitti fra banche: se una banca omette di segnalare un'esposizione che dovrebbe passare a sofferenza, un'altra banca rischia di assumere decisioni sulla base di informazioni errate.

Accesso ai dati. Fino a circa 15 anni fa i dati della centrale rischi per i privati cittadini erano così riservati da non poter essere ottenuti neanche dal diretto interessato; attualmente ci si può rivolgere a BI e ottenere le informazioni. *(pagina 5-7)*

3.8. Il rischio di trasformazione delle scadenze e la disciplina degli investimenti immobiliari

A seguito del processo di despecializzazione (in particolare di quella operativa) sono state introdotte nuove regole di vigilanza:

- norme sul finanziamento a medio-lungo termine alle imprese (**oggi abrogate**);
- limiti alle funzioni di trasformazione delle scadenze (**oggi abrogati**);
- limiti agli investimenti per loro natura difficilmente liquidabili, come quelli in **immobili** e in **partecipazioni** (**attualmente in vigore**).

Oggi si presta minore attenzione a regole specifiche sui rischi di trasformazione delle scadenze, perché è stato predisposto un sistema che, sulla base di algoritmi, monitora direttamente la liquidità delle banche (art. 411 e seguenti del Regolamento 575/2013). Restano invece in vigore le nozioni contenute nelle disposizioni di vigilanza di BI relative agli immobili: pur essendo inserite in disposizioni di vigilanza, sono vere e proprie norme il cui mancato rispetto comporta sanzioni.

Disposizioni di vigilanza, Sezione I, Premessa: *Le scelte in materia di detenzione e gestione di beni immobili rientrano nell'autonomia delle banche e dei gruppi bancari, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile. Esse sono effettuate nel rispetto della "tipicità" dell'oggetto sociale bancario, in coerenza con il Risk Appetite Framework e con le politiche e il processo di gestione dei rischi; è in ogni caso esclusa la possibilità di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo.*

Questa premessa richiama l'attività bancaria definita dall'art. 10 TUB, commi 1 e 3: le banche non sono agenzie immobiliari e non possono occuparsi di compravendita di immobili a fini **esclusivamente** speculativi. Questo non implica che una banca non possa possedere immobili in assoluto (ad esempio a seguito dell'escussione di garanzie), né che, vendendone uno di cui non ha più bisogno, debba necessariamente subire una perdita.

Disposizioni di vigilanza, Sezione I, Premessa: *Per salvaguardare l'equilibrio della struttura finanziaria, gli investimenti immobiliari sono effettuati nel rispetto della regola per cui l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni non può eccedere l'ammontare complessivo dei fondi propri.*

Disposizioni di vigilanza, Sezione II, comma 1: *Le banche e i gruppi bancari possono acquisire immobili a uso strumentale, per tali intendendosi gli immobili che rivestono carattere ausiliario rispetto all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria; è esclusa la possibilità di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo. A titolo esemplificativo, si considerano strumentali gli immobili destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale, o a essere concessi in locazione ai dipendenti e ogni altro immobile acquisito per il perseguimento dell'attività bancaria e finanziaria.*

Viene quindi ammessa l'acquisizione di immobili a fini strumentali (ad esempio per l'apertura di una nuova sede); il concetto di strumentalità qui è inteso in senso più ampio rispetto a quello dell'art. 10 TUB comma 3, ma le attività strumentali restano comunque le stesse previste da tale norma.

Disposizioni di vigilanza, Sezione II, comma 2: *L'investimento in beni immobili, anche per finalità legate alla tutela delle ragioni creditorie di banche e gruppi bancari, è accompagnato dall'adozione di presidi organizzativi e gestionali nell'ambito delle cautele richieste dalla disciplina prudenziale che presiede all'efficace gestione dei rischi cui banche e gruppi bancari sono esposti per garantire una gestione sana e prudente.*

Disposizioni di vigilanza, Sezione II, comma 3: *(...) Secondo questa regola, l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e in partecipazioni va contenuto entro il limite dell'ammontare complessivo dei fondi propri. Il limite può essere superato quando ciò sia dovuto ad operazioni di acquisizione di immobili a tutela delle ragioni di credito, secondo quanto previsto dal presente Capitolo; a questi fini si considerano acquisiti per recupero crediti anche gli immobili dei quali la banca o la società del gruppo bancario si è rimpossessata a seguito di scioglimento dei contratti di*

locazione finanziaria. La banca o la capogruppo del gruppo bancario, quando prevede o ha accertato il superamento del limite generale, redige un programma contenente le misure da adottare per il rientro nel limite (che possono comprendere la dismissione di immobili e/o misure volte a incrementare i fondi propri); il programma prevede che le misure sono attuate in un arco di tempo ragionevole, compatibile con l'esigenza di preservare il valore di realizzo degli immobili (di norma entro quattro anni).

In sintesi: l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni non può eccedere i fondi propri della banca, salvo l'eccezione per gli immobili acquisiti a tutela del credito, per i quali comunque è previsto un piano di rientro entro un arco di tempo ragionevole (di norma quattro anni).

(pagina 7-8)

3.9. Il rischio di raccolta e la riserva obbligatoria

Il rischio di raccolta fa riferimento a un istituto ormai quasi del tutto sparito. Il rischio di liquidità di una banca dipende da due componenti:

- il **rischio di credito**: possibilità che i prenditori di fondi non restituiscano il capitale;
- il **rischio di raccolta**: possibilità che la banca non riesca a ottenere fondi dalla clientela.

La riserva obbligatoria (ROB). Le vecchie norme prevedevano che una certa percentuale della raccolta non potesse essere erogata sotto forma di credito, ma dovesse essere depositata presso BI nella riserva obbligatoria. Ogni mese (in particolare il **15 del mese di riferimento**) si effettuava un calcolo sui depositi a vista, e una certa percentuale stabilita da BI (arrivata, in un certo periodo, al **27,5%**) doveva essere depositata presso la riserva obbligatoria.

Col tempo ci si rese conto che questo strumento non tutelava effettivamente i depositanti: anche in caso di fallimento dell'istituto, i depositanti avrebbero ricevuto indietro solo **1/4** della somma depositata. La riserva obbligatoria è quindi passata da strumento di presidio della liquidità della banca a strumento di **politica economica/monetaria**.

Negli anni precedenti alla costituzione della moneta unica, ci si rese inoltre conto che negli altri Paesi europei la soglia di capitale da destinare alla riserva obbligatoria era inferiore al **5%**. Attualmente la soglia è determinata dalla **BCE** ed è pari all'**1%**.

(pagina 8-9)

3.10. Il rischio di mercato

Il rischio di mercato è una tipologia di rischio emersa a seguito dell'entrata in vigore del TUB: da quando le banche hanno potuto operare anche in altri settori, come il comparto finanza, sono aumentati sia i potenziali guadagni sia i possibili rischi.

Il vecchio regime dei portafogli titoli. Le norme inizialmente prevedevano che le banche dichiarassero i motivi per cui acquistavano titoli:

- se l'acquisto era finalizzato all'erogazione di un servizio di investimento alla clientela, il titolo veniva inserito nel **portafoglio titoli non immobilizzato**;

- se l'acquisto era finalizzato alla detenzione “personale” della banca, il titolo veniva inserito nel **portafoglio immobilizzato**.

Per evitare che un istituto trasferisse un titolo dal portafoglio immobilizzato a quello non immobilizzato per “scaricarlo” sui clienti meno esperti, le vecchie norme non consentivano, salvo rari casi comunque da motivare, il trasferimento da un portafoglio all'altro.

Il regime attuale. Le norme non prevedono più il portafoglio immobilizzato, poiché lo stesso è ricavabile dai principi contabili imposti dall'IFRS 9; il portafoglio non immobilizzato è stato ridefinito **portafoglio di negoziazione** (art. 86 e seguenti del Regolamento 575/2013 UE).

(pagina 9)

3.11. Il rischio di regolamento

Un'ulteriore tipologia di rischio è quella di **regolamento**, definita ai sensi della circolare 229 (“Istruzioni di vigilanza”) e, attualmente, ai sensi dell'**art. 378 del Regolamento 575/2013 UE**.

Il rischio di regolamento è il rischio che si determina nelle operazioni di transazioni su titoli qualora la controparte, dopo la scadenza del contratto, non abbia adempiuto alla propria obbligazione di consegna dei titoli o degli importi di denaro dovuti.

Dal momento che non tutte le posizioni sui titoli necessitano di essere regolate immediatamente, esiste per la banca il rischio che una controparte non adempia alle proprie obbligazioni entro il termine previsto. Anche in questo caso la disciplina impone accantonamenti a copertura del rischio assunto.

Nota: il testo delle slide si interrompe a questo punto (fine pagina 9); la trattazione del rischio di regolamento e del rischio di concentrazione, annunciata nel titolo del paragrafo, non prosegue oltre nel materiale disponibile.

(pagina 9)

4 | Vigilanza Regolamentare: le Partecipazioni Detenibili dalle Banche (Art. 53 TUB)

Fonte: LEGB2_Appunti_04_Vigilanza-Regolamentare-Partecipazioni.pdf — 7 pagine

4.1. Il rischio su merci e il rischio di cambio

Il rischio di mercato non riguarda esclusivamente il comparto titoli (rischio di regolamento), ma può essere riferito anche alle merci e al valore del tasso di cambio (entrambi definiti ai sensi degli artt. 355 e seguenti del Regolamento 575/2013 UE).

- **Rischio su merci:** si riferisce alla possibilità di variazione del valore del bene sottostante (petrolio, gas, grano, mais, etc.); la banca si copre da questo rischio tramite una garanzia (in particolare un pegno) sulle merci stesse.
- **Rischio di cambio:** si riferisce all'oscillazione del prezzo delle valute. È un rischio trasversale: su un titolo, ad esempio, una banca supporta sia il rischio di mercato sia il rischio di cambio se il titolo è stato contratto in valuta straniera.

(pagina 1)

4.2. Il rischio operativo

Negli ultimi 20 anni le banche hanno iniziato a supportare un numero sempre crescente di rischi ascrivibili alla macro-categoria dei rischi operativi (categoria già di per sé difficilmente quantificabile). Il rischio operativo è stato definito per la prima volta nel 1998 all'interno della circolare 263 di Banca d'Italia; questa circolare è stata successivamente abrogata e nella circolare 285 non viene ripresa questa tipologia di rischio, per cui l'unico riferimento a livello normativo resta oggi il Regolamento 575/2013 UE.

Il rischio operativo è il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico.

La definizione fa riferimento a una serie di elementi molto eterogenei:

- l'**inadeguatezza** può essere riferita alla cattiva contabilità tenuta dall'impresa (si guardino le voci "altri debitori/creditori"), alla negligenza o dolosità della componente umana, alla presenza di eventi esogeni (bug o attacchi informatici);
- il **rischio giuridico** comprende al proprio interno il rischio legale (o di contenzioso), ma si riferisce anche alla possibile errata interpretazione delle norme da parte della banca.

(pagina 1)

4.3. Art. 53 TUB: l'evoluzione della disciplina sulle partecipazioni

Art. 53 TUB: Vigilanza Regolamentare; Partecipazioni detenibili — lett. c) partecipazioni detenibili.

Questa disciplina può essere compresa solo considerando congiuntamente quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza e dal Regolamento 575/2013 UE.

Come già accennato nella prima parte del corso, l'entrata in vigore del TUB aveva eliminato la separatezza banca-industria imposta dalla precedente legge bancaria, sia per le partecipazioni **a monte** che per quelle **a valle**, passando da un divieto assoluto a una soglia massima del 15%.

Con l'avvento della despecializzazione, però, le banche non erano più tutte uguali: non tutte svolgevano più solo ed esclusivamente il binomio raccolta-credito, e quindi non sarebbe stato giusto trattare allo stesso modo banche diverse (ad esempio una banca d'affari non è uguale a una banca d'investimento, né a una banca commerciale). Banca d'Italia, oltre a implementare delle basi segnaletiche (Assetti Partecipativi Enti, APE) attraverso cui monitorare l'evolversi della situazione per le banche, tramite le istruzioni di vigilanza suddivise le banche in tre grandi categorie: **banche ordinarie**, **banche abilitate** e **banche specializzate**.

A seguito della Direttiva 44/2007 UE venne rivista la disciplina relativa all'acquisizione di partecipazioni a monte, modificando l'art. 19 e seguenti del TUB, ma nulla venne fatto in merito alle partecipazioni a valle. Si trattò di una vera e propria incoerenza del legislatore, per altro non giustificata: il tema delle partecipazioni è ugualmente pericoloso tanto a monte quanto a valle. Solo successivamente, nel 2013, si è intervenuti per eliminare questa discrepanza.

(pagina 1-2)

4.4. Circolare 285, Parte III, Cap. 1 — Premessa: finalità della disciplina delle partecipazioni detenibili

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte III (Altre disposizioni di vigilanza prudenziale), Sezione I, Capitolo 1 (Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari), Premessa:

La disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari è diretta a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimen-

ti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie; con specifico riferimento a queste ultime, mira altresì a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione. In vista di tali obiettivi la disciplina fissa, in primo luogo, un limite generale all'investimento in partecipazioni e in immobili, da contenere entro l'ammontare dei fondi propri a livello consolidato. Le disposizioni contengono, inoltre, le discrezionalità previste dal CRR. I limiti prudenziali in materia hanno carattere inderogabile; in caso di involontario superamento le banche devono assicurare il riallineamento nel più breve tempo possibile. I limiti trovano applicazione, con criteri e modalità specifici, anche per forme di investimento in equity realizzate indirettamente attraverso organismi interposti tra la banca e l'impresa finale (es. fondi di private equity, veicoli societari ecc.). Specifiche cautele sono previste per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria o per finalità di recupero crediti, in considerazione della elevata rischiosità di tali investimenti e a presidio dell'obiettività delle relative decisioni. L'acquisizione di partecipazioni è soggetta ad autorizzazione preventiva soltanto in caso di investimenti in imprese di natura finanziaria che, per la loro rilevanza, siano suscettibili di determinare impatti sulla struttura finanziaria e patrimoniale dell'acquirente, nonché per acquisizioni da cui possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza consolidata. La disciplina dei limiti prudenziali e delle autorizzazioni è completata dall'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni orientati a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e corretta gestione dei conflitti di interesse, ivi inclusa la possibilità di adottare, ove appropriato, soluzioni ispirate a forme di separazione organizzativa o societaria fra l'attività di investimento partecipativo e la rimanente attività bancaria, in particolare quella di erogazione del credito. La concreta attuazione di tali principi nelle diverse realtà aziendali è guidata dal principio di proporzionalità, con riguardo alle diverse caratteristiche e strategie degli intermediari.

Sin dalla premessa si specifica che tutta la disciplina è volta a contenere il rischio di un'eccessiva immobilizzazione dell'attivo derivante da investimenti in imprese finanziarie e NON finanziarie (quindi anche partecipazioni a valle in imprese industriali). Con riferimento alle partecipazioni in imprese non finanziarie, la disciplina mira a promuovere una gestione dei rischi e dei potenziali conflitti di interesse volta alla sana e prudente gestione dell'istituto (richiamo alla finalità dell'art. 5 TUB). Si specifica anche che i limiti prudenziali hanno carattere inderogabile e che, in caso di involontario superamento di tali limiti, le banche devono rientrarvi nel minor tempo possibile. Altre specifiche cautele sussistono in caso di acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà. Si prevede infine che la disciplina sia completata anche dai principi in materia di organizzazione interna.

(pagina 2-3)

4.5. La definizione di “partecipazione”

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Premessa, Definizioni:

“Partecipazione”: il possesso di azioni o quote nel capitale di un'altra impresa che,

realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole ai sensi delle presenti disposizioni, nonché nelle altre ipotesi in cui l'investimento della banca si accompagni a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari.

Viene appositamente specificato che si parla di partecipazione soltanto laddove il possesso delle azioni (o delle quote) abbia come finalità la creazione di un legame durevole con l'impresa di cui si vuole assumere una partecipazione. **Non** rientra nella definizione di partecipazione “il mero possesso di azioni a titolo di pegno, disgiunto dalla titolarità del diritto di voto”. (pagina 3)

4.6. Il limite generale agli investimenti in partecipazioni e immobili

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione II (Limite generale agli investimenti in partecipazioni e immobili), Limite generale:

Non possono essere acquisite partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili. Il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili è dato dalla differenza tra i fondi propri e la somma delle partecipazioni e degli immobili, comunque detenuti. Ove, in relazione a eventi particolari, si verifichi una riduzione dei fondi propri di entità tale da comportare il superamento del limite generale, l'organo con funzione di gestione sottopone all'organo con funzione di supervisione strategica un programma che prevede il riallineamento alla presente disciplina nel più breve tempo possibile.

Il limite generale è espresso dalla relazione:

$$\text{Immobili} + \text{Partecipazioni} < \text{Fondi Propri}$$

Laddove venisse superato questo limite, l'organo con funzione di gestione deve redigere e presentare un programma all'organo con funzione di supervisione strategica per il riallineamento nel più breve tempo possibile.

Modalità di calcolo (Sezione II): ai fini del calcolo del margine disponibile si intendono per “immobili” gli immobili di proprietà (al netto dei relativi fondi di ammortamento) e gli immobili acquisiti in locazione finanziaria. Sono esclusi gli immobili di proprietà ceduti in locazione finanziaria e quelli acquisiti con i fondi di previdenza del personale.

Vi sono differenze rispetto agli investimenti immobiliari propriamente detti: in quel caso per “immobili” si intendono anche gli immobili di proprietà e gli immobili acquisiti in locazione finanziaria. (pagina 3-4)

4.7. Il limite delle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie (Art. 89 CRR)

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione III (Limite delle partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie), Casi di superamento dei limiti:

Quando le partecipazioni qualificate detenute in imprese non finanziarie superano le soglie indicate dall'art. 89, parr. 1 e 2, CRR, si applica l'opzione prevista dall'art. 89, par. 3, lett. a), CRR.

In caso di superamento dei limiti quantitativi previsti per le partecipazioni qualificate detenute in imprese non finanziarie si ha quindi un rimando diretto all'art. 89 del Regolamento UE 575/2013.

Regolamento 575/2013 UE, Art. 89 (Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario):

Comma 1. Una partecipazione qualificata, il cui importo superi il 15% del capitale ammissibile dell'ente, in un'impresa che non è una delle seguenti, è soggetta alle disposizioni di cui al paragrafo 3: a) un soggetto del settore finanziario; b) un'impresa, diversa da un soggetto del settore finanziario, che svolge attività che l'autorità competente ritiene essere una delle seguenti: i) l'estensione diretta dell'attività bancaria; ii) servizi ausiliari dell'attività bancaria; iii) leasing, factoring, gestione dei fondi comuni d'investimento, gestione di servizi informatici o attività analoghe.

Comma 2. L'importo totale delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che supera il 60% del suo capitale ammissibile è soggetto alle disposizioni di cui al paragrafo 3.

Comma 3. Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2: a) ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1250% al maggiore dei seguenti importi (...).

Anche in questo caso riemerge la distinzione fra attività bancarie/finanziarie e attività industriali.

La regola generale è che il limite massimo previsto per la detenzione di partecipazioni in imprese non finanziarie (o meglio, per le imprese che non rientrano nelle categorie del comma 1) è del **15%**: sopra questa soglia l'acquisizione è comunque permessa, ma con accantonamenti superiori (fattore di ponderazione del rischio del 1250% ai fini del requisito patrimoniale). Nella determinazione di questa percentuale non si tiene conto di tre casi specifici, trattati nelle sezioni seguenti: le partecipazioni acquisite nell'attività di collocamento e garanzia, quelle in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e quelle acquisite per recupero crediti. (pagina 4-5)

4.8. Partecipazioni acquisite nell'attività di collocamento e garanzia

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione IV (Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'attività di collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria per recupero crediti), Attività di collocamento e garanzia:

Non si computano nel limite generale le azioni e gli altri strumenti di capitale detenuti nell'ambito dell'attività di collocamento di titoli di nuova emissione con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, anche svolta mediante la partecipazione a consorzi, per un periodo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla chiusura del collocamento stesso. I valori mobiliari rimasti nel portafoglio di proprietà della banca oltre detto periodo, se non classificati nel portafoglio di negoziazione, devono essere computati nei suddetti limiti.

Quando un'impresa opta per un aumento di capitale, in fase di collocamento si affida a più banche. Queste banche costituiscono quello che viene definito un **consorzio di collocamento** (al cui interno è identificata una banca capofila) e redigono un contratto che lega l'impresa in questione al consorzio. Bisogna distinguere l'attività di collocamento "semplice" (in cui l'operazione viene ultimata a prescindere dai risultati raggiunti) dal collocamento con garanzia (in cui le banche si impegnano a sottoscrivere le eventuali azioni non collocate). Laddove le banche acquisiscano queste azioni, possono inserirle nel portafoglio di negoziazione oppure mantenerle (nel qual caso sono assoggettate a queste norme di limite). (pagina 5)

4.9. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione IV, Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria:

L'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti e al fine di consentirne il riequilibrio, deve essere valutata con estrema cautela per la complessità e l'elevato grado di incertezza che caratterizzano tali operazioni. In particolare deve essere attentamente verificata la sussistenza di una convenienza economica di tali operazioni. La conversione di crediti può rivelarsi vantaggiosa a condizione che la crisi dell'impresa affidata sia temporanea, riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e non di mercato, e perciò esistano ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo. L'intervento delle banche che intendono acquisire partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria deve inquadrarsi in una procedura basata sui seguenti punti: (...).

L'operazione relativa all'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà deve essere valutata con estrema cautela; la banca deve tenere conto di una serie di elementi citati

nelle disposizioni, tra cui la convenienza economica dell'operazione e il fatto che si tratti di una difficoltà riconducibile ad aspetti finanziari e non di mercato. Questa operazione viene valutata tramite la redazione di un **piano di recupero**, in cui vengono fatti emergere e valutati tutti questi elementi, che deve successivamente essere approvato dall'organo con funzione di gestione (CdA).

In questo contesto è fatto divieto per la banca di acquisire azioni o altri strumenti della società in difficoltà già in circolazione; è possibile però sottoscrivere azioni di nuova emissione. Quando l'operazione di acquisizione di partecipazioni è svolta da più imprese si parla di **operazione in pool**. *(pagina 5-6)*

4.10. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione IV, Partecipazioni acquisite per recupero crediti:

L'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice oppure di interessenze detenute dal debitore al fine di recuperare il credito può essere effettuata nel rispetto dei limiti di concentrazione, complessivo e generale, e delle altre condizioni stabilite nel presente paragrafo. Le partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice devono essere finalizzate a facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell'attivo della società al fine di liquidare il patrimonio dell'impresa. Tale intervento deve essere approvato dall'organo con funzione di gestione con una delibera che ne metta in luce la convenienza rispetto all'avvio di altre iniziative di recupero, anche coattivo.

Anche laddove la finalità sia il recupero crediti è possibile eccedere la soglia citata in precedenza, ma anche in questo caso bisogna giustificare il perché di questa operazione. *(pagina 6)*

4.11. Partecipazioni in banche, imprese finanziarie, assicurative e strumentali: autorizzazioni

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione V (Partecipazioni in banche, imprese finanziarie, in imprese assicurative e in imprese strumentali), Autorizzazioni:

L'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia qualora, considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti, la partecipazione: a) superi il 10% dei fondi propri consolidati del gruppo bancario; oppure b) comporti il controllo o l'influenza notevole; c) l'acquisizione di partecipazioni in imprese strumentali è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia nei casi sopra indicati.

Criteri di autorizzazione: ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia valuta se la situazione tecnica e organizzativa del richiedente sia tale da sostenere l'acquisizione e se

l'ulteriore articolazione organizzativa sia compatibile con le esigenze della vigilanza su base consolidata. L'autorizzazione è negata, in particolare, qualora per effetto della deduzione della partecipazione dai fondi propri o del consolidamento dell'impresa partecipata venga meno il rispetto del requisito patrimoniale complessivo.

Procedimento e comunicazioni: la richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dalla banca non appartenente a un gruppo bancario, oppure dalla capogruppo per gli investimenti propri e per quelli delle controllate. Le acquisizioni di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative non soggette ad autorizzazione o comunicazione preventiva ai sensi delle presenti disposizioni, ma che comportino (considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti) il superamento della soglia dell'1% dei fondi propri, sono comunicate alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal perfezionamento dell'operazione.

Nell'ambito delle partecipazioni a valle in imprese finanziarie, la disciplina è sostanzialmente quella dell'art. 19 TUB. (pagina 6-7)

4.12. Regole organizzative di governo societario (Sezione VII)

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione VII (Regole organizzative di governo societario):

In conformità del principio di sana e prudente gestione, gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono essere orientati all'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, creditizia in particolare. Le soluzioni adottabili in concreto, rimesse all'autonomia degli intermediari, devono essere adeguate alle caratteristiche e strategie della banca o del gruppo bancario, nel rispetto del principio generale di proporzionalità, e risultare efficaci rispetto alla finalità di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse. A tal fine, l'organo con funzione di supervisione strategica della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, approva le politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. In particolare le politiche interne determinano le strategie della banca o del gruppo bancario in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie. In tale ambito, le decisioni d'investimento e la gestione del portafoglio di partecipazioni [...]

Nota: il testo si interrompe qui a fine pagina 7; il documento sorgente disponibile termina a questo punto. (pagina 7)

5 | Vigilanza Regolamentare e Governo Societario (Art. 53 TUB)

Fonte: LEGB2_Appunti_05_Vigilanza-Regolamentare-Governo-Societario.pdf — 15 pagine

5.1. Premessa: conflitti di interesse nelle partecipazioni in imprese non finanziarie

Chiusura di un discorso precedente (il paragrafo si apre a metà frase, come continuazione della lezione precedente) sulle partecipazioni delle banche in imprese non finanziarie.

Le partecipazioni in imprese non finanziarie devono essere orientate al criterio della **redditività al netto del rischio**. Deve inoltre essere individuata la propensione al rischio in termini di massimo grado di immobilizzo dei fondi propri ritenuto accettabile, sia con riferimento al complesso degli investimenti sia alle partecipazioni in singole imprese non finanziarie.

I limiti operativi interni, il sistema dei controlli e le singole scelte di portafoglio devono essere coerenti con le strategie definite dalla banca; essi individuano, in relazione all'attività svolta nel comparto e alle strategie della banca e del gruppo, le altre attività bancarie che possono determinare conflitti d'interesse, e definiscono soluzioni organizzative e di governo societario idonee a prevenire e gestire correttamente detti conflitti.

In questa parte si fa riferimento alla possibilità che sorgano **conflitti di interessi** legati a queste partecipazioni, il che introduce il tema successivo del governo societario. *(pagina 1)*

5.2. Art. 53 TUB, lett. d): il governo societario — evoluzione storica e fonti normative

5.2.1. Il testo della norma

L'art. 53 TUB, alla lettera d), oggi recita:

- d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione

La precedente formulazione della lettera d) si riferiva **esclusivamente** all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni: il governo societario e i sistemi di remunerazione/incentivazione sono state aggiunte successivamente.

5.2.2. Evoluzione storica della vigilanza sull'organizzazione interna

Per valutare l'organizzazione interna di una banca, inizialmente le vecchie disposizioni di vigilanza prevedevano come unico strumento un **questionario** (nota a margine: in questo questionario erano presenti una serie di domande relative all'organizzazione della banca) che le banche dovevano compilare e inviare a Banca d'Italia (BI) una volta ogni due anni; successivamente BI avrebbe espresso una valutazione da 1 a 5.

Le due modifiche più importanti alle disposizioni di vigilanza sono avvenute: - nel **1998**, con l'introduzione di un apposito capitolo dedicato ai controlli interni delle banche; - in attuazione dell'**accordo di Basilea III**, con il quale sono state aggiunte una serie di norme relative alla governance che integrano quelle previste dal diritto comune.

5.2.3. Fonti attuali

Attualmente le norme che disciplinano il governo societario sono prevalentemente di **matrice europea**, in particolare il Regolamento 575/2013 UE e le direttive **CRD4** e **CRD5**. Si è preferito il meccanismo delle direttive perché le banche, essendo società, restano pur sempre parzialmente disciplinate dal diritto commerciale, materia non ancora perfettamente armonizzata a livello europeo.

5.2.4. Assenza di una disciplina differenziata per modello organizzativo

Non esiste una disciplina differenziata sulla base del sistema organizzativo adottato dalla banca (**tradizionale, dualistico, monistico**), perché le norme si riferiscono direttamente alle **funzioni** e non al sistema prescelto. Inoltre, se in linea teorica per le discipline non specificate diversamente si applica il diritto comune, alcune previsioni del diritto europeo tendono a rendere gli assetti organizzativi molto diversi da quelli di una società "classica" — un aspetto che dovrebbero tenere bene a mente gli studiosi di diritto commerciale.

Nota a margine (continua a pag. 2): la governance di una banca non è come la governance di una qualunque altra società, e lo stesso discorso vale anche per altri ambiti. Ad esempio, a seguito dell'emergenza covid sono state emanate disposizioni straordinarie che prevedevano, tra le altre cose, delle moratorie sui finanziamenti, e ci si chiedeva se gli interessi andassero pagati o meno. Gli studiosi di diritto commerciale affermavano che gli interessi non andassero pagati, appellandosi all'aspetto solidaristico, ma la banca, in quanto società, ha bisogno di quegli interessi.

(pagina 1-2)

5.3. Circolare 285 — Premessa: finalità e struttura del Capitolo sul governo societario

Riferimento normativo: **Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza)**, Parte I (Recepimento in Italia della CRD4), Titolo IV (Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi), **Capitolo 1** (governo societario), **Sezione I** (Disposizioni preliminari e principi generali), Premessa.

Efficaci assetti organizzativi e di governo societario costituiscono per tutte le imprese condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali; per le banche essi assumono particolare rilievo in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria e degli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte dell'ordinamento. (...) Le disposizioni di questo capitolo, coerenti con l'evoluzione delle regole, dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale ed europeo, disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale; esse formano parte integrante di un più ampio sistema normativo riguardante altri aspetti rilevanti dell'organizzazione e del governo societario, quali, ad esempio, i controlli sugli assetti proprietari e sulle modificazioni statutarie, il sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi, i requisiti degli esponenti aziendali, le operazioni con parti correlate e più in generale i conflitti di interesse, la disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché gli obblighi di disclosure verso gli investitori e il mercato e la disciplina speciale prevista per le società quotate e per le attività e i servizi di investimento.

In questa prima parte della premessa si specifica subito che assetti organizzativi efficaci sono essenziali per il perseguimento degli obiettivi aziendali, e si richiamano gli interessi pubblici presi in considerazione dall'ordinamento. Si ha poi un richiamo a regole e principi elaborati sia a livello internazionale (Basilea III) sia a livello europeo (CRD4 e CRD5).

Le disposizioni di questo capitolo si articolano in principi generali e linee applicative. I primi, attraverso norme di carattere generale, fissano gli obiettivi della disciplina rimettendo all'autonomia degli intermediari la concreta individuazione delle soluzioni più idonee a realizzarli, secondo criteri di proporzionalità che tengono conto della dimensione o della complessità della banca (cfr. par. 4.1 della presente Sezione). Le linee applicative agevolano, su alcuni aspetti specifici della materia, l'attuazione delle norme generali, senza esaurirne il contenuto precettivo; esse sono calibrate sulle caratteristiche organizzative e operative delle diverse tipologie di banche.

Le disposizioni del capitolo si dividono quindi in: - **principi generali**: fissano gli obiettivi rimettendo agli intermediari le modalità di attuazione, secondo un criterio di **proporzionalità**; - **linee applicative**: agevolano l'attuazione delle norme generali su aspetti specifici, senza esaurirne il contenuto precettivo. (pagina 2-3)

5.4. Definizioni: organo di supervisione strategica, di gestione e di controllo

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, Definizioni.

Organo con funzione di controllo o organo di controllo: a seconda del modello di amministrazione e controllo, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione.

Organo con funzione di gestione: l'organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica; il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione.

Organo con funzione di supervisione strategica: l'organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della società).

Nelle definizioni emerge quanto già detto: si ragiona per **organo** (in base alla funzione svolta) e non per **sistema** adottato dalla banca (tradizionale, dualistico, monistico). Le tre funzioni — supervisione strategica, gestione, controllo — possono essere attribuite a organi diversi o coincidere a seconda del modello societario, ma la disciplina si applica sempre a quelle funzioni.

(pagina 3)

5.5. Sezione II — Scelta del sistema di amministrazione e controllo e progetto di governo societario

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, **Sezione II** (Sistemi di amministrazione e controllo e progetto di governo societario), Principi generali.

In linea teorica non sussiste un'univoca corrispondenza tra le caratteristiche di ciascun modello di amministrazione e controllo e quelle strutturali e operative di ciascuna impresa. Le banche esercitano la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo sulla base di un'approfondita autovalutazione (...). I modelli monistico e dualistico possono anche rispondere alle esigenze di banche che operano in misura rilevante sui mercati internazionali in cui tali modelli sono maggiormente conosciuti ovvero facenti parte di gruppi in cui sono prevalenti tali forme organizzative. (...) Le motivazioni alla base della scelta del modello di amministrazione e controllo — di competenza dell'assemblea dei soci — devono essere rappresentate nell'ambito di un più generale **progetto di governo societario**, illustrativo degli assetti statutari e di organizzazione interna; il progetto è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, con il parere favorevole dell'organo di controllo.

Con la **riforma del diritto societario del 2003** è stata data alle banche la possibilità di adottare liberamente un sistema a scelta fra quello monistico, dualistico e tradizionale. Molte banche, pensando al fatto che la BCE avesse sede a Francoforte, optarono per il sistema dualistico pensando di “compiacere” la BCE. Un altro motivo per cui molte banche scelsero il modello dualistico fu che con il doppio consiglio (sorveglianza e gestione) potevano essere impiegate più persone.

Attualmente si specifica che, per una banca, la scelta del modello di amministrazione e controllo si basa su un'approfondita autovalutazione, che si esplica tramite la redazione di un **progetto**

di governo societario.

(pagina 3-4)

5.6. Contenuto del progetto di governo societario e deroga per le BCC

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione II, Linee applicative.

Il progetto di governo societario deve: a) illustrare le ragioni che rendono il modello prescelto il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli; b) descrivere le specifiche scelte attinenti alla struttura organizzativa (...); c) fornire, nel caso della capogruppo (...); d) essere redatto e inviato alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia in fase di costituzione della banca, contestualmente alla relativa istanza di autorizzazione, nonché in occasione della modificazione del sistema di amministrazione e controllo adottato, unitamente alla richiesta di accertamento relativa alla modifica statutaria.

In questa parte si specifica cosa debba contenere il progetto di governo societario: motivazione della scelta del modello, struttura organizzativa, elementi specifici per la capogruppo, e modalità/tempi di trasmissione all'autorità di vigilanza.

Le banche di credito cooperativo non sono tenute alla predisposizione del progetto di governo societario qualora adottino lo statuto tipo predisposto dall'associazione di categoria o dalla capogruppo, nel caso di gruppi bancari cooperativi, vagliato dalla Banca d'Italia.

La procedura è quindi **semplificata** nel caso delle BCC (banche di credito cooperativo).

(pagina 4)

5.7. Sezione III — Compiti e poteri degli organi sociali

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, **Sezione III** (Compiti e poteri degli organi sociali).

5.7.1. Disposizioni comuni

Compiti e poteri di amministrazione e di controllo devono essere ripartiti in modo chiaro ed equilibrato tra i diversi organi e all'interno di ciascuno di essi, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna.

Viene appositamente specificato che i compiti devono essere ripartiti in modo chiaro ed equilibrato fra i diversi organi, evitando concentrazioni di poteri.

5.7.2. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione — principi generali

Un sistema di governo societario efficiente, basato sul principio del bilanciamento dei poteri, richiede che, nel caso in cui le funzioni di supervisione strategica e di gestione vengano attribuite a organi diversi, siano chiaramente individuati e distinti i compiti e le responsabilità dei due organi, il primo chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca e a verificarne nel continuo l'attuazione, il secondo responsabile dell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale.

Si ha un richiamo esplicito al **modello dualistico** (consiglio di sorveglianza / consiglio di gestione).

5.7.3. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione — linee applicative

- a) Gli organi aziendali devono assicurare il governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche, i necessari presidi (...); b) L'organo con funzione di supervisione strategica definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze (...); d) Il contenuto delle deleghe nell'ambito dell'organo con funzione di gestione deve essere determinato in modo analitico ed essere caratterizzato da chiarezza e precisione, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio.

(Queste linee applicative sono state lette a campione e molto velocemente durante la lezione).

(pagina 4-5)

5.8. Sezione IV — Composizione e nomina degli organi sociali: principi generali

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, **Sezione IV** (composizione e nomina degli organi sociali), Principi generali.

Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo siano presenti soggetti: - pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione, di gestione o di controllo; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.); - dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni all'organo, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca; - con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra

l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca; - che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169; - che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

Si specifica quindi che i soggetti debbano essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi delle funzioni che sono chiamati a svolgere, dotati di professionalità adeguata al ruolo, con competenze diffuse e diversificate, tempo e risorse adeguate (nel rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi), e devono operare con autonomia di giudizio nell'interesse complessivo della banca.

(pagina 5)

5.9. Comitati endo-consiliari: nomine, rischi, remunerazioni

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, **Comitati endo-consiliari**.

5.9.1. Disposizioni comuni

Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa (...)

Il termine “**endo-consiliari**” si riferisce al fatto che i comitati non sono costituiti da altre persone, ma da consiglieri che vi prendono parte distribuendosi il carico di lavoro. Viene appositamente specificato come la creazione di questi comitati riguardi solo le banche di maggiori dimensioni.

5.9.2. Comitato nomine

Il comitato svolge funzioni di supporto agli organi con supervisione strategica e di gestione nei seguenti processi: nomina o cooptazione dei consiglieri, (...)

Si tratta di un comitato specifico che, fra le altre cose, supporta l'organo preposto alla **cooptazione** dei consiglieri (nota a margine: la cooptazione è il metodo attraverso cui avviene la selezione e l'elezione dei nuovi membri di un organo collegiale). Si hanno delle deroghe rispetto alle norme di diritto societario comune: il vaglio preventivo dei soggetti che potranno in seguito essere cooptati spetta proprio a questo comitato, che valuterà, in via preventiva, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, etc.

5.9.3. Comitato rischi

Il comitato rischi svolge funzioni di supporto all'organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni e: individua e propone, avvalendosi del contributo del comitato nomine, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare; esamina preventivamente i programmi di attività (compreso

il piano di audit) e le relazioni annuali delle funzioni aziendali di controllo indirizzate all'organo; esprime valutazioni e formula pareri all'organo sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni.

Si tratta del comitato con le maggiori responsabilità; svolge diverse funzioni fra cui il supporto all'organo con funzione di supervisione strategica e l'esame dei programmi di attività.

5.9.4. Comitato remunerazioni

Per i compiti del comitato remunerazioni si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione delle banche.

Questo comitato si occupa delle remunerazioni all'interno delle banche. *(pagina 6-7)*

5.10. Sezione V — Funzionamento degli organi, flussi informativi e ruolo del presidente

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, **Sezione V** (funzionamento degli organi, flussi informativi e ruolo del presidente).

5.10.1. Funzionamento degli organi e flussi informativi

Il funzionamento corretto ed efficiente degli organi richiede non solo una composizione adeguata secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi, ma anche la predisposizione di flussi informativi, procedure, metodi di lavoro, tempistiche delle riunioni, altrettanto adeguati. Assumono quindi particolare rilievo l'individuazione e la formalizzazione di prassi operative (procedure di convocazione, periodicità e durata delle riunioni, partecipazione) che assicurino effettività e tempestività all'azione degli organi e dei loro comitati.

Anche in questo caso si richiama una composizione degli organi adeguata, così come devono essere adeguatamente predisposti flussi informativi, procedure, metodi di lavoro, etc.

5.10.2. Ruolo del presidente — principi generali

Il presidente del consiglio di amministrazione svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri.

5.10.3. Ruolo del presidente — linee applicative

- a) Il presidente del consiglio di amministrazione garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti.

Si riprende il concetto per cui gli esponenti aziendali debbano essere ben informati prima di prendere decisioni e astenersi/rifiutarsi di farlo laddove ritengano di non avere tutte le informazioni necessarie. Non si tratta solo di “principi”, ma di vere e proprie norme con possibili ripercussioni anche sul piano penale.

Nota a margine: il presidente convoca il CdA per votare, ma deve essere sicuro che ci siano le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole; questo può avvenire inviando flussi informativi regolari agli organi aziendali. *(pagina 7–8)*

5.11. Capitolo 3, Sezione I — Il sistema dei controlli interni: definizione, finalità e principio di proporzionalità

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, **Capitolo 3** (il sistema dei controlli interni), **Sezione I** (Disposizioni preliminari e principi generali), Premessa.

Il sistema dei controlli interni è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle banche; esso assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione. Le presenti disposizioni definiscono i principi e le linee guida cui il sistema dei controlli interni delle banche si deve uniformare; in quest'ambito, sono definiti i principi generali di organizzazione, indicati il ruolo e i compiti degli organi aziendali, delineate le caratteristiche e i compiti delle funzioni aziendali di controllo. (...) Le banche applicano le disposizioni secondo il principio di proporzionalità, cioè tenuto conto del profilo di rischio della banca, della dimensione e complessità operative, della natura dell'attività svolta, della tipologia dei servizi prestati.

Il sistema dei controlli interni (SCI) viene definito come un elemento fondamentale, necessario ad assicurare che l'attività aziendale risulti in linea con le strategie e le politiche aziendali. Si riprende il **principio di proporzionalità**.

La presente disciplina: rappresenta la cornice generale del sistema dei controlli aziendali; forma parte integrante del complesso di norme concernenti gli assetti di governo e controllo delle banche.

Non si tratta di un elenco esaustivo, ma di regole minime: il sistema dei controlli interni deve occuparsi **almeno** di questi due aspetti, venendo integrato successivamente dalle specifiche disposizioni previste in materia.

I presidi relativi al sistema dei controlli interni devono coprire ogni tipologia di rischio aziendale. La responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali deve essere chiaramente definita e formalizzata.

Si specificano quindi tre elementi fondamentali: (i) tutti i rischi devono essere adeguatamente coperti; (ii) le responsabilità sono rimesse agli organi competenti; (iii) la divisione dei compiti e delle responsabilità deve essere definita chiaramente. *(pagina 8–9)*

5.12. Le finalità del sistema dei controlli interni e il suo ruolo centrale nell'organizzazione

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I, Premessa.

5.12.1. Finalità

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità: verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali; contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (**Risk Appetite Framework – “RAF”**); salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; efficacia ed efficienza dei processi aziendali; affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche; prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo); conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Da notare come fra le finalità esplicitamente richiamate ci sia il coinvolgimento, anche indiretto, in attività illecite (come ad esempio il riciclaggio — nota a margine: questa è l'unica norma di diritto bancario a richiamare espressamente questa disciplina) e il concetto di “**conformità**” (sostanzialmente la traduzione di “compliance”) delle operazioni con la legge, che fa riferimento a una delle funzioni più importanti e innovative.

5.12.2. Ruolo centrale nell'organizzazione

Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione aziendale: rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni; orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo; presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale; favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali. Per queste caratteristiche, il sistema dei controlli interni ha rilievo strategico; la cultura del controllo deve avere una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali: non riguarda solo le funzioni aziendali di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale), nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per identificare, misurare, comunicare, gestire i rischi.

5.12.3. Requisiti generali per realizzare l'obiettivo

Per poter realizzare questo obiettivo, il sistema dei controlli interni deve in generale: assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), l'affidabilità del processo di gestione dei rischi e la sua coerenza con il RAF; prevedere attività di controllo diffuse a ogni segmento operativo e livello gerarchico; garantire che le anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'impresa (agli organi aziendali, se significative) in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi; incorporare specifiche procedure per far fronte all'eventuale violazione di limiti operativi; assicurare che il personale sia portato a conoscenza delle componenti del sistema dei controlli interni e delle principali politiche (in particolare, la politica di compliance), nonché delle modifiche sostanziali a esse apportate.

(pagina 9–10)

5.13. Le tre tipologie di controllo: primo, secondo e terzo livello

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I, Premessa. A prescindere dalle strutture dove sono collocate, si individuano tre tipologie di controllo.

5.13.1. Controlli di linea (controlli di primo livello)

Controlli di linea (c.d. “controlli di primo livello”), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del back office; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche.

I controlli di linea sono volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Questo obiettivo può essere raggiunto tramite procedure informatizzate oppure tramite unità dedicate o addetto al back office (esempio: il responsabile di filiale preposto che a fine giornata svolge un'analisi delle operazioni realizzate per verificare che siano state svolte correttamente e/o non vi siano insoluti).

5.13.2. Controlli sui rischi e sulla conformità (controlli di secondo livello)

Controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. “controlli di secondo livello”), che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro: a) la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi; b) il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni; c) la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

Questi controlli non possono essere affidati agli stessi soggetti che svolgono i controlli di primo livello. I controlli sui rischi e sulla conformità si occupano del controllo sui rischi (attività di **risk management**) e dei controlli di conformità (**compliance** — nota a margine: dove si parla di autoregolamentazione ci si riferisce al rispetto anche delle circolari interne) su tutti i livelli (esempio: presentazione di un nuovo prodotto → chiedere alla compliance).

5.13.3. Revisione interna (controlli di terzo livello)

Revisione interna (c.d. “controlli di terzo livello”), volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l’affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo (ICT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all’intensità dei rischi.

L’attività di revisione interna (in inglese, **internal audit** — nota a margine: questa funzione inizialmente veniva definita di “ispettorato interno”) è volta a identificare eventuali violazioni delle procedure e della regolamentazione a tutti i livelli, nonché a valutare periodicamente l’affidabilità dell’intero sistema dei controlli interni (nota a margine: funzione di carattere preventivo).

(pagina 10–11)

5.14. Principi generali di organizzazione: separatezza delle funzioni e gestione delle risorse umane

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I, Premessa.

Inoltre, le banche rispettano i seguenti principi generali di organizzazione: i processi decisionali e l’affidamento di funzioni al personale sono formalizzati e consentono l’univoca individuazione di compiti e responsabilità e sono idonei a prevenire i conflitti di interessi. In tale ambito, deve essere assicurata la necessaria **separatezza** tra le funzioni operative e quelle di controllo; le politiche e le procedure di gestione delle risorse umane assicurano che il personale sia provvisto delle competenze e della professionalità necessarie per l’esercizio delle responsabilità a esso attribuite.

(pagina 11)

5.15. Sezione II — Il ruolo degli organi aziendali nel sistema dei controlli interni (RAF)

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, **Sezione II** (Il ruolo degli organi aziendali).

5.15.1. Premessa: il Risk Appetite Framework (RAF)

Le banche assicurano la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità del sistema dei controlli interni. In tale ambito, formalizzano il quadro di riferimento

per la determinazione della propensione al rischio (**Risk Appetite Framework – “RAF”**), le politiche di governo dei rischi, il processo di gestione dei rischi, ne assicurano l'applicazione e procedono al loro riesame periodico per garantirne l'efficacia nel tempo. La responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze.

Si specifica che le banche debbano predisporre il **Risk Appetite Framework (RAF)**, ovvero un provvedimento che determina le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione degli stessi.

5.15.2. Organo con funzione di supervisione strategica

L'organo con funzione di supervisione strategica: **definisce e approva**: a. il modello di business avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati; b. gli indirizzi strategici e provvede al loro riesame periodico, in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo; c. gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi; (...) **approva**: a. la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali; b. il processo di gestione del rischio e ne valuta la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi; (...) **assicura che**: a. la struttura della banca sia coerente con l'attività svolta e con il modello di business adottato, evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative; b. il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale siano costantemente uniformati ai principi indicati nella Sezione I e che le funzioni aziendali di controllo possiedano i requisiti e rispettino le previsioni della Sezione III; (...).

Bisogna notare come cambiano i verbi in relazione a cosa fa l'organo con funzione di supervisione strategica: si usa “**definisce e approva**”, “**approva**” e “**assicura**” — una gradazione che riflette diversi gradi di coinvolgimento e responsabilità.

5.15.3. Organo con funzione di gestione

L'organo con funzione di gestione ha la comprensione di tutti i rischi aziendali, inclusi i possibili rischi di malfunzionamento dei sistemi interni di misurazione (c.d. “**rischio di modello**”), e, nell'ambito di una gestione integrata, delle loro interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno. In tale ambito, è in grado di individuare e valutare i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la banca.

5.15.4. Organo con funzione di controllo

L'organo con funzione di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del RAF.

5.15.5. Il coordinamento delle funzioni di controllo

Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni si basa sulla proficua interazione nell'esercizio dei compiti (d'indirizzo, di attuazione, di verifica, di valutazione) fra gli organi aziendali, gli eventuali comitati costituiti all'interno di questi ultimi, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, le funzioni di controllo.

(pagina 11-13)

5.16. Sezione III — Istituzione delle funzioni aziendali di controllo ed esternalizzazione

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, **Sezione III** (Funzioni aziendali di controllo), Istituzione delle funzioni aziendali di controllo.

Ferma restando l'autonoma responsabilità aziendale per le scelte effettuate in materia di assetto dei controlli interni, le banche **istituiscono**, secondo quanto di seguito indicato, funzioni aziendali di controllo permanenti e indipendenti: i) di conformità alle norme (compliance); ii) di controllo dei rischi (risk management); iii) di revisione interna (internal audit). Per assicurare l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo: (...)

Viene usato l'indicativo ("istituiscono") perché non si tratta di una facoltà opzionale: in ogni banca devono essere sempre presenti le funzioni di **compliance**, **risk management** e **internal audit**.

Alcune funzioni sono tuttavia **esternalizzabili**: le banche più piccole di solito non hanno abbastanza personale da poter dedicare allo svolgimento di queste funzioni (e non potrebbero neanche permetterselo in termini di costi da sostenere), per cui le affidano a soggetti esterni. Ci sono aspetti positivi e negativi derivanti dall'esternalizzazione: - **aspetti positivi**: i soggetti a cui vengono affidati questi compiti sono probabilmente molto esperti in materia e sarebbero più efficienti del personale di una banca; - **aspetti negativi**: un soggetto esterno non tiene conto della singola realtà aziendale; per lui ogni banca è solo "numeri".

Nelle BCC i controlli di terzo livello sono quasi sempre esternalizzati e affidati alla capogruppo.

(pagina 13)

5.17. Requisiti specifici delle funzioni aziendali di controllo: compliance, risk management, internal audit

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione III, Requisiti specifici delle funzioni aziendali di controllo.

5.17.1. Funzione di conformità alle norme (compliance)

Il **rischio di non conformità alle norme** è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina). Poiché il rischio di non conformità alle norme è diffuso a tutti livelli dell'organizzazione aziendale, soprattutto nell'ambito delle linee operative, l'attività di prevenzione deve svolgersi in primo luogo dove il rischio viene generato: è pertanto necessaria un'adeguata responsabilizzazione di tutto il personale.

I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono:

- l'ausilio alle strutture aziendali per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di non conformità alle norme;
- l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio rilevato, con possibilità di richiederne l'adozione;
- la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- l'identificazione nel continuo delle norme applicabili alla banca e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali; (...).

Ferme restando le responsabilità della funzione di compliance per l'espletamento dei compiti previsti da normative specifiche (quali, ad es., le discipline in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti e di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati), altre aree di intervento sono: il coinvolgimento nella valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi nell'ambito del relativo processo di approvazione, secondo quanto previsto nella Sezione II, paragrafo 3) che la banca intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse sia tra le diverse attività svolte dalla banca, sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali.

Questa è la definizione di **rischio di compliance**.

5.17.2. Funzione di controllo dei rischi (risk management)

La funzione di controllo dei rischi ha la finalità di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.

La compliance si occupa dei profili giuridici e aziendalistici, mentre il risk management è

maggiormente di tipo quantitativo. Tutti i controlli interni sono comunque coordinati fra loro.

5.17.3. Funzione di revisione interna (internal audit)

In tale ambito, coerentemente con il piano di audit, la funzione di revisione interna: verifica, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva: a. la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella direzione generale della banca, sia nelle filiali. La frequenza delle ispezioni è coerente con l'attività svolta e la propensione al rischio; tuttavia sono condotti anche accertamenti ispettivi casuali e non preannunciati; b. il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali; c. il rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega, e il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività; (...).

(pagina 13-14)

5.18. Capitolo 2 — Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, **Capitolo 2** (Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione), Sezione I (Disposizioni di carattere generale).

5.18.1. Fonti normative

Le presenti disposizioni sono adottate sulla base degli articoli 53 e 67 del Testo Unico Bancario (TUB). Esse danno attuazione alla direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (di seguito, CRD, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, c.d. **CRD V**) relativamente alle previsioni in essa contenute in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, e tengono conto degli indirizzi e dei criteri concordati in sede internazionale, tra cui quelli dell'**EBA** e dell'**FSB**. I sistemi di remunerazione e incentivazione devono essere in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema finanziario nel suo complesso. Nel loro insieme, le best practices e gli orientamenti espressi in ambito internazionale costituiscono indirizzi e criteri interpretativi utili per il corretto recepimento delle disposizioni da parte delle banche (...).

Per la disciplina relativa ai sistemi di remunerazione e incentivazione bisogna far riferimento prevalentemente alla disciplina europea, non soltanto al Regolamento 575/2013 e alla CRD4, ma anche alle linee guida emanate dall'EBA. Si fa riferimento anche all'importanza delle best practices e degli orientamenti espressi in ambito internazionale.

5.18.2. Principi e criteri generali

Adeguati meccanismi di remunerazione e di incentivazione dei consiglieri e del management della banca possono favorire la competitività e il buon governo delle imprese bancarie. La remunerazione, in particolare di coloro che rivestono ruoli rilevanti all'interno dell'organizzazione aziendale, tende ad attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa. Al contempo, i sistemi retributivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi e i valori aziendali, ivi inclusi gli obiettivi di finanza sostenibile che tengono conto, tra l'altro, dei fattori ambientali, sociali e di governance (**ESG**), e con le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca, ivi comprese le strategie di monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati, coerentemente con quanto definito nell'ambito delle disposizioni sul processo di controllo prudenziale.

In particolare, le forme di retribuzione incentivante, basate su strumenti finanziari (es. **stock option**) o collegate alla performance aziendale, devono essere coerenti con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (ad es., Risk Appetite Framework – “RAF”) e con le politiche di governo e di gestione dei rischi; esse devono tenere inoltre conto del costo e del livello del capitale e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese ed essere strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo periodo.

Nella prospettiva di evitare possibili aggiramenti delle presenti disposizioni, le banche assicurano che il proprio personale non sia remunerato o non riceva pagamenti o altri benefici tramite veicoli, strumenti o modalità comunque elusive delle presenti disposizioni, con riguardo, in caso di gruppo, anche alle succursali e filiazioni estere (ovunque insediate). Le banche richiedono al proprio personale, attraverso specifiche pattuizioni, di non avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla retribuzione o su altri aspetti che possano alterare (...)

(Il testo si interrompe qui: l'ultima pagina disponibile termina a metà frase, riguardo al divieto per il personale di alterare, tramite strategie di copertura personale o assicurazioni, gli effetti di allineamento al rischio previsti dai meccanismi di remunerazione.) (pagina 14-15)

6 | Vigilanza regolamentare: i poteri di intervento della Banca d'Italia (art. 53-bis TUB)

Fonte: LEGB2_Appunti_06_Vigilanza-Regolamentare-Poteri-di-Intervento.pdf — 3 pagine

6.1. Circolare 285: sistema informativo e continuità operativa (cenni conclusivi sul governo societario)

Chiude la trattazione dei sistemi di remunerazione e incentivazione una precisazione: tali sistemi non sono di per sé uno strumento dannoso, anzi favoriscono lo sviluppo della competitività all'interno del sistema bancario. Resta però fermo il divieto, per i soggetti interessati da questi sistemi, di avvalersi di strategie o forme di copertura personale che possano vanificare (“inficiare”) gli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi retributivi.

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte I (Recepimento in Italia della CRD4), Titolo IV (Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi), Capitolo 4 — Il sistema informativo. A seguito del forte sviluppo della tecnologia, la Banca d'Italia (BI) ha avvertito la necessità di regolamentare anche il sistema informativo delle banche. Il capitolo contiene una serie di regole che le banche devono seguire per minimizzare il rischio informatico. Anche in questo ambito è prevista la redazione di un piano, che deve essere predisposto dagli organi competenti e successivamente approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica. Presidiare in via preventiva queste tipologie di rischio è ritenuto essenziale.

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte I (Recepimento in Italia della CRD4), Titolo IV (Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi), Capitolo 5 — La continuità operativa. Il capitolo tratta la continuità operativa, da intendersi come corollario di un corretto utilizzo del sistema informativo. *(pagina 1)*

6.2. Art. 53-bis TUB: origine, finalità e principio di proporzionalità dei poteri di intervento

Origine della norma. In attuazione della CRD4, il comma 3 dell'art. 53 TUB (relativo agli interventi di BI di carattere specifico) è divenuto un articolo a sé stante: l'art. 53-bis TUB. In

precedenza l'articolo specificava esplicitamente una serie di obiettivi che oggi non sono più citati nel testo di legge, ma che restano comunque validi come finalità sottese ai poteri di intervento:

- garantire la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, sanando eventuali gestioni aziendali problematiche¹;
- garantire il rispetto della normativa vigente;
- prevenire eventuali deterioramenti tecnici².

Il principio di proporzionalità. Vigè tuttora il principio per cui gli interventi di BI devono essere proporzionali rispetto alla valutazione complessiva della banca in questione. Nell'esercizio dei propri poteri, BI deve tenere conto di elementi:

- di natura **oggettiva**: gli strumenti affidati a BI sono molteplici, ma occorre individuare quale sia il più adatto al caso concreto;
- di natura **soggettiva**: la scelta dello strumento va rapportata anche alla banca su cui verrà usato, basandosi sulle capacità dimostrate dagli esponenti aziendali nel corso degli anni e sulle loro potenziali abilità "ricettive" (cioè la capacità di recepire e dare seguito alle indicazioni di vigilanza).

La scala di valutazione BI (punteggio da 1 a 4) e la gradualità degli interventi. BI, tramite proprie valutazioni, attribuisce a ogni banca un punteggio che va da 1 a 4. Gli interventi devono essere proporzionati a tale punteggio:

- **Punteggio 1 o 2**: BI si limita solitamente ad atti di *moral suasion* (sotto forma di "chiacchiere") oppure all'invio di lettere nelle quali vengono fatte emergere le anomalie rilevate, invitando la banca ad agire per risanare la situazione³. Questi interventi sono considerati di vigilanza "leggera" e non trovano un riscontro normativo specifico: nulla vieta a BI di inviare lettere (la libertà di corrispondenza è peraltro un principio sancito anche a livello costituzionale) o di approcciarsi verbalmente agli esponenti aziendali.
- **Punteggio più elevato (ad es. 3)**: con un punteggio pari a 4 sarebbe probabilmente già in atto una liquidazione coatta amministrativa; con un punteggio pari a 3, invece, BI necessita di strumenti più forti e incisivi — quelli sanciti e descritti dall'art. 53-bis TUB.

(pagina 1-2)

6.3. Art. 53-bis, comma 1: i poteri di intervento specifico di BI (lettere a-e)

Il comma 1 dell'art. 53-bis TUB elenca i poteri che la Banca d'Italia può esercitare nei confronti delle banche vigilate.

¹Se nell'ambito della vigilanza informativa/ispettiva emergessero dei problemi, BI ha l'obbligo di intervenire adottando provvedimenti che sanino queste anomalie.

²Da notare come si tratti, in tutti e tre i casi, di interventi di carattere preventivo.

³Il termine *invita* non è usato casualmente: quando BI *invita* una banca, la sta di fatto obbligando; se invece *prega* una banca di fare qualcosa, le sta chiedendo di fare qualcosa a titolo di "favore" (ad esempio si può pregare una banca di compilare un questionario).

a) Convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche. Questa lettera introduce una deroga rispetto al diritto comune: nelle società sottoposte alla disciplina ordinaria, il CDA può essere convocato esclusivamente dal presidente del CDA o da un tribunale (su richiesta di un certo numero di soci che rappresentino una determinata percentuale del capitale sociale), ma non da BI. La norma in esame attribuisce invece a BI la possibilità di convocare non solo i singoli soggetti menzionati (amministratori, sindaci) ma anche gli organi collegiali nel loro complesso. A seguito della CRD4 è stata inoltre aggiunta la possibilità, per BI, di convocare anche il personale.

b) Ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni. BI può, ad esempio tramite l'invio di una lettera, ordinare la convocazione degli organi, fissarne l'ordine del giorno e proporre l'assunzione di determinate decisioni. Esempio: nel caso di una banca ritenuta ormai incapace di sopravvivere in autonomia — non esistendo più la fusione coatta come strumento di intervento — BI può ordinare la convocazione del CDA fissando come ordine del giorno il progetto di fusione con una determinata banca.

c) Procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche, quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b). Se gli organi non danno seguito a quanto richiesto ai sensi della lettera b) (ad esempio ignorano la lettera con cui veniva richiesta la convocazione del CDA), BI può procedere direttamente alla convocazione dei suddetti organi.

d) Adottare, per le materie indicate nell'art. 53 comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario, riguardanti anche: - la restrizione delle attività o della struttura territoriale; - il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio; - con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; - la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; - per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la possibilità di fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.

BI può quindi adottare, per le materie già previste dall'art. 53 comma 1 (misure generali), provvedimenti specifici nei confronti di una singola banca. Per non falsare la competizione all'interno del sistema, questi interventi devono sempre essere adeguatamente motivati e possono essere adottati solo in chiave restrittiva. Il testo originario dell'articolo era molto più sintetico: a seguito della CRD4 sono stati aggiunti esempi concreti degli ambiti a cui questa modalità di intervento può riferirsi.

e) Disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza di provvedere. Questa lettera, particolarmente innovativa, è stata introdotta nel 2015 a seguito della CRD4: introduce il c.d. potere di

removal, ovvero il potere di rimozione degli esponenti aziendali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa. La rimozione può riguardare il singolo o più esponenti, ma non l'intero organo⁴. È presente un apposito richiamo all'art. 26 TUB: non è necessario disporre la rimozione se sono venuti meno i requisiti previsti dall'art. 26 TUB (onorabilità, professionalità, ecc.), salvo che non sussista urgenza di provvedere. Questa norma sancisce, per certi versi, un cambio nella filosofia dell'esercizio della vigilanza: il potere di *removal* viene infatti esercitato da BI secondo principi di discrezionalità amministrativa nei confronti di quei soggetti che BI non ritiene adeguati, anche qualora essi possiedano tutti i requisiti previsti dalla legge⁵. (pagina 2-3)

6.4. Art. 53-bis, comma 2: estensione del potere di convocazione ai soggetti che ricevono funzioni esternalizzate

Ai sensi del comma 2, la Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

Il potere di BI di convocare personale viene così esteso anche a soggetti terzi che normalmente non sarebbero sottoposti all'attività di vigilanza, ma che svolgono per conto della banca funzioni essenziali o importanti affidate in outsourcing. (pagina 3)

⁴In linea teorica BI potrebbe anche rimuovere l'intero organo, ma dovrebbe farlo con un apposito provvedimento per ciascuno degli esponenti; nella disciplina della liquidazione straordinaria si prevede invece la possibilità di rimuovere l'organo in blocco.

⁵Per certi versi si va anche a ridurre la libertà dell'imprenditore, non lasciandolo completamente libero di scegliere gli esponenti aziendali.

7 | La Vigilanza Ispettiva

Fonte: LEGB2_Appunti_07_Vigilanza-Ispettiva.pdf — 9 pagine

7.1. Introduzione: la vigilanza ispettiva

L'ultima forma di vigilanza che rimane da analizzare, dopo la vigilanza regolamentare e quella informativa, è quella **ispettiva**. Questa forma di vigilanza si caratterizza per un maggiore potere autoritativo delle autorità di vigilanza, ma affinché possa funzionare bene è necessario che sia fortemente integrata anche con le altre forme di vigilanza (regolamentare e informativa).

Non ci sono stati grandi cambiamenti nel TUB rispetto alla precedente legge bancaria a livello contenutistico, anche se alcuni mutamenti linguistici sono particolarmente significativi, come si vedrà nell'analisi dell'art. 54 TUB. (pagina 1)

7.2. Art. 54 TUB, comma 1: il potere ispettivo di Banca d'Italia

Art. 54 TUB, comma 1: *“La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.”*

Nonostante questo primo comma sia estremamente sintetico, soltanto qui si fa riferimento all'attività di vigilanza esercitata nei confronti delle banche italiane. Si ha un esplicito riferimento anche alla possibilità di effettuare ispezioni anche presso quei soggetti verso cui sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

Le differenze lessicali rispetto alla precedente legge bancaria sono significative:

- *“Disporre” vs “effettuare”.* Nella precedente legge bancaria si utilizzava l'espressione “Banca d'Italia può **disporre** ispezioni”, lasciando in un qualche modo intendere che questa attività fosse delegabile. Per fugare ogni dubbio, nella nuova formulazione dell'art. 54 si stabilisce che “Banca d'Italia può **effettuare** ispezioni”: il legislatore ha quindi preferito mettere in chiaro che l'attività ispettiva non può essere delegata in alcun modo e può essere svolta soltanto da BI. *(Non si tratta di un cambiamento superfluo perché esistono Paesi come il Regno Unito in cui la Bank of England non realizza ispezioni perché stringe accordi con società di revisione a cui delega di svolgere anche l'attività ispettiva — a tutti gli effetti un outsourcing.)*

- *“Funzionari” vs “dipendenti”*. Nelle vecchie disposizioni di vigilanza si sanciva che l’attività di vigilanza poteva essere svolta dai **funzionari**; attualmente questa può essere affidata ai **dipendenti**. I funzionari sono caratterizzati da un certo grado (ad esempio quadro o dirigente), mentre con il termine dipendente si fa riferimento a una categoria molto più ampia di soggetti. *(Adesso, come in passato, si creano dentro BI dei gruppi ispettivi, con la differenza che in passato il capogruppo era almeno un funzionario, mentre adesso si prescinde totalmente dal grado.)*
- *Natura non facoltativa dell’attività*. Anche se viene utilizzata l’espressione “può effettuare”, questo non significa che si tratti di un’attività di vigilanza facoltativa: la vigilanza ispettiva è infatti al pari delle altre attività di vigilanza. Il verbo “potere” viene declinato in relazione alla libertà affidata a BI nella determinazione delle tempistiche e delle modalità con cui effettuare le ispezioni. BI è libera nella determinazione delle modalità di accertamento.

Per la determinazione delle modalità concrete attraverso cui svolgere l’attività ispettiva, BI si avvaleva (e si avvale tutt’ora) della **“Guida per l’attività ispettiva”**, cioè un documento riservato i cui contenuti non erano noti all’infuori di BI stessa; attualmente però tutta questa segretezza è venuta meno ed è aumentata la trasparenza verso l’esterno in merito ad alcuni aspetti.

(pagina 1–2)

7.3. Tipologie di ispezioni: la classificazione tradizionale

Secondo i vecchi schemi le ispezioni venivano distinte in due macrocategorie (normalmente combinate come periodiche-generale e straordinarie-settoriali):

- **Ispezioni periodiche e ispezioni straordinarie**: tutte le banche sono sottoposte periodicamente ad ispezioni; le banche di dimensioni più piccole (o anche le BCC e le BP) vengono sottoposte ad accertamento ispettivo in media ogni **4 anni**, le banche di maggiori dimensioni ogni **6/7 anni**. Le ispezioni straordinarie sono invece ispezioni realizzate con una cadenza inferiore. Le ispezioni (periodiche o straordinarie che siano), proprio perché vengono svolte a distanza di anni per la stessa banca, possono arrivare a durare anche mesi, per dare modo ai dipendenti di ottenere tutte le informazioni di cui necessitano. Le banche hanno un incentivo a collaborare in queste ispezioni perché “ricevere” un’ispezione è comunque oneroso in termini di tempo e personale che bisogna dedicare ai dipendenti di BI.
- **Ispezioni generali e ispezioni settoriali**: le ispezioni generali mirano a un’analisi delle attività della banca nel suo complesso, mentre quelle settoriali si focalizzano su un certo aspetto. Un tempo le ispezioni erano quasi tutte generali; attualmente è aumentato il numero di ispezioni settoriali, soprattutto per osservare il rispetto (o meno) di normative più delicate, come ad esempio la trasparenza verso clienti o quelle inerenti al riciclaggio. Negli ultimi anni stanno prendendo sempre più piede le attività di **follow up**: se a seguito di un’ispezione BI ha espresso delle costatazioni e ha obbligato la banca in questione a prendere delle misure, è probabile venga organizzata un’ispezione straordinaria per verificare che effettivamente la banca stia agendo come le è stato imposto.

Normalmente le ispezioni periodiche sono di tipo generale, quelle straordinarie invece sono settoriali.

Preavviso: quando le ispezioni sono svolte da BI, questa non fornisce un preavviso su quando potrebbe avvenire; la BCE tende invece a informare preventivamente. In questo caso ricordiamo che, come disposto ai sensi dell'art. 7 TUB, le norme relative alla trasparenza amministrativa si applicano in quanto compatibili. Il motivo per cui BI preferisce l'effetto sorpresa ha perso un po' di significato nel tempo: prima ci si recava subito alla cassa per vedere se ci fossero cose anomale, e se una banca avesse saputo dell'ispezione in anticipo avrebbe agito per evitare di essere scoperta. Siccome attualmente si possono realizzare verifiche sul sistema informatico su cui sono registrate tutte le operazioni, e i soldi cartacei nella cassa sono sempre meno, l'effetto sorpresa ha perso un po' della sua rilevanza. (pagina 2)

7.4. Art. 54 TUB, commi 2-4: la cooperazione con le autorità estere

Comma 2: *“La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.”*

In questo comma si sancisce il principio per cui, pur esistendo l'*home country control*, le autorità di vigilanza devono collaborare fra loro (**principio di leale collaborazione**). BI, invece di recarsi personalmente nel paese comunitario in questione, può richiedere che l'autorità di vigilanza di quel Paese svolga per lei l'attività di vigilanza ispettiva. La locuzione “ovvero concordare altre modalità delle verifiche” si riferisce a quei casi in cui l'Italia necessita di svolgere attività di vigilanza ispettiva in uno di quei paesi in cui la stessa è delegabile (come nel caso della Bank of England, già citato).

Comma 3: *“Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.”*

In questo comma si esprime esattamente lo stesso concetto descritto nel comma precedente ma “rovesciandolo” all'Italia: sono le autorità estere che possono ispezionare succursali di proprie banche stabilite in Italia, previa informazione a BI.

Comma 4: *“A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori.”*

In questo caso si specifica che la collaborazione è facoltativa (“può concordare”) e comunque possibile solo a condizioni di **reciprocità** con il Paese terzo in questione (cioè fuori dall'Unione Europea). (pagina 2-3)

7.5. La prassi operativa: le nuove tipologie di ispezione (disposizioni di vigilanza)

Fonte: Parte III (Altre disposizioni di vigilanza prudenziale), Capitolo 8 (Vigilanza ispettiva), Sezione I (Disposizioni di carattere generale), Premessa.

“Le ispezioni della Banca d’Italia sono volte ad accertare che l’attività dei soggetti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell’osservanza delle disposizioni in materia creditizia. In particolare, l’attività ispettiva è graduata in funzione di caratteristiche, dimensioni e complessità dell’intermediario controllato ed è focalizzata sui rischi rilevanti, sulla governance e sui controlli interni. La frequenza e la tipologia delle ispezioni sono determinate sulla base di una pianificazione annuale e possono essere distinte in:

- *ispezioni a “spettro esteso”, che esaminano la complessiva situazione aziendale;*
- *ispezioni “mirate”, rivolte a determinati settori di attività, aree di rischio o profili gestionali;*
- *ispezioni “tematiche”, riguardanti aspetti di carattere generale rilevanti per l’intero sistema creditizio e finanziario;*
- *ispezioni di “follow-up”, per la verifica dello stato di realizzazione di misure correttive richieste dalla Vigilanza o promosse dagli stessi intermediari;*
- *ispezioni di “compliance”, che verificano il rispetto delle normative in materia di tutela delle relazioni con la clientela, di usura e di contrasto al riciclaggio.*

Ai fini della vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche, i soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata e i soggetti ai quali le une e gli altri abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.”

È importante notare il **cambio di terminologia**: da ispezioni generali a “spettro esteso” e da settoriali a “mirate”, con l’aggiunta delle ispezioni tematiche (categoria che nello schema tradizionale non esisteva). (pagina 3)

7.6. Svolgimento degli accertamenti: soggetti, poteri e fasi dell’ispezione

Fonte: Parte III (Altre disposizioni di vigilanza prudenziale), Capitolo 8 (Vigilanza ispettiva), Sezione II (Disciplina degli accertamenti), Svolgimento degli accertamenti.

“Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d’Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta. Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all’intero patrimonio informativo dell’azienda ispezionata. Gli accertamenti nei confronti di banche o di soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti sono svolti, di norma, presso gli uffici della direzione generale: gli ispettori, qualora lo ritengano necessario ai fini dell’indagine, possono recarsi anche presso le dipendenze insediate sia in Italia sia all’estero.”

All'interno delle disposizioni di vigilanza in realtà non si dice molto sulle modalità attraverso cui viene svolta l'attività di vigilanza ispettiva, ma, come detto, col tempo è aumentata un po' la trasparenza di BI in merito alle prassi adottate. Di seguito le fasi tipiche del processo, ricostruite sulla base della prassi.

1. Pianificazione. Il primo passo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza è svolto dalle autorità di vigilanza che predispongono un **piano ispettivo**; in questo piano si decide chi sono gli intermediari che subiranno un'ispezione e di quale tipo (generale o settoriale). *(Ovviamente il piano può essere rivisto, ad esempio si possono inserire ispezioni straordinarie.)*

2. Conferimento dell'incarico. Successivamente si ha il conferimento dell'incarico al (o ai) dipendente designato per l'ispezione. *(In caso di banca accentrata l'incarico è affidato dal governatore di BI o da un membro del direttorio; in caso di banca decentrata, da una filiale provinciale di BI.)* In caso di ispezioni generali l'incarico è sempre affidato a un gruppo ispettivo e mai a una persona singola. Questo conferimento dell'incarico altro non è che una lettera nella quale si sancisce che il dipendente X andrà a svolgere un'ispezione nella banca Y, ed è a tutti gli effetti un ordine di incarico.

3. Criteri di designazione del personale. Due regole orientative guidano la scelta dei dipendenti da assegnare: - evitare persone che abbiano già dei pregiudizi: si evitano, ad esempio, dipendenti che già svolgano un'attività di vigilanza informativa nei confronti di quella banca; - puntare a un'**eterogeneità delle competenze** nella costituzione del gruppo (una persona con maggiori competenze in ambito legale, un'altra con maggiori competenze nella lettura dei bilanci, ecc.).

Non avere pregiudizi non significa però essere poco informati sulla banca che si andrà a ispezionare: una volta ricevuta la lettera di incarico, il gruppo ispettivo inizia la **fase di pre-ispezione**, nella quale si valutano una serie di documenti (fra cui lo SREP, la valutazione annuale precedente di BI, i rapporti ispettivi precedenti, ecc.).

4. Svolgimento dell'ispezione: criteri modulari. Durante l'ispezione vera e propria si seguono criteri modulari, cioè si analizzano prima una serie di documenti più generici (i verbali delle riunioni del CdA, i verbali delle riunioni del collegio, il registro degli esposti), e poi ci si focalizza su aspetti più quantitativi, come ad esempio i crediti erogati o le attività di investimento. A prescindere da cosa si va ad analizzare nello specifico, bisogna anche tenere a mente l'ambiente in cui si svolge l'ispezione: i dipendenti devono capire se le persone con cui stanno interloquendo siano o meno affidabili.

5. Redazione del rapporto. Quando l'ispezione è stata conclusa si può procedere alla redazione del rapporto ispettivo; per evitare però che le valutazioni delle banche differiscano in relazione a chi svolge l'ispezione, è necessario avere un confronto con il capo dell'amministrazione centrale di BI che si occupa della vigilanza ispettiva.

(pagina 4-5)

7.7. Struttura del rapporto ispettivo

I rapporti ispettivi si dividono in due parti:

- una **parte aperta**, che verrà consegnata alla banca ispezionata, a sua volta divisa in:
 - **costatazioni**, nelle quali vengono fatti emergere veri e propri rilievi che potrebbero portare all'erogazione di sanzioni;
 - **ulteriori osservazioni**, dove sono riportate cose che non costituirebbero sanzioni ma di cui comunque BI vuole informare la banca;
- una **parte chiusa**, che rimane a BI, a sua volta divisa in:
 - **riclassificazione di alcune voci di bilancio e di matrice** (relazioni di carattere tecnico di poche pagine in cui si riportano alcuni schemi che permettono di avere un quadro della banca);
 - un **giudizio sugli esponenti bancari e sulle prospettive della banca**. (*La terminologia è un po' cambiata perché adesso si parla di "considerazioni di sintesi" e "analisi delle risultanze", ma i concetti sono sempre quelli.*)

Per la consegna della parte aperta, BI organizza un'apposita riunione.

Nel rapporto ispettivo la **prima pagina** è dedicata ai dati identificativi della banca: il nome della banca, il codice ABI, la data di inizio e chiusura dell'ispezione e quali sono gli ispettori.

Di seguito si analizzano due rapporti ispettivi reali: uno un po' più datato e uno più recente.

(pagina 5)

7.8. Rapporto Ispettivo N.1 — Parte Aperta: costatazioni

Il primo rapporto analizzato riguarda una banca in gravissima difficoltà, poi commissariata durante lo svolgimento stesso dell'ispezione. Di seguito i passaggi testuali della parte aperta (costatazioni), con il relativo commento esplicativo.

Il contesto e la debolezza strutturale

“In un contesto segnato da forti esternalità di carattere economico-ambientale nonché in presenza di un difficoltoso affermarsi di logiche genuinamente imprenditoriali da parte degli enti di riferimento proprietario, l'evoluzione gestionale della banca si è nel tempo allontanata da sentieri virtuosi per assumere, come già rilevato nel precedente accertamento ispettivo, connotati di crescente debolezza strutturale, da ultimo sfociati in gravi squilibri delle coordinazioni tecniche e nella dispersione del posizionamento sul mercato. Oltre ai richiamati vincoli esterni, la determinante di siffatto stato di cosa, che tra l'altro rende l'azienda possibile di esclusione dal sistema di garanzia dei depositi, va ricondotta alla insufficienze dell'azione svolta dagli Organi amministrativi, direzionali e di controllo cui, sino alle recenti decisioni di ricambio, è stata affidata la conduzione dell'impresa. Da stigmatizzare nell'ordine: (...)”

Si parte subito con le costatazioni e l'approccio adottato da BI è quello di partire dalle questioni più generali (il contesto in cui la banca opera) per poi proseguire con quelle più specifiche inerenti alla situazione della banca. Gli elementi che emergono sono:

1. la **non indipendenza** della banca: le forti esternalità esterne (enti di riferimento proprietario) non sono un fattore positivo; si specifica fin da subito che la banca non è ancora entrata nell'ottica che le banche sono imprese a tutti gli effetti (ci si trovava nella fase di passaggio dalla precedente legge bancaria al TUB), a causa dei soci più forti, e che si sta allontanando da sentieri virtuosi;
2. la **recidiva**: viene appositamente ribadito, per esprimere la gravità della situazione, che questo rilievo era stato fatto emergere anche durante la scorsa ispezione;
3. la **debolezza strutturale**, derivante da gravi squilibri delle coordinazioni tecniche e perdite di quote di mercato. *(L'utilizzo del termine "grave" non è casuale: BI lo utilizza laddove ritiene che la banca potrebbe essere sottoposta a una procedura di liquidazione straordinaria.)*
4. un richiamo alla possibilità di **esclusione dal sistema di garanzia dei depositi**.

La politica allocativa e la gestione dei rischi

“La politica allocativa attuata, dimentica dei principi di prudenza costituiti dal frazionamento e dall'attenta selezione dei rischi, tanto da spingere la concentrazione e il grado di illiquidità del portafoglio prestati al punto da compromettere la stabilità dell'intermediario.”

Si fa riferimento alla scorretta modalità di gestione dei rischi: la banca non ha posto abbastanza attenzione nella selezione dei rischi, finendo per sviluppare un'elevata **concentrazione** in un certo settore (nel caso concreto, il settore degli appalti pubblici), rischiando di compromettere l'intera stabilità dell'intermediario (il problema è legato alla difficoltà di liquidare le posizioni assunte).

Gli indirizzi strategici

“Gli indirizzi strategici perseguiti, frutto di prospettive di breve periodo e volti alla conservazione di schemi tradizionale, pur al cospetto di sollecitazioni di mercato, ad evidenza impicanti: ridefinizione dei moduli produttivi e commerciali per il miglioramento qualitativo, ricerca di nuovo fonti di reddito, dinamiche più tempestive e rigorose nel contenimento dei costi.”

Ancora una volta si accusa la banca di non aver tenuto conto, nel passaggio dalla precedente legge bancaria al TUB, del cambiamento del contesto normativo. Si ha un richiamo all'importanza di una gestione non improntata solo al breve periodo ma anche al medio-lungo termine. *(Al tempo di questo rapporto ispettivo non esisteva ancora l'organo con funzione di supervisione strategica.)*

L'assetto organizzativo

“L'approccio adottato in materia organizzativa, riflesso di processi di mediazione tra istanze sovente particolaristiche, in luogo della realizzazione di un disegno organico. Né è scaturita un'architettura non priva di elementi di incoerenza, spesso pletorica e talvolta carente, fondata sulla frammentazione dei compiti senza l'ausilio di fasi di coordinamento e di trasparenza nei compiti, poco orientata alla vendita, alla valuta-

zione dei risultati, e, soprattutto, scarsamente presidiata sotto il profilo dei controlli interni.”

BI fa riferimento anche alle anomalie riscontrate a livello organizzativo: la confusione interna non rendeva capace di distinguere chi facesse cosa, perché in alcuni ambiti vi era carenza di circolari interne, in altri ve ne erano fin troppe. Visto il richiamo esplicito ai controlli interni, l'internal auditor sarà stato punito severamente.

I coefficienti patrimoniali prudenziali

“Nel merito dei lineamenti tecnici, deve in primo luogo rilevarsi lo sfaldamento della base patrimoniale, quale in chiusura di sopralluogo emerge dal dato netto stimato in sede ispettiva (- 60 mld di Lire) contro un importo di 910 mld di Lire. Le rettifiche apportate attengono per 710 mld di Lire a svalutazioni su crediti.”

In questa parte BI inizia a occuparsi dei coefficienti (ratios) patrimoniali prudenziali; il termine **sfaldamento** è riferito a una grave perdita di patrimonio (*se non fosse stata così grave, avrebbe utilizzato termini meno perentori come “progressiva riduzione”*). Un grosso problema che emerge è l'enorme differenza fra quanto dichiarato dalla banca e quanto rilevato in sede ispettiva: **-60 miliardi di Lire** (dato netto stimato in sede ispettiva) contro **910 miliardi di Lire** dichiarati. Le rettifiche apportate, pari a **710 miliardi di Lire**, si riferiscono alla loro trasformazione in perdite su crediti netti.

“Dimensione dei termini del degrado ora manifestatosi si ottiene, per altra via, dal confronto fra l'azzeramento del coefficiente di solvibilità al dicembre '95 e il valore del 9,41% segnalato alla fine dell'anno precedente. Rispetto alla soglia obiettivo del 10%, sanzionata con finalità prudenziale nel giugno '92, detto consultivo comporta: (...)”

Il **coefficiente di solvibilità** è passato in un anno da **9,41%** a **0** (azzeramento a dicembre '95). Inoltre, come già richiamato in precedenza, anche la scorsa ispezione non era andata particolarmente bene, e per questo BI aveva optato per una misura di carattere specifico nei confronti di questa banca, modificando la soglia da rispettare per il coefficiente di solvibilità, portandola dall'**8% al 10%** (richiamo all'art. 53-bis lettera d, nel giugno '92). A seguito dell'ispezione era emerso che il coefficiente di solvibilità della banca era del 9,41% (ennesima violazione).

La redditività

“Indicazioni del pari critiche rinvennero dal disgregarsi dell'attitudine aziendale al profitto, stretta da deficit di periodo ormai sistematici (...)”

Si vuole far emergere che, a prescindere dalla situazione patrimoniale, la banca non sta neanche più riuscendo a generare reddito.

Gli interessi fittizi: il meccanismo dell'“evergreening”

“L'esponenziale ampliarsi degli impieghi produttivi di competenze meramente scritturali.”

Questa semplice frase è fondamentale per capire il problema principale della banca: le **competenze meramente scritturali**. La banca in questione iscriveva a bilancio interessi fittizi. La modalità con cui venivano contabilizzati questi interessi fittizi sempre crescenti è piuttosto semplice:

1. Un'impresa edile **A** richiede un finanziamento di **100 euro** alla banca per la realizzazione di un complesso turistico e la banca glielo concede (*tralasciando un'istruttoria per nulla adeguata, in cui non si considerava la capacità di rimborso del soggetto, se avesse ottenuto o meno l'autorizzazione per poter edificare, la forma tecnica di finanziamento più adeguata, ecc.*).
2. Dopo un po' di tempo la banca si rende conto che l'impresa **A** non riuscirà a restituire la somma prestata; per evitare di passare l'esposizione a sofferenza, banca e impresa si accordano per la costituzione di un'altra impresa **B** (con gli stessi soci di **A**), che chiederà un finanziamento di **120 euro** per la costruzione di un complesso turistico.
3. La società **B** copre il debito di **A** (i 100 euro di finanziamento) più gli interessi maturati nel tempo (**20 euro**, cifra inventata ma esemplificativa).
4. Lo stesso procedimento viene poi ripetuto con le società **C**, **D**, **E**, ecc., generando una catena di finanziamenti sempre crescenti che occultano il deterioramento reale dei crediti.

L'istruttoria del fido e il valore commerciale vs. il valore di realizzo

“E invero, l'attività istruttoria appare incompleta e superficiale, sia nelle proposte promananti dalle ramificazioni periferiche, di rado suffragate da analisi consone, sia nello scrutinio affidato agli uffici centrali, sovente ripetitivo e acritico. In concreto, il prioritario metro di giudizio si è fondato sulla consistenza dei patrimoni apprezzati solo nel presunto valore commerciale e non in quello di realizzo.”

Vengono espressi dei rilievi anche in merito alla modalità con cui erano gestite le pratiche di fido, con riferimento a una pratica particolarmente scorretta nel contesto bancario: utilizzare il **valore commerciale** nelle valutazioni piuttosto che il **valore di realizzo**. (*Quando un cliente offre in garanzia un certo bene, la banca necessita di far realizzare una perizia per poterne determinare il valore; la banca poi dovrà tener conto non del valore commerciale del bene in questione, ma di quanto riuscirà a ottenere in caso di vendita dello stesso — appunto il valore di possibile realizzo, sempre molto più basso del valore commerciale.*)

Precisazione sulla natura dell'ispezione

“Le ispezioni di vigilanza non sono ragguagliabili ad una revisione contabile e, quindi, il presente fascicolo non ha alcun valore a tale effetto.”

Una curiosità è che venga appositamente specificato che l'azione di vigilanza ispettiva non sia equiparabile a una **revisione contabile**.

La consegna del rapporto: il commissariamento in corso d'ispezione

“Il contenuto del presente fascicolo viene portato, in data odierna, a conoscenza del Commissario straordinario e del Comitato di Sorveglianza.”

Da notare come normalmente il rapporto venga consegnato alla banca (in particolare al presidente del CdA e al presidente del Collegio Sindacale); in questo caso, a seguito della situazione disastrosa della banca, la banca è stata **commissariata mentre era ancora in atto l'ispezione**, e infatti il verbale è stato direttamente consegnato al commissario straordinario e al comitato di sorveglianza. (pagina 5–8)

7.9. Rapporto Ispettivo N.1 — Parte Chiusa

Nella parte chiusa, come visto, si ha una riclassificazione di alcune voci di bilancio e di matrice, su cui viene assegnato un giudizio (nel caso di questa banca, tutti sfavorevoli) e una valutazione anche sugli esponenti (altrettanto sfavorevole).

In un'altra tabella sono definite, in colonna, le sofferenze, gli incagli e le perdite, e in riga si specifica la valutazione fornita dalla banca sull'esposizione e il giudizio di BI in sede ispettiva. *(Il documento fonte non riporta i valori numerici di questa tabella: se ne descrive solo la struttura.)*

Nella parte finale, oltre a un riassunto conclusivo in cui si ribadisce lo stato pessimo della banca, si specifica che lo spettro degli strumenti a disposizione per poter intervenire è **“ampio e non preclusivo”**, cioè si può utilizzare qualunque strumento. (pagina 8–9)

7.10. Rapporto Ispettivo N.2 — Parte Aperta: la centralità della governance

Il secondo rapporto analizzato, più recente del primo, si apre con un giudizio complessivo netto:

“L'accertamento ha fatto emergere risultanze in prevalenza sfavorevoli.”

Già questa introduzione non lascia presagire nulla di buono.

“Il sistema di governo e controllo aziendale è affetto da significative disfunzioni (...). Detto sistema, infatti, si presenta opaco, con riferimento agli assetti proprietari. Elementi di scarsa trasparenza si sono palesati nelle informative fornite all'Organo di Vigilanza.”

“L'Amministratore Delegato e socio di riferimento accentra in sé responsabilità e di controllo (...); Il consiglio di amministrazione non fornisce un adeguato contributo dialettico (...); il collegio sindacale non ha assicurato un'adeguata sorveglianza (...), l'internal auditor (...).”

Il primo elemento da notare è che, a differenza del primo rapporto ispettivo analizzato (dove il primo argomento trattato era il contesto esterno), in questo rapporto la **governance** è il primissimo argomento trattato. La situazione di questa banca è particolarmente grave a causa di un socio forte divenuto contemporaneamente amministratore delegato, presidente e direttore generale; gli altri organi (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, internal auditor) non sono stati comunque molto d'aiuto, non fornendo gli opportuni contrappesi.

Vale la pena sottolineare come, all'epoca di questa ispezione (precedente al 2015), non vi era ancora il **potere di removal**: l'unica strada perseguibile per BI era il **commissariamento**. Sapendo che il problema principale di questa banca era questo socio molto forte, sarebbe stata una soluzione molto più mirata ed efficiente la rimozione del singolo soggetto, piuttosto che la caduta di interi organi sociali a seguito del commissariamento — soluzione che, all'epoca, non era però disponibile.

(pagina 9)

8 | La disciplina sanzionatoria bancaria

Fonte: LEGB2_Appunti_08_Disciplina-Sanzionatoria.pdf — 4 pagine

8.1. Introduzione: quando e come interviene Banca d'Italia

Laddove il rapporto ispettivo presenti pochissime costatazioni o non ne presenti affatto (cosa impossibile) non è necessario prendere alcuna misura; laddove però siano state riscontrate più irregolarità o la situazione della banca risulti gravemente compromessa, Banca d'Italia (BI) è tenuta ad intervenire tramite l'erogazione di sanzioni o anche con misure più incisive.

Le sanzioni sono trattate negli articoli finali del TUB (art. 144 e seguenti); alcuni articoli sono stati aggiunti a seguito del recepimento della CRD4 (Capital Requirements Directive IV).

Vale la pena sottolineare come, nonostante le sanzioni vengano erogate normalmente al termine dell'attività ispettiva, questo non significhi che sia l'unico momento in cui possano essere effettivamente utilizzate: - se BI è certa che nell'ambito della **vigilanza informativa** siano state commesse violazioni, procede **direttamente** all'erogazione della sanzione; - negli altri casi preferisce **attendere l'esito dell'ispezione**, solo per avere maggiore certezza. (pagina 1)

8.2. Art. 144 TUB — Altre sanzioni amministrative alla società ed enti

Comma 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato; nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:

In questo caso si utilizza la **tecnica del richiamo**: nel comma successivo si richiamano direttamente tutte le discipline che potrebbero essere soggette a violazione e comporterebbero una sanzione. Fra gli articoli richiamati si hanno: - l'art. **18** (società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento); - l'art. **51** (vigilanza informativa); - l'art. **53** (vigilanza regolamentare).

Comma 8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali. (Comma autoesplicativo.)

Comma 9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate **fino al doppio** dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. (Comma autoesplicativo.) *(pagina 1-2)*

8.3. Art. 144-bis TUB — Ordine di porre termine alle violazioni

Comma 1. Per le violazioni previste dall'articolo 144, comma 1, lettera a), quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Banca d'Italia può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della società o dell'ente una sanzione consistente nell'**ordine di eliminare le infrazioni**, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

In questo articolo si definisce una misura alternativa: a seguito di una violazione caratterizzata da scarsa offensività o pericolosità (ad esempio una violazione di una certa soglia per un ammontare molto contenuto e per un periodo di tempo piuttosto ristretto), BI, invece di erogare una sanzione, può applicare una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni.

Comma 2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, la Banca d'Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144, comma 1; l'importo delle sanzioni è aumentato **sino a un terzo** rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 144. (Comma autoesplicativo.) *(pagina 2)*

8.4. Art. 144-ter TUB — Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale

Comma 1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro** nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: (...)

Le sanzioni sono state inasprite nei confronti degli esponenti aziendali e sono state aggiunte anche verso il personale. Da notare come il valore della sanzione amministrativa pecuniaria vada da 5.000 a 5 milioni di euro: queste cifre sono appositamente elevate perché dovrebbero costituire un incentivo (deterrente).

Per le sanzioni erogate nei confronti del personale, la banca ha l'obbligo di esperire l'**azione**

surrogatoria: se un soggetto non fosse capace di pagare la propria sanzione, la banca può sostituirsi ad esso, ma avrà l'obbligo di farsi restituire la somma "anticipata". *(pagina 2)*

8.5. Art. 144-quater TUB — Criteri per la determinazione delle sanzioni

Comma 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo, la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; (...)

In questo comma si specificano tutta una serie di criteri che vengono tenuti in considerazione in sede di determinazione delle sanzioni. *(pagina 3)*

8.6. Art. 144-septies TUB — Applicazione delle sanzioni nell'ambito del MVU

Comma 1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU (Meccanismo di Vigilanza Unico).

Comma 2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d'Italia può applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente **su richiesta della BCE**.

Questo articolo specifica che, in caso di violazione accertata a livello europeo, la sanzione non può essere erogata direttamente dalla BCE, ma quest'ultima deve rivolgersi a BI. *(pagina 3)*

8.7. Art. 145 TUB — Procedura sanzionatoria

Comma 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia, contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.

Questo comma è stato modificato più volte nel corso del tempo, ma la modifica più importante è avvenuta a seguito della **legge 262/2005** (la legge sulla tutela del risparmio). Laddove BI rilevi che ci siano anomalie affinché possa essere erogata una sanzione, prima deve avviare un autonomo procedimento amministrativo e solo successivamente può inviare una lettera nei confronti della banca indicando l'entità della sanzione, i soggetti coinvolti e le motivazioni. I

soggetti interessati, entro trenta giorni, possono presentare deduzioni o richiedere un'audizione personale.

La modifica avvenuta a seguito della legge sul risparmio è che la sanzione non viene più erogata dal **MEF**¹ ma **da BI stessa**. Una possibile critica a questo sistema è che quindi nell'ambito sanzionatorio si lascia un potere piuttosto ampio a BI; un possibile contrappeso a questa disciplina è che la potestà sanzionatoria è stata affidata ad un ufficio indipendente.

Comma 4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla **corte di appello di Roma**. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

Questo comma è abbastanza strano ed è stato contestato in passato a seguito delle numerose eccezioni al diritto comune che introduce: 1. nonostante il provvedimento provenga da una pubblica amministrazione, si viene reindirizzati verso un giudice **civile**; 2. si parla esplicitamente di **corte di appello** (e non di tribunale), quindi ci si trova già nel secondo grado di giudizio; 3. non si applica il principio di competenza territoriale, perché si specifica chiaramente che la corte di appello debba essere di **Roma**.

Le spiegazioni fornite a queste eccezioni sono: - alla seconda eccezione: le autorità che erogano la sanzione (MEF prima e BI dopo) sono considerate in un certo qual modo già un primo grado di giudizio; - alla terza eccezione: si è preferito evitare che gli addetti alla consulenza di BI viaggiassero in tutta Italia (è quindi una norma di favore).

(pagina 3-4)

¹Il MEF riceveva un "parere" da BI che non veniva quasi mai disatteso.

9 | Altre forme di vigilanza: modificazioni statutarie, fusioni e scissioni, cessione di rapporti giuridici, tutela della concorrenza

Fonte: LEGB2_Appunti_09_Altre-Forme-di-Vigilanza.pdf — 7 pagine

9.1. Introduzione: gli altri poteri di vigilanza

Proseguendo nella lettura del TUB si nota che, oltre ai tre poteri “classici” di vigilanza (informativa, regolamentare, ispettiva), ne esistono anche altri, disciplinati dagli articoli 56, 57 e 58 TUB. Questi articoli esistevano già nella precedente legge bancaria, ma sono stati più volte modificati nel corso del tempo.

Nota: esiste in più, in linea teorica, anche un potere relativo alla concorrenza attribuito a Banca d'Italia (BI), ma non è mai stato inserito effettivamente all'interno del TUB.

(pagina 1)

9.2. Art. 56 TUB: modificazioni statutarie

Comma 1: *La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.*

Nella vecchia legge bancaria era previsto che, laddove una banca avesse voluto modificare il proprio statuto, avrebbe dovuto far autorizzare queste modifiche dall'autorità di vigilanza; inoltre, nel caso delle banche pubbliche, le modifiche erano approvate dal Ministro del Tesoro. Attualmente non esiste più questa differenza fra banche pubbliche e private e non si utilizza più il verbo “autorizzare” ma “accertare”. Il motivo di questo cambio di terminologia viene spiegato nella relazione accompagnatoria al TUB, in cui si specifica che si tratta solo di una modifica formale e non sostanziale: l'accertamento, nella pratica, è un'autorizzazione, ma si vuole far emergere l'autonomia imprenditoriale della banca. L'autorità di vigilanza si limita solo a verificare che le modifiche statutarie non contrastino con la sana e prudente gestione.

Comma 2: *Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.*

Il comma 2 riprende lo stesso concetto espresso nell'art. 14 TUB: se fra i documenti necessari per iniziare l'attività bancaria vi era anche lo statuto, necessariamente questo era già stato accertato, e per forza di cose le sue eventuali modifiche dovranno essere riaccertate.

Disposizioni secondarie e prassi applicativa. Ulteriori informazioni si trovano nel Titolo III, Capitolo 1 della circolare 229 (quasi completamente abrogata, salvo alcuni aspetti non ripresi dalle normative europee). Nelle vecchie disposizioni di vigilanza era previsto che: 1. il CDA predisponesse il progetto relativo alle modificazioni statutarie; 2. si ricevesse l'autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza; 3. successivamente fosse convocata l'assemblea per la votazione; 4. il verbale dell'assemblea fosse trasmesso a BI, per controllare che quanto autorizzato in precedenza fosse coerente con quanto approvato successivamente dall'assemblea (una forma di mancanza di fiducia di BI nei confronti della banca).

Nel 2007, a seguito dello stesso provvedimento che ha facilitato l'apertura degli sportelli bancari, BI ha attuato un processo di semplificazione della procedura: adesso l'accertamento è divenuto solo anteriore alla deliberazione assembleare. Gli amministratori commettono un'irregolarità se convocano l'assemblea per votare una modifica statutaria senza previo accertamento di BI. È scomparso un controllo apposito di BI a posteriori della votazione, ma esistono comunque diversi modi con cui BI può indagare se la modifica approvata in assemblea sia stata coerente con quanto accertato (ad esempio tramite i meccanismi di vigilanza informativa o ispettiva; senza contare che il notaio, nella verbalizzazione dell'assemblea, si assume la responsabilità).

Nella pratica, la richiesta di modifica dello statuto viene realizzata inviando un documento diviso per colonne, in cui sono presenti il vecchio statuto su una colonna e quello nuovo sull'altra, con segnalazioni grafiche per far emergere le differenze che si intendono apportare. *(pagina 1-2)*

9.3. Ripasso: la disciplina generale delle modificazioni statutarie (diritto societario)

Costituisce modificazione dello statuto di una società per azioni ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale, come ad esempio l'introduzione o la soppressione di clausole preesistenti.

Le modifiche statutarie rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci in sede straordinaria (anche se, in alcuni casi, lo statuto può attribuire la facoltà di modifica anche all'organo amministrativo). La delibera di modificazione viene adottata con le maggioranze previste in via generale per l'assemblea straordinaria. Le delibere modificative, per quanto non siano più pedissequamente sotto il controllo giudiziario, lo sono in via eventuale e facoltativa.

Ai sensi dell'art. 2436 c.c., il notaio verbalizza la delibera dell'assemblea e, chiuso il verbale, verifica l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge; entro trenta giorni ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese, contestualmente al deposito. *(pagina 2)*

9.4. Art. 57 TUB: fusioni e scissioni

Osservando gli articoli relativi alle fusioni delle BCC e delle BP, nonché questo articolo e le disposizioni di vigilanza, emerge un chiaro *favor* del legislatore per le operazioni di aggregazione. La vecchia legge bancaria prevedeva però un potere in più, oggi scomparso: la **fusione coatta** (BI aveva la possibilità di ordinare a due banche di fondersi). Il TUB non contiene più questo istituto, perché significherebbe non riconoscere l'autonomia imprenditoriale delle banche; BI può comunque convocare l'assemblea inserendo come ordine del giorno la proposta di fusione fra due banche (art. 53-bis).

Comma 1: *La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'articolo 14. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.*

Qui si torna a parlare di **autorizzazione** invece che di accertamento. A seguito dell'entrata in vigore del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), si è previsto che l'autorizzazione non è necessaria laddove venga rilasciata dalla BCE. Il decreto legislativo richiamato si occupa della disciplina dei gruppi bancari.

Comma 2: *Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1.*

Comma identico, nella logica, a quello dell'articolo precedente (art. 56).

Comma 3: *Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.*

Si tratta di una deroga al diritto comune, che dimezza (e oltre) il termine di opposizione previsto per i creditori alla fusione: un ulteriore esempio del *favor* legislativo per le fusioni citato in apertura.

(pagina 2-3)

9.5. Ripasso: la disciplina dell'opposizione dei creditori alla fusione

L'art. 2503 c.c. stabilisce che l'attuazione della fusione non può avere luogo prima che siano decorsi **60 giorni** dalla data in cui risulta essere stata iscritta, presso l'ufficio del Registro delle Imprese territorialmente competente, la decisione di fusione dell'ultima società partecipante. Tale termine è, tuttavia, ridotto alla metà, e quindi a **30 giorni**, nel caso in cui alla fusione non partecipino società il cui capitale è rappresentato da azioni (art. 2505-quater c.c.).

Nel corso dei predetti periodi, i creditori delle singole società partecipanti possono opporsi all'operazione straordinaria di fusione deliberata dai soci, innanzi al competente Tribunale, il quale può comunque disporre che la fusione abbia luogo qualora ritenga infondato il pericolo di

pregiudizio per i creditori, ovvero qualora la società partecipante alla fusione — nei cui confronti è stata formulata opposizione — presti idonee garanzie.

Nell'eventualità in cui, per effetto della fusione, uno o più soci di una delle società partecipanti perdano la propria posizione di socio illimitatamente responsabile, acquisendo quella di socio a responsabilità limitata (come nel caso di una s.n.c. che partecipa ad una fusione con società risultante o incorporante s.r.l. o s.p.a.), la mancata opposizione dei creditori sociali alla fusione **non libera automaticamente** l'ex socio dalla illimitata responsabilità per le obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui si perfeziona la fusione. È necessario, ai fini della liberazione del socio dalle obbligazioni sociali anteriori alla fusione, che vengano rispettate le disposizioni dell'art. 2500-quinquies c.c. in materia di trasformazione societaria. Tale norma prevede infatti che la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, “se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione”: il consenso si presume espresso se il perfezionamento dell'operazione viene comunicato ai creditori sociali con raccomandata con avviso di ricevimento (o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento) ed entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione non sopravvenga il diniego espresso della liberazione dei soci da parte dei creditori sociali.

L'obbligo dell'attesa dei predetti termini (60 o 30 giorni, a seconda della composizione del capitale delle società partecipanti alla fusione) può essere superato qualora consti il consenso dei creditori di ciascuna società partecipante alla fusione. Peraltro, anche in assenza del consenso da parte dei creditori sociali, tali termini possono comunque essere derogati dalle singole società partecipanti, nei seguenti modi alternativi: - procedendo al pagamento dei creditori che hanno espresso l'assenso alla fusione; - depositando presso un istituto di credito una somma di denaro corrispondente all'ammontare dei crediti vantati verso la società dai creditori che non hanno manifestato il loro consenso alla fusione.

L'art. 2503 c.c. prevede, inoltre, che la prestazione della garanzia — rappresentata dal deposito presso un istituto di credito o da adeguata fideiussione bancaria — non è necessaria quando tale circostanza risulta dalla relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c., redatta da un'unica società di revisione per tutte le società partecipanti alla fusione. *(pagina 3-4)*

9.6. Approfondimenti sull'art. 57 TUB: accertamento vs autorizzazione, fusioni miste e caso applicativo

Perché “autorizzare” e non “accertare”. In questo caso non è possibile utilizzare il termine “accertare” (infatti si usa il verbo “autorizzare”) e il motivo è chiaro: laddove si tratti di una fusione per unione, il risultato finale è la costituzione di una nuova società (nuova società vuol dire nuova banca, e questo comporta la necessità di una nuova autorizzazione); laddove invece si tratti di una fusione per incorporazione, non si è di fronte ad una nuova banca, ma le modifiche sono tali per cui è comunque necessaria un'autorizzazione.

Fusioni “a cui prendono parte” le banche, non “tra” banche. Vale la pena sottolineare

che non si parla di fusioni tra banche, bensì di fusioni a cui prendono parte le banche: è quindi possibile che vi siano anche fusioni fra banche e non banche (ad esempio con intermediari finanziari). Lo stesso discorso vale anche nel caso di scissioni; il principio guida resta sempre la sana e prudente gestione.

Il piano industriale (moral suasion). Nelle vecchie istruzioni di vigilanza (Circolare 229, Titolo III, Capitolo 4), nella premessa emerge un elemento importante: il CDA è tenuto a presentare, nell'istanza di autorizzazione, anche un documento in cui viene svolta un'attenta analisi dei vantaggi e dei costi che la banca si aspetta dall'operazione di fusione (o scissione), per verificarne la convenienza economica. Questa valutazione può essere svolta tramite la redazione di un piano industriale che faccia emergere i profili economici e le fasi in cui si dovrà articolare il processo di concentrazione. Nelle disposizioni si afferma che la redazione di questo piano è opportuna ma non obbligatoria; nella pratica è come se lo fosse, trattandosi di un atto di *moral suasion*.

Esempio: la cessione di azienda SPA a una BCC (2004). Nel 2004 vi è stata un'operazione di cessione di un'azienda bancaria costituita in forma di SPA ad una BCC. Non sarebbe stato possibile realizzare una fusione per incorporazione perché, nonostante l'art. 37 TUB consenta le fusioni "miste" (fra BCC e SPA), la risultante della fusione deve comunque essere una SPA. Anche laddove fosse stato possibile perseguire questa strada, la BCC difficilmente avrebbe accettato, per un motivo molto semplice: in caso di incorporazione sarebbero stati "presi" anche i soci della SPA, e per una BCC (in cui il voto è capitario) questo avrebbe potuto significare alterare gli equilibri interni.

(pagina 4)

9.7. Art. 58 TUB: cessione dei rapporti giuridici

Questo istituto torna utile in diversi contesti, fra cui anche nell'ambito delle crisi bancarie (ad esempio, nella vicenda di Veneto Banca, la cessione dei rapporti è avvenuta verso Intesa San Paolo). Anche questo articolo era presente nella vecchia legge bancaria, ma era organizzato diversamente.

Comma 1: *La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.*

Le tre ipotesi presentate in questo comma riguardano: 1. la cessione di **aziende** a banche (art. 2555 c.c.: l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa); 2. la cessione di **rami d'azienda** (ad esempio sportelli); 3. la cessione di **rapporti giuridici** individuabili in blocco (ad esempio, cedere tutte le posizioni relative al leasing perché non si vuole più operare in tale settore).

In questo caso non si parla di autorizzazione (né di accertamento), ma si afferma che BI emana istruzioni (contenute anch'esse nelle vecchie disposizioni di vigilanza — Circolare 229, Titolo III, Capitolo 5). Il TUB afferma però che, a loro volta, le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione da parte di BI. Le

istruzioni dispongono che la cessione richiede l'autorizzazione quando le attività o le passività oggetto di cessione superano il **10%** del patrimonio di vigilanza della cessionaria.

Comma 2: *La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.*

È dunque la banca **cessionaria** a dare notizia dell'avvenuta cessione. Cosa succederebbe se venisse realizzata una cessione per cui è prevista l'autorizzazione, ma senza aver ottenuto l'autorizzazione di BI? In questo articolo manca un comma come quello dell'articolo precedente (art. 57), che specifichi che non si può dare corso all'operazione senza autorizzazione. Se venisse violato l'art. 58: dal punto di vista amministrativo verrebbe erogata la sanzione prevista all'art. 144 TUB; dal punto di vista del diritto comune, l'operazione sarebbe **inefficace** (non invalida, perché resta valida, ma non produce gli effetti).

Nota: questo significa che l'autorizzazione può anche essere successiva e l'operazione può essere sanata.

Comma 3: *I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.*

In caso di cessione di rapporti bancari si ha quindi anche la cessione di tutte le garanzie connesse (ad esempio, la cessione di un mutuo ipotecario porta con sé anche l'ipoteca).

(pagina 5-6)

9.8. La tutela della concorrenza e i poteri di Banca d'Italia: evoluzione storica

In ultimo, vale la pena riprendere brevemente l'evoluzione della disciplina relativa ai poteri assegnati a BI nell'ambito della tutela della concorrenza.

La legge antitrust (287/1990). La disciplina della tutela della concorrenza è stata introdotta in Italia, prendendo spunto da Europa e Stati Uniti, con la legge 287/1990 (la cosiddetta legge antitrust). Questa legge si basa su tre grandi pilastri: - le **intese** (accordi fra imprenditori volti a ridurre o falsare la concorrenza); - l'**abuso di posizione dominante** (comportamenti sleali derivanti da un posizionamento sul mercato che portano ad una distorsione della concorrenza); - le **concentrazioni** (fusioni fra imprese che, aumentando sensibilmente la loro quota di mercato, potrebbero mettere in atto comportamenti tali da falsare la concorrenza).

Nota: laddove più imprese caratterizzate da elevate quote di mercato vogliano realizzare una fusione, visto il potenziale rischio di concentrazione, è necessario ricevere un'autorizzazione da parte dell'autorità competente.

La legge 287/1990 istituì anche un'apposita autorità amministrativa indipendente (come BI, CONSOB, ecc.): l'**AGCM** (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

La deroga per le banche (art. 20, comma 2, legge 287/1990). La legge 287/1990 prevedeva, all'art. 20 comma 2, una deroga alla disciplina comune, assegnando i poteri in materia antitrust relativi alle banche non all'AGCM ma a **BI** (l'AGCM avrebbe fornito soltanto pareri non vincolanti; la scelta finale sarebbe spettata sempre a BI).

Nota: la ratio dietro questa scelta era che si riteneva che BI conoscesse molto meglio dell'AGCM il settore bancario.

I due problemi emersi con il TUB. A seguito dell'entrata in vigore del TUB, quella disciplina fece emergere due ordini di problemi:

1. *La ripartizione delle competenze:* assegnare i poteri antitrust a BI per le banche era più semplice da sostenere prima della despecializzazione, ma cosa sarebbe successo laddove una banca avesse commerciato, tramite i propri sportelli, un prodotto assicurativo?
2. *I criteri utilizzati,* potenzialmente in conflitto fra loro. Un caso emblematico è quello della **Banca Popolare di Sassari**: questa banca era particolarmente in difficoltà e si tentò una fusione con il Banco di Sardegna. Dal punto di vista della sana e prudente gestione non vi erano problemi (una banca sana ne ingloba una in difficoltà); dal punto di vista della disciplina antitrust, questa fusione era invece un problema enorme, visto che le due banche in questione detenevano le maggiori quote di mercato (per di più in un'isola, quindi in un mercato geograficamente chiuso). Nonostante l'AGCM avesse espresso parere negativo sul progetto di fusione, BI decise comunque di autorizzarla.

Prevenzione di intese e abusi di posizione dominante. Negli anni in cui i poteri nell'ambito della tutela della concorrenza erano assegnati a BI, questa operò anche per prevenire intese e abusi di posizione dominante: ad esempio, durante un'ispezione, un funzionario di BI trovò il verbale di un'assemblea, a cui avevano partecipato esponenti di tutte le banche, nella quale si era tentato di concordare condizioni economiche da proporre a livello nazionale.

Il caso delle NUB. Un altro caso importante in cui BI utilizzò i poteri assegnati nell'ambito della tutela della concorrenza fu il giudizio relativo alla compatibilità (o meno) delle NUB.

Nota: le NUB (Norme Uniformi Interbancarie) sono circolari predisposte dall'A-BI (Associazione Bancaria Italiana), finalizzate a regolarizzare e standardizzare i rapporti fra banche e clienti.

Nel 1994 BI affermò che le NUB non creano in alcun modo un'intesa anticoncorrenziale, perché prive di valore vincolante (le banche possono scegliere se rispettarle o meno). In generale, però, sono ammesse solo NUB di carattere giuridico o tecnico, perché il vantaggio tratto dal cliente è superiore al danno che ne subisce; le NUB con contenuto economico, o giuridiche ma con un risvolto economico, sono invece illegittime.

La riforma del 2005 e l'abrogazione della deroga. Successivamente, anche perché ci si era resi conto di essere l'unica nazione ad aver adottato questa scelta, la legge sulla tutela del risparmio (262/2005) andò ad abrogare l'art. 20 comma 2 della legge antitrust, riportando i poteri esclusivamente in capo all'AGCM.

Il tema delle concentrazioni: art. 19 comma 12 (abrogato). Un'altra tematica affrontata dalla legge sulla tutela del risparmio era definita ai sensi dell'art. 19 comma 12 (attualmente abrogato), relativo ancora al tema delle concentrazioni. Quando più banche realizzano una fusione, bisogna considerare sia profili riconducibili ad un'analisi di sana e prudente gestione (di competenza delle autorità di vigilanza), sia profili relativi ai possibili risvolti derivanti da concentrazioni (di competenza dell'autorità antitrust).

Nota: ciò vale ovviamente per banche di maggiori dimensioni, per cui si rischia una concentrazione delle quote di mercato, non per qualunque operazione di fusione.

L'art. 19 sanciva che, per poter essere autorizzata, una fusione fra banche richiedesse che BI e AGCM si accordassero per il rilascio di un unico atto (cioè un provvedimento congiunto). Il problema sorgeva nel momento in cui una delle due autorità non era favorevole all'operazione: l'inesistenza dell'atto (in quanto mai "pubblicato") implicava anche l'inoppugnabilità dello stesso. Per questo motivo, il legislatore ha successivamente optato per l'abrogazione dell'art. 19, prevedendo il rilascio di due documenti distinti.

(pagina 6-7)

10 | La vigilanza su base consolidata e i gruppi bancari

Fonte: LEGB2_Appunti_10_Vigilanza-Consolidata-e-Gruppi-Bancari.pdf — 3 pagine

10.1. Introduzione: vigilanza su base consolidata vs vigilanza sui gruppi bancari

Il legislatore, nella composizione del TUB, ha scelto di occuparsi prima della vigilanza in riferimento alla singola banca (ai sensi degli artt. 51 e seguenti) e successivamente della vigilanza nei confronti dei gruppi bancari e di quella consolidata.

Bisogna tenere a mente l'assenza di identità fra la **vigilanza su base consolidata** (in senso stretto) e la **vigilanza sui gruppi bancari**: la prima infatti è una disciplina più generica che include anche la seconda (la riprova la si ha ai sensi dell'art. 65 TUB).

- La **Sezione I** è dedicata alla vigilanza sui gruppi bancari;
- la **Sezione II** è dedicata alla vigilanza consolidata.

(pagina 1)

10.2. Art. 59 TUB: Definizioni

Comma 1: Ai fini del presente capo:

- a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23;
- b) per “società finanziarie” si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia.

In questo articolo vengono presentate alcune definizioni; quelle di maggior interesse sono esclusivamente le prime due. La definizione di **controllo** richiama direttamente quanto disposto ai sensi dell'art. 23 TUB.

(pagina 1)

10.3. Art. 60 TUB: Composizione del gruppo bancario

Comma 1: Il gruppo bancario è composto alternativamente:

- a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
- b) dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, le partecipazioni in società bancarie e finanziarie.

La disciplina sul gruppo bancario è nata con la legge Amato del '90 e successivamente il legislatore l'ha estesa verso altri soggetti (nel codice civile infatti esiste la disciplina sui gruppi, ma è stata ripresa dal TUB).

La lettera a e la lettera b, se confrontate, presentano due possibilità su chi possa essere capogruppo:

- la **lettera a** parla di una banca italiana: se una banca italiana è capogruppo, allora si tratta necessariamente di un gruppo bancario (ipotesi di tipo qualitativo);
- la **lettera b** stabilisce invece che si può avere un gruppo bancario anche quando la capogruppo non è una banca italiana ma una società finanziaria; in tal caso, all'interno del gruppo deve esserci almeno una banca italiana e devono esserci partecipazioni rilevanti¹ in società bancarie e finanziarie (inizialmente ci furono dei problemi per far quadrare questa disciplina delle partecipazioni con quella dell'art. 61 TUB comma 2; per evitare tanti problemi quest'ultimo è stato direttamente abrogato).

(pagina 1-2)

10.4. Art. 61 TUB: Capogruppo

Comma 1: Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.

In questo comma si ribadisce semplicemente chi può essere capogruppo.

Comma 3: Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.

¹Il concetto di rilevante è ripreso all'interno delle disposizioni di vigilanza: affinché la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista possa essere considerata capogruppo occorre, fra l'altro, che nell'insieme delle società da essa partecipate abbiano "rilevanza determinante" quelle bancarie, finanziarie e strumentali. Tale condizione risulta soddisfatta se il rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio delle banche, delle società finanziarie e delle società strumentali partecipate e il totale dell'attivo di bilancio della capogruppo e di tutte le società ed enti da essa partecipati è superiore al 40 per cento. Ai fini di tale calcolo le imprese di assicurazione sono assimilate a quelle esercenti attività finanziaria.

In questo comma si specifica che, laddove una banca sia una capogruppo, nei suoi confronti resta ferma la disciplina prevista per tutte le altre banche e si aggiungono queste norme. Si riprende anche la disciplina per le modifiche statutarie.

Comma 4: La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

In questo comma si specifica che, oltre alla classica attività di direzione e coordinamento (presente anche nel diritto comune), la capogruppo ha altri compiti: quando si costituisce un gruppo bancario, infatti, la capogruppo diventa un anello di congiunzione fra le autorità di vigilanza e i soggetti appartenenti al gruppo (in caso di inadempimenti della capogruppo, questa ne risponde).

(pagina 2)

10.5. Art. 65 TUB: Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata

Comma 1: La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) società appartenenti a un gruppo bancario;
- b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
- c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca.

Da questo comma si evince che la vigilanza consolidata si riferisce non solo ai gruppi bancari (lettera a) ma anche ad altri soggetti (lettere b e c); ai sensi degli articoli successivi si riprendono gli istituti della vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva.

(pagina 2-3)

11 | La disciplina della crisi bancaria

Fonte: LEGB2_Appunti_11_Disciplina-della-Crisi.pdf — 12 pagine

11.1. Evoluzione storica della disciplina della crisi bancaria

In tutti gli ordinamenti esiste una disciplina speciale per la crisi delle banche, dal momento che a queste non possono essere applicate le norme di diritto comune.

La **vecchia legge bancaria** prevedeva due istituti: - l'**amministrazione straordinaria**, utilizzata in situazioni ritenute *gravi*; - la **liquidazione coatta amministrativa**, utilizzata in casi ritenuti di *eccezionale gravità*.

A seguito della seconda direttiva banche, il TUB — non essendo ancora all'epoca armonizzata a livello europeo la disciplina sulla crisi — aveva ripreso esattamente gli stessi istituti della precedente legge bancaria (restavano comunque evidenti problematiche di carattere interpretativo e applicativo).

I cambiamenti più rilevanti sono avvenuti a seguito della ricezione della **direttiva 54/2014**, rubricata come **BRRD** (*Banking Recovery and Resolution Directive*), che ha permesso di armonizzare la disciplina europea in merito alla gestione delle crisi; il legislatore ha aggiunto numerosi articoli ed è stato creato un apposito corpo normativo.

Nonostante la vecchia legge bancaria prevedesse soltanto due istituti veri e propri, in realtà le modalità e gli strumenti attraverso cui le autorità di vigilanza potevano (e possono) operare erano molti di più (fusioni fra banche, scissioni, cartolarizzazioni, etc.). Si considerano qui due esempi emblematici: il **Decreto Sindona** e la **crisi del Banco di Napoli**.

Il Decreto Sindona. Rappresenta un caso emblematico dei numerosi mezzi effettivamente a disposizione delle autorità di vigilanza: si tratta di una misura *ad hoc* adottata per evitare il fallimento di una banca. Con questo decreto si garantiva alle banche che avessero aiutato ad evitare il fallimento di un istituto la possibilità di ottenere un finanziamento agevolato da parte di Banca d'Italia (BI). Lo strumento venne adottato negli anni in cui era ancora presente una vigilanza di tipo strutturale e non era stata ancora disciplinata adeguatamente la materia degli aiuti di Stato.

La crisi del Banco di Napoli. Caso più recente, relativo all'ex istituto bancario più grande del Mezzogiorno. Non potendo adottare misure come quelle del Decreto Sindona (ci si trovava già nel contesto della vigilanza strutturale), le autorità italiane chiesero alla Commissione europea una deroga su alcune discipline (come quelle sugli aiuti di Stato) per poter evitare il fallimento

della banca, risanarla e renderla appetibile per il mercato. La Commissione europea, anche alla luce di un’analoga richiesta mossa dalle autorità francesi a causa del fallimento di una loro banca di grandi dimensioni, decise di accettare la proposta dell’Italia.

Le misure concretamente adottate per evitare il fallimento del Banco di Napoli furono numerose e in sequenza: 1. sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero del Tesoro; 2. “alleggerimento” dell’istituto delle posizioni a sofferenza, gestite da una società costituita appositamente, la **SGA**¹; 3. emissione di obbligazioni.

Per rendere appetibili le obbligazioni — dal momento che le banche concorrenti non avrebbero voluto sottoscrivere obbligazioni di un loro competitor — il governo utilizzò anche il Decreto Sindona. A seguito di questi interventi la crisi venne superata con successo. *(pagina 1)*

11.2. La BRRD e la riforma del Titolo IV del TUB

La BRRD è stata particolarmente importante perché ha rappresentato una presa di posizione sul tema delle modalità di gestione di una crisi bancaria. Durante la crisi del 2008 moltissimi Paesi, tra cui Germania e Regno Unito, avevano utilizzato strumenti volti ad aiutare le proprie banche in difficoltà — non l’Italia, dal momento che quella crisi era partita da un uso scorretto di strumenti derivati — sostanzialmente aiuti di Stato.

A seguito di quella crisi si è deciso che, se la banca è un’impresa a tutti gli effetti, non può essere lo Stato a supportare i rischi di un’eventuale crisi (anche perché ciò spingerebbe verso comportamenti di *moral hazard*), ma devono essere i creditori ad assumersi il rischio (tranne casi molto particolari) — il principio del **bail-in**.

La BRRD è stata recepita il **16 novembre 2015** con l’adozione di due decreti legislativi: - il **d.lgs. 181/2015**, che ha modificato il TUB (soprattutto per quanto riguarda gli articoli successivi al 70); - il **d.lgs. 180/2015**, che ha introdotto la disciplina delle risoluzioni.

Osservando il panorama europeo, la maggior parte dei paesi prevedeva già misure per i casi di crisi irreversibili (in Italia, ad esempio, era già in vigore la liquidazione coatta), ma molti paesi erano carenti in termini di misure per le crisi meno gravi. In Italia esisteva già l’amministrazione straordinaria, e tale misura venne ritenuta così valida dall’UE che si decise di trarne spunto per creare una disciplina concettualmente simile a livello europeo.

Oltre alle situazioni più gravi, la BRRD si è concentrata anche su meccanismi di natura preventiva: la vigilanza prevede infatti non solo interventi *ex-post* ma anche *ex-ante*, e per questo sono state introdotte misure e interventi preliminari per risolvere potenziali crisi prima ancora che queste si presentino.

Successivamente è stata emanata anche una **BRRD II** (recepita tramite d.lgs. 123/2021), che ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina delle crisi.

¹Questa società, per aggirare un limite sull’emissione di obbligazioni, venne costituita come società di diritto inglese (che non prevede tale limite) invece che italiano (dove il limite corrisponde al doppio del capitale sociale).

Per analizzare la disciplina delle crisi nel TUB occorre fare riferimento al **Titolo IV**. Inizialmente rubricato “disciplina delle crisi”, il Titolo IV è oggi rubricato come “misure preparatorie, di intervento precoce, e liquidazione coatta amministrativa”. Il primo articolo del titolo era l’art. 70 TUB (ancora oggi riferito all’amministrazione straordinaria), a cui sono stati progressivamente aggiunti numerosi altri articoli. (pagina 2)

11.3. I piani di risanamento (artt. 69-quater, 69-sexies, 69-octies TUB)

Questi articoli si collocano nel **Capo 01.I**, relativo ai piani di risanamento: siamo in una parte del TUB dedicata alle **banche sane**, in un momento in cui non vi è ancora alcuna crisi in atto.

11.3.1. Art. 69-quater TUB: Piani di risanamento

Comma 1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l’adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

Commento. Le banche devono dotarsi di un piano di risanamento: si tratta di uno strumento di natura preventiva che indica cosa farebbe una banca e quali misure adotterebbe laddove si trovasse in una situazione di crisi.

Comma 5. Il piano di risanamento è approvato dall’organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d’Italia per le valutazioni di cui all’articolo 69-sexies. Il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d’Italia. Si procede comunque al riesame e all’eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.

Commento. Il piano deve essere approvato dall’organo amministrativo e sottoposto a BI. Il riesame avviene almeno con cadenza annuale, ma la frequenza può aumentare a seguito di un mutamento nella struttura giuridica, organizzativa o nella situazione patrimoniale della banca.

11.3.2. Art. 69-sexies TUB: Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo

Comma 1. La Banca d’Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorità competenti degli Stati comunitari in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformità dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.

Commento. Trovandoci ancora in un contesto non di crisi, sono le autorità competenti degli

Stati membri a valutare completezza e adeguatezza dei piani.

Comma 2. Il piano di risanamento è trasmesso all'autorità di risoluzione per la formulazione di eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario.

Commento. L'elemento interessante di questo comma è il richiamo alle autorità di risoluzione: a seguito della BRRD sono state istituite le **autorità di risoluzione**, autorità indipendenti da BI che hanno sostituito la Divisione Situazioni Straordinarie.

11.3.3. Art. 69-octies TUB: Misure attuative dei piani di risanamento

Comma 1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze è comunicata senza indugio alla Banca d'Italia.

Commento. Laddove la situazione dovesse effettivamente peggiorare, si darà attuazione a quanto previsto nel piano di risanamento; ciò può significare sia l'adozione di determinate misure, sia l'astenersi dall'adottarne altre. (pagina 2-3)

11.4. Il sostegno finanziario di gruppo (artt. 69-terdecies, 69-quaterdecies, 69-sexdecies TUB)

Il **Capo 02.I** è relativo al sostegno finanziario di gruppo: disciplina la possibilità per cui, in caso di necessità, si possa attivare un sostegno finanziario da parte dell'intero gruppo bancario.

11.4.1. Art. 69-terdecies TUB: Autorizzazione dell'accordo

Comma 1. Il progetto di accordo è sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell'articolo 69-quindecies, congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche comunitarie aderenti all'accordo, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.

11.4.2. Art. 69-quaterdecies TUB: Approvazione dell'accordo da parte dell'assemblea dei soci e concessione del sostegno

Comma 1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell'articolo 69-terdecies è sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere predisposto dai componenti indipendenti dell'organo amministrativo sull'interesse della società ad aderire all'accordo, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L'accordo produce effetti solo nei confronti delle società le cui assemblee hanno approvato il progetto.

Commento. Si stabilisce che il progetto di accordo debba essere autorizzato oltre che dai soci anche dall'**assemblea straordinaria** (e non da quella ordinaria, come ci si potrebbe aspettare).

11.4.3. Art. 69-sexdecies TUB: Opposizione della Banca d'Italia e comunicazioni

Comma 1. La delibera di concessione del sostegno è trasmessa alla Banca d'Italia, che può vietare o limitarne l'esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all'articolo 69-quindecies non sono soddisfatte. (pagina 4)

11.5. I presupposti dell'intervento precoce (artt. 69-octiesdecies e 69-vicies-semel TUB)

11.5.1. Art. 69-octiesdecies TUB: Presupposti

Comma 1. La Banca d'Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca o una società capogruppo di un gruppo bancario: - **a)** le misure di cui all'articolo 69-noviesdecies; - **b)** la rimozione degli esponenti di cui all'articolo 69-viciessemel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella medesima lettera a), o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione.

Commento. Con questo articolo si passa da un contesto di assenza di crisi della banca ad uno in cui la banca inizia ad avere qualche difficoltà. La lettera a) rimanda a un articolo che prevede l'attuazione del piano di intervento; la lettera b) rimanda a un articolo che prevede il potere di rimozione degli esponenti.

11.5.2. Art. 69-vicies-semel TUB: Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza

Comma 1. Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octodecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche e delle società capogruppo di un gruppo bancario. Si applica il comma 4 dell'articolo 70.

Commento. Il potere di *removal* presentato in questo contesto è più incisivo di quello descritto ai sensi dell'art. 53-bis TUB: in questo caso è data a BI la possibilità di disporre la rimozione di **tutti** i componenti degli organi con funzione di amministrazione e controllo. BI può quindi disporre lo scioglimento dell'intero organo.

Comma 3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia può inoltre ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza di una banca o di una società capogruppo di un gruppo bancario.

Commento. Viene data a BI anche la possibilità di ordinare la rimozione di funzionari dell'alta dirigenza (come, ad esempio, il direttore generale).

Comma 4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della

nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della banca o della società capogruppo.

Commento. Si specifica che la nomina dei nuovi componenti deve essere effettuata dall'organo competente, ma deve essere approvata da BI. (pagina 4-6)

11.6. Amministrazione straordinaria — versione originaria (art. 70 TUB, vecchio testo)

Comma 1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:

- **a)** risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca; - **b)** siano previste gravi perdite del patrimonio; - **c)** lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

Commento. In questa versione la procedura viene disposta dal **Ministro del Tesoro**, su proposta di BI, e vengono inserite le condizioni a), b) e c), oggi confluite nell'articolo 69-octiesdecies.

- La **lettera a)** fa riferimento a gravi irregolarità o violazioni (da confrontare con le differenze rispetto all'art. 52 TUB) delle disposizioni legislative (TUB o altre leggi primarie), amministrative (non riferite al CdA, ma a BI, che è una pubblica amministrazione) o statutarie. L'aggettivo *gravi* è centrale: si vedrà come esso si contrapponga a *eccezionale gravità*, requisito della liquidazione coatta amministrativa.
- La **lettera b)**, a differenza della lettera a) che si occupa di profili legali, fa riferimento all'aspetto patrimoniale; in questo caso l'intervento ha carattere anticipatorio, perché si utilizza il termine *previste*.
- Per quanto attiene alla **lettera c)**, resta discusso se questi organi abbiano facoltà di richiedere l'avvio della procedura solo per quanto previsto ai sensi delle lettere a) e b) o anche per altri motivi (resta comunque un dubbio piuttosto teorico: perché l'organo dovrebbe volere l'amministrazione straordinaria per altri motivi?).

Comma 2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese (...).

Commento. Si specifica che viene sospesa anche l'assemblea.

Comma 5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali, la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore ai sei mesi.

Commento. Si specifica la durata della procedura: un anno (salvo termine più breve previsto dal decreto o da BI), con possibilità di proroga di sei mesi.

Comma 6. La Banca d'Italia può predisporre proroghe non superiori a due mesi dal termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura.

Commento. Questo comma lascia a BI quasi carta bianca: si parla di proroghe al plurale, quindi possono essere anche più di una, ma possono essere predisposte solo per adempimenti connessi alla chiusura della procedura. (pagina 5-7)

11.7. Organi e poteri della procedura di amministrazione straordinaria (artt. 71, 72, 76 TUB)

11.7.1. Art. 71 TUB: Organi della procedura

Comma 1. La Banca d'Italia nomina: **a)** uno o più commissari straordinari; **b)** un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

11.7.2. Art. 72 TUB: Poteri e funzionamento degli organi straordinari

Comma 1. I commissari esercitano le funzioni e i poteri dei disciolti organi amministrativi della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti.

Comma 2. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione.

Commento. Da questi commi si evince come i commissari vadano a sostituire l'organo amministrativo della banca e il comitato quello di controllo. A questi organi vengono però assegnati anche tutti i poteri necessari per l'esecuzione della procedura stessa, come ad esempio l'accertamento della situazione aziendale. I soggetti nominati per queste procedure non sono mai dipendenti diretti di BI, ma persone di sua fiducia (ex dipendenti, professori universitari, etc.).

La procedura di amministrazione straordinaria può concludersi in due modi: 1. i commissari ritengono che la situazione sia sanabile e, a seguito dell'intervento, restituiscono la banca risanata; 2. se la situazione è più grave del previsto, si procede con la **liquidazione coatta amministrativa**.

11.7.3. Art. 76 TUB: Gestione provvisoria (articolo attualmente abrogato)

Comma 1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

Commento. Questo articolo, attualmente abrogato, prevedeva la possibilità per BI di disporre, in casi di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumessero i poteri di amministrazione della banca. Il potere risultava sensato perché in precedenza tali misure erano disposte dal MEF, per cui in caso di urgenza BI aveva comunque facoltà di intervenire; visto che attualmente i poteri sono completamente affidati a BI, questo articolo non trova più ragion d'essere. (pagina 6-7)

11.8. Liquidazione coatta amministrativa — versione originaria e organi della procedura (artt. 80, 81, 86, 87, 90 TUB)

11.8.1. Art. 80 TUB: Liquidazione coatta amministrativa (vecchia versione)

Comma 1. Il Ministro del Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie siano di **eccezionale gravità**.

Commento. Il passaggio da amministrazione straordinaria a liquidazione coatta amministrativa non dipende da un mutamento qualitativo, ma quantitativo: non si parla più solo di *gravità*, ma di *eccezionale gravità*. Il legislatore, tuttavia, non ha mai definito i concetti di gravità ed eccezionale gravità (né si è giunti a un'opinione condivisa in giurisprudenza); il giudizio ultimo sulla procedura con cui procedere spetta a BI (normalmente si tende prima a procedere con l'amministrazione straordinaria, e solo in casi estremi si ricorre alla liquidazione coatta).

In questo comma si specificava (e si specifica tuttora) che il decreto comporta **sia** la revoca dell'autorizzazione **sia** la liquidazione coatta amministrativa; resta discusso se la procedura possa essere disposta (o possa essere ritenuta tale) anche laddove si abbia solo la revoca dell'autorizzazione o solo la disposizione della liquidazione. In passato sono avvenute entrambe le situazioni: - vi è stato un solo caso di revoca dell'autorizzazione senza disposizione della liquidazione coatta amministrativa: una banca siciliana che era stata autorizzata da BI ma, prima dell'inizio delle operazioni, BI stessa aveva revocato l'autorizzazione dopo aver scoperto che i soci della banca erano tutti indagati dalla commissione antimafia; - capitano più spesso casi di disposizione della procedura di liquidazione coatta senza revoca dell'autorizzazione (ad esempio nei casi delle *banche di fatto*).

11.8.2. Art. 81 TUB: Organi della procedura

Comma 1. La Banca d'Italia nomina: **a)** uno o più commissari liquidatori; **b)** un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voto il proprio presidente.

Commento. Da notare come in questa procedura si specifichi che si tratti di **commissari liquidatori** (e non straordinari).

11.8.3. Art. 86 TUB: Accertamento del passivo

Comma 1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca.

11.8.4. Art. 87 TUB: Opposizioni allo stato passivo

Comma 1. Possono opporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati dall'articolo 86, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata.

11.8.5. Art. 90 TUB: Liquidazione dell'attivo

Comma 2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Si applicano le disposizioni dell'articolo 58, commi 2, 3, 4.

Commento. Nell'esecuzione della procedura di liquidazione coatta amministrativa questo articolo è particolarmente importante: il richiamo diretto all'art. 58 TUB permette di comprendere come mai molte liquidazioni coatte si svolgano in tempi brevissimi. Alcune liquidazioni possono essere svolte anche in un fine settimana, purché BI si sia già preventivamente accordata con l'istituto verso cui avverranno le cessioni dell'azienda e dei rapporti giuridici.

A livello di legislazione italiana si sono verificati cambiamenti che riguardano l'impossibilità di procedere ancora con questo *modus operandi*: a seguito della digitalizzazione delle operazioni, gli sportelli non costituiscono più una forma di vantaggio competitivo ma una voce di costo, per cui è più difficile trovare acquirenti. (pagina 7–9)

11.9. Amministrazione straordinaria — versione riformata dalla BRRD (art. 70 TUB, nuovo testo)

L'articolo non è stato stravolto rispetto alla versione precedente, ma vale la pena analizzare alcuni cambiamenti significativi.

Comma 1. La Banca d'Italia può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarità di cui all'art. 69-duodecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio, ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

Commento. In questo caso si prevede che sia **BI** (e non più il MEF) a disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo. Come accennato in precedenza, i

presupposti per l'amministrazione straordinaria sono gli stessi, ma sono stati "spostati" in un altro articolo (il 69-octiesdecies).

Comma 5. L'amministrazione straordinaria dura sino ad un anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine più breve. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo sino ad un anno, anche per più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Commento. Il nuovo comma 5 ha previsto un cambiamento nella durata della procedura: l'amministrazione può durare sino ad un anno (come nella versione precedente), ma possono essere disposte più proroghe, senza limite quantitativo previsto, purché continuino a sussistere i presupposti di cui al comma 1. Ci si può chiedere se, a seguito di più di una proroga, non ci si trovi di fronte a una situazione di *eccezionale gravità* piuttosto che di semplice *gravità*.

Comma 6 (abrogato). Il comma relativo alle proroghe tecniche è stato abrogato; a seguito della modifica del comma precedente, BI non aveva più bisogno di questo ulteriore potere².

(pagina 9-10)

11.10. Il commissariamento leggero: art. 75-bis TUB (Commissari in temporaneo affiancamento)

Comma 1. La Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti indicati all'articolo 70, può nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l'organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l'obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l'assunzione di determinati atti o decisioni.

Commento. Questo articolo rappresenta una novità rispetto all'impianto originario: se sussistono gli stessi presupposti dell'art. 70 (quelli per l'amministrazione straordinaria), BI ha la facoltà di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione, anziché sospendere quest'ultimo. L'articolo è stato inserito prevedendo che possano esistere situazioni di difficoltà non direttamente attribuibili alla banca, per cui l'affiancamento dei commissari agli organi rappresenta una soluzione meno "traumatica" rispetto alla sospensione.

(pagina 10)

11.11. I provvedimenti straordinari verso banche italiane e comunitarie (artt. 78 e 79 TUB)

Fra gli articoli relativi all'amministrazione straordinaria e quelli relativi alla liquidazione coatta amministrativa sono stati introdotti due articoli (78 e 79), inseriti in una sezione rubricata

²Siamo davvero così sicuri che la banca sia ancora considerata un'impresa a tutti gli effetti se sussiste la possibilità di poterla sottoporre indefinitamente a una procedura disposta da una pubblica amministrazione?

“Provvedimenti straordinari”. Poiché entrambi gli articoli si riferiscono a una situazione per la banca sicuramente problematica, ma non tale da essere definita di crisi, probabilmente sarebbe stato più sensato collocarli prima dell’amministrazione straordinaria ma dopo gli strumenti di carattere preventivo.

11.11.1. Art. 78 TUB: Banche autorizzate in Italia

Comma 1. La Banca d’Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l’attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.

Commento. Fra i poteri inseriti in questo comma vi è quello relativo all’apertura o chiusura di nuovi sportelli, di cui BI, negli ultimi anni, ha in effetti leggermente abusato, soprattutto a seguito di violazioni di norme “sensibili” come quelle relative al riciclaggio. In questo comma non si specifica nulla circa il termine del divieto.

11.11.2. Art. 79 TUB: Banche comunitarie

Comma 1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all’autorità competente dello Stato d’origine, la Banca d’Italia ne dà comunicazione a tale autorità per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca d’Italia può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all’autorità competente dello Stato d’origine, alla Commissione europea e all’ABE.

Commento. Come noto, BI non gode di poteri diretti nei confronti delle banche comunitarie, perché vige il principio dell’**home country control**; tuttavia, se sussistono ragioni di urgenza, BI può adottare le misure necessarie per la tutela dei depositanti. Viene appositamente specificato che queste misure debbano essere *necessarie*, non soltanto utili. Le eventuali misure adottate devono essere comunicate all’autorità competente dello Stato d’origine, alla Commissione europea e all’EBA.

Comma 2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d’Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall’autorità competente dello Stato d’origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all’autorità competente dello Stato d’origine e all’ABE.

Commento. Nei casi esplicitamente previsti da questo comma, BI può adottare ulteriori misure laddove ritenga che quelle prese dall’autorità competente dello Stato d’origine manchino o

risultino inadeguate. Anche in questo caso le eventuali misure adottate devono essere comunicate all'autorità dello Stato d'origine e all'EBA.

Comma 3. Quando i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato d'origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d'Italia può ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

Commento. Laddove lo ritenga necessario, BI può rivolgersi direttamente all'EBA che, fra le altre cose, si occupa anche di dirimere le controversie fra le autorità dei diversi paesi.

Comma 4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato d'origine.

(pagina 10-12)

12 | Decreto Legislativo 180/2015 — La risoluzione delle banche

Fonte: LEGB2_Appunti_12_Dlgs-180-2015-Risoluzione.pdf — 8 pagine

12.1. Introduzione al Decreto Legislativo 180/2015

Il Decreto Legislativo 180/2015 disciplina la **risoluzione** delle banche. Il focus dell'analisi è relativo ai **piani di risoluzione**, da non confondere con i **piani di risanamento**. L'analisi del testo parte dal **Titolo III**, rubricato come **misure preparatorie** (da non confondere con le **misure di intervento precoce**). (pagina 1)

12.2. Art. 7 — Piani di risoluzione individuali

Comma 1: La Banca d'Italia predispone, sentita la Banca Centrale Europea se questa è l'autorità competente, un piano di risoluzione per ciascuna banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata. Se la banca ha una o più succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorità di risoluzione di quegli Stati.

Comma 2: Fatto salvo l'articolo 11, il piano è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalità per l'applicazione alla banca delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale.

Comma 3: Nell'elaborare il piano, sono identificati eventuali ostacoli rilevanti per la risoluzione e stabilite modalità d'intervento atte ad affrontarli.

Comma 4: Il piano è riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno annualmente, nonché in caso di significativo mutamento della struttura societaria o organizzativa, della attività o della situazione patrimoniale o finanziaria della banca.

Nota: a differenza dei piani di risanamento (presentati a BI da parte delle banche), il piano di risoluzione è predisposto da parte di BI (non dall'unità di risoluzione). All'interno del piano, che deve essere predisposto almeno una volta l'anno, si prevedono le modalità di intervento in caso di effettiva risoluzione della banca. (pagina 1)

12.3. Art. 12 — Valutazione della risolvibilità

Comma 1: La Banca d'Italia valuta, sentita la Banca Centrale Europea quando questa è l'autorità competente, se una banca non facente parte di un gruppo è risolvibile. Se la banca ha una o più succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorità di risoluzione di quegli Stati.

Comma 2: Una banca si intende risolvibile quando, anche in presenza di situazioni di instabilità finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, essa può essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative significative per il sistema finanziario italiano, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali.

Comma 3: Per valutare la risolvibilità si considerano gli elementi indicati dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale, e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento sulle seguenti misure: a) sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione; b) assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale; c) assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

Comma 4: La valutazione è effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell'articolo 7, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, se ritiene che la banca non è risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione è sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità ai sensi dell'articolo 14.

Nota: da notare come nel comma 1 (e anche nel resto di questo decreto) si definisca la banca come risolvibile; in realtà questo termine è stato tradotto dall'inglese ma non è esattamente la stessa cosa. Nel comma 2 si definisce quando una banca è risolvibile (la banca potrebbe trovarsi in una situazione a metà strada fra la gravità e l'eccezionale gravità non dipesa da eventi endogeni ma esogeni, e per questo BI ritiene che tramite la risoluzione sia possibile minimizzare le conseguenze negative). Nel comma 3 si definiscono una serie di elementi che devono essere considerati per poter valutare la risolvibilità e altri elementi su cui la valutazione non può fare affidamento (ad esempio gli aiuti di Stato). (pagina 1-2)

12.4. Art. 17-19 — Presupposti per l'attivazione delle procedure di crisi

12.4.1. Art. 17 (Presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi)

Comma 1: Una banca è sottoposta a una delle misure indicate all'articolo 20 quando ricorrono **congiuntamente** i seguenti presupposti: a) la banca è in dissesto o a rischio di dissesto secondo quanto previsto dal comma 2; b) non si possono ragionevolmente prospettare misure

alternative che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che può includere misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario.

Comma 2: La banca è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una **o più** delle seguenti situazioni: a) risultano irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano l'attività della banca di gravità tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività; b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio; c) le sue attività sono inferiori alle passività.

Nota: nel comma 1 si stabilisce che una banca è sottoposta ad una delle misure indicate all'articolo 20 solo quando ricorrono **CONGIUNTAMENTE** i presupposti previsti. Nel comma 2 invece si stabilisce che una banca è considerata in dissesto (o a rischio di dissesto) in una **O più** delle situazioni previste (in questo caso non devono sussistere congiuntamente).

12.4.2. Art. 18 (Sostegno finanziario pubblico straordinario)

Comma 1: Ai fini dell'articolo 17, comma 2, lettera f), una banca non è considerata in dissesto o a rischio di dissesto nei casi in cui, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario viene concesso: a) in una delle seguenti forme: i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate; ii) una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; iii) la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca.

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

12.4.3. Art. 19 (Accertamento dei presupposti)

Comma 1: L'organo di amministrazione o di controllo di una banca informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorità competenti, se ritiene che la banca è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a). Se l'autorità competente è la Banca Centrale Europea, essa ne dà senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.

Comma 2: La sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a), è accertata dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, quali autorità competenti. Quando la Banca Centrale Europea è l'autorità competente, è sentita la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione.

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

(pagina 2-3)

12.5. Art. 20-21 — Individuazione della procedura di crisi e obiettivi della risoluzione

12.5.1. Art. 20 (Individuazione della procedura di crisi)

Comma 1: Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 17, è disposta alternativamente nei confronti di una banca: a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla banca, secondo quanto previsto dal Capo II, quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); b) la risoluzione della banca secondo quanto previsto dal Capo III o la liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico Bancario se la misura indicata alla lettera a) non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto.

Comma 2: La risoluzione è disposta quando la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dell'**interesse pubblico**, che ricorre quando la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all'articolo 21 e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.

Nota: unico elemento degno di nota è al comma 2 la sussistenza di un interesse pubblico. Interessante notare come per le banche di modeste dimensioni (come le BCC o le piccole SPA) non possa mai sussistere un interesse pubblico, quindi queste sono costrette ad alimentare il fondo di garanzia dei depositi ma non possono beneficiare dei servizi relativi alla risoluzione.

12.5.2. Art. 21 (Obiettivi della risoluzione)

Comma 1: La Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto avendo riguardo: - alla continuità delle funzioni essenziali dei soggetti di cui all'articolo 2, - alla stabilità finanziaria, - al contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, - alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, - nonché dei fondi e delle altre attività della clientela.

Nota: questo articolo può essere considerato l'equivalente dell'art. 5 TUB (finalità) ma riferito alle crisi.

(pagina 3)

12.6. Art. 22 — Principi della risoluzione

Comma 1: La risoluzione si conforma ai seguenti principi: a) le perdite sono subite dagli azionisti e dai creditori, nell'ordine e nei modi stabiliti dal presente decreto; b) salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, gli azionisti e i creditori aventi la stessa posizione nell'ordine di priorità applicabile in sede concorsuale ricevono pari trattamento e subiscono le perdite secondo l'ordine medesimo; c) nessun azionista e creditore subisce perdite maggiori di quelle che subirebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile; d) i depositi protetti non subiscono perdite.

Nota: la lettera b) si riferisce al principio del “**par condicio creditorum**”, per quanto riguarda la lettera c) invece questa riprende il principio per cui “**No Creditor Worse Off**” (nessun creditore trattato peggio di quanto sarebbe stato in caso di liquidazione). *(pagina 4)*

12.7. Art. 23, 25, 26 — Valutazione e tutela giurisdizionale relativa alla valutazione

12.7.1. Art. 23 (Valutazione)

Comma 1: L’avvio della risoluzione o la riduzione e conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale ai sensi del Capo II nei confronti di un soggetto di cui all’articolo 2 è preceduto da una **valutazione equa, prudente e realistica** delle sue attività e passività.

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

12.7.2. Art. 25 (Valutazione provvisoria)

Comma 1: Quando sussistono motivi di urgenza che non permettono di procedere ai sensi dell’articolo 24, l’avvio di un’azione di risoluzione e la riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale possono essere disposti sulla base di una **valutazione provvisoria**.

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

12.7.3. Art. 26 (Tutela giurisdizionale e indennità spettanti ai soggetti incaricati della valutazione)

Comma 1: La decisione di applicare una misura di risoluzione o esercitare un potere di risoluzione o esercitare il potere di ridurre o convertire le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale si basa sulla valutazione di cui all’art. 23 o all’art. 25. La valutazione è parte integrante della decisione.

Comma 2: Non è ammessa tutela giurisdizionale contro la valutazione, finché non è stata adottata la decisione di cui al comma 1. Davanti al giudice amministrativo non è ammessa tutela autonoma contro la valutazione, ma essa può essere oggetto di contestazione solo nell’ambito dell’impugnazione della decisione, ai sensi dell’art. 95.

Nota: quanto definito in questo articolo è peculiare. Nel comma 1 si specifica che la decisione di BI relativa all’applicazione di una misura di risoluzione si basa su una valutazione. Nel comma 2 invece si prevede che non è ammessa tutela giurisprudenziale contro la valutazione; la valutazione può solo essere oggetto di contestazione nell’ambito dell’impugnazione della decisione (rimando ad art. 95 comma 2). *(pagina 4)*

12.8. Art. 28 — Strumenti soggetti a riduzione o conversione

Comma 1: La riduzione o la conversione è disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da una banca avente sede legale in Italia computabili nei fondi propri su base individuale, quando si realizzano per la banca i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a).

Comma 2: Quando i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o la conversione è disposta con riferimento a: a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata; b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato all'articolo 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata; se del gruppo fa parte una società avente sede legale in un altro Stato membro, la misura è disposta in conformità dell'articolo 30.

Comma 3: La riduzione o la conversione è disposta nell'ordine indicato dall'articolo 52, comma 1, lettera a).

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

(pagina 4–5)

12.9. Art. 32, 34, 35, 38 — Avvio, attuazione, effetti e chiusura della risoluzione

12.9.1. Art. 32 (Avvio della risoluzione)

Comma 1: Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la Banca d'Italia, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone l'avvio della risoluzione con un provvedimento che contiene: (...)

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

12.9.2. Art. 34 (Attuazione del programma di risoluzione)

Comma 1: La Banca d'Italia dà esecuzione al programma di risoluzione, come definito con il provvedimento di cui all'articolo 32, comma 1, attuando le misure ivi indicate ed esercitando i poteri previsti dal Capo V.

Comma 2: Il programma è attuato dalla Banca d'Italia in una o più delle seguenti modalità: a) con atti di uno o più commissari speciali dalla stessa nominati, che esercitano i poteri disciplinati dall'articolo 37 e dal Capo V; b) con atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni.

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

12.9.3. Art. 35 (Effetti della risoluzione)

Comma 1: Quando il programma di risoluzione viene attuato con le modalità previste dall'articolo 34, comma 2, lettere a) o b), dall'insediamento dei commissari speciali o dal primo atto compiuto dalla Banca d'Italia in luogo dei competenti organi sociali si producono i seguenti effetti: a) sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sull'ente sottoposto a risoluzione; b) decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione, salvo che diversamente disposto dal provvedimento di avvio della risoluzione.

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

12.9.4. Art. 38 (Chiusura della risoluzione)

Comma 1: La Banca d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere più utilmente perseguiti, informata la Banca Centrale Europea quando essa è l'autorità competente, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo dell'ente sottoposto a risoluzione, di redigere separati rapporti sull'attività svolta nell'ambito della risoluzione. I rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia.

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

(pagina 5-6)

12.10. Art. 39-40 — Misure di risoluzione e cessione a soggetto terzo

12.10.1. Art. 39 (Misure di risoluzione)

Comma 1: Sono misure di risoluzione: a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo; b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte; c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività; d) il bail-in.

Nota: le misure di risoluzione indicate in questo articolo non sono esclusive; possono essere adottate anche contemporaneamente (e nella maggior parte dei casi succede).

12.10.2. Art. 40 (Cessione)

Comma 1: La cessione, in una o più soluzioni, a un soggetto terzo, diverso da un ente-ponte o da una società veicolo per la gestione delle attività, ha ad oggetto: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o parte di esse; b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di un ente sottoposto a risoluzione, o parte di essi.

Nota: questa misura altro non è che l'equivalente dell'art. 58 TUB (cessione dei rapporti giuridici) ma applicato alle crisi. La cessione deve avvenire verso un soggetto terzo diverso da un ente-ponte o una società veicolo.

(pagina 6)

12.11. Art. 42 e 45 — Ente-ponte e società veicolo per la gestione delle attività

12.11.1. Art. 42 (Costituzione e funzionamento dell'ente-ponte)

Comma 1: L'ente-ponte è costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'articolo 43, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate. Sono fatte salve le eventuali limitazioni stabilite ai sensi della disciplina a tutela della concorrenza.

Comma 2: Il capitale dell'ente-ponte è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche.

Nota: l'ente-ponte è una delle modalità di risoluzione delle crisi più adottate. Viene istituito un soggetto giuridico che vada a svolgere, in via temporanea, le funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e nel mentre si applicano le altre misure (come ad esempio la cessione dei rapporti giuridici). L'ente-ponte è necessario perché in alcuni casi la banca in dissesto non sarebbe capace neanche di svolgere le funzioni essenziali.

12.11.2. Art. 45 (Costituzione e funzionamento della società veicolo per la gestione delle attività)

Comma 1: La società veicolo per la gestione delle attività è costituita per amministrare i beni e i rapporti giuridici a essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore attraverso una successiva cessione o la liquidazione della società veicolo medesima. Il capitale della società è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche.

Nota: la società veicolo (o **bad bank**), costituita in forma di SPA e solo previa approvazione dell'atto costitutivo da parte di BI, amministra i beni e rapporti giuridici ad essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore. *(pagina 6-7)*

12.12. Art. 48-49 — Finalità del bail-in e passività escluse

12.12.1. Art. 48 (Finalità del bail-in)

Comma 1: Il bail-in è disposto: a) per ripristinare il patrimonio di un soggetto di cui all'articolo 2 sottoposto a risoluzione nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la fiducia del mercato, se l'applicazione del bail-in, anche unitamente alle misure di riorganizzazione aziendale, è sufficiente a prospettare il risanamento; oppure b) in caso di cessione ai sensi della Sezione II, per ridurre il valore nominale delle passività cedute, inclusi i titoli di debito, o per convertire queste passività in capitale.

Nota: il bail-in è l'alternativa al bail-out. In questo articolo si definiscono le finalità del bail-in.

12.12.2. Art. 49 (Passività escluse dal bail-in)

Comma 1: Sono soggette al bail-in tutte le passività, ad eccezione delle seguenti: a) i depositi protetti; b) le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione; c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili; d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili; e) passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione; f) passività con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale, nonché dei suoi gestori o partecipanti, purché le passività derivino dalla partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione ai sistemi; g) passività nei confronti dei seguenti soggetti: (...)

Nota: in questo comma si specifica che tutte le passività sono soggette al bail-in ad eccezione di quelle individuate dall'articolo stesso (definite in ordine di “delicatezza”). In caso di bail-in i depositanti sono i primi soggetti ad essere colpiti ma questo concetto non si applica nel caso di: depositi protetti (quindi depositi per un valore non superiore ai 100.000 euro per depositante), passività garantite (anche in questo caso per valori non superiori ai 100.000 euro), somme di denaro detenute dall'intermediario di proprietà del depositante (ad esempio nel caso di un servizio di investimento i soldi/titoli sono di proprietà del cliente quindi non possono essere sottoposti a bail-in), le passività verso altri intermediari di durata inferiore ai sette giorni, etc.

Nel caso dei depositi protetti bisogna specificare che il fondo a tutela dei depositanti interviene a garanzia del **singolo depositante**; questo significa che un deposito è protetto fino a 100.000 euro ma laddove il singolo cliente abbia due conti dal valore di 100.000 euro ciascuno comunque verrebbe rimborsato per un valore non superiore ai 100.000. Nel caso di un fondo cointestato da due persone dal valore di 200.000 euro questo verrebbe interamente rimborsato perché entrambi i depositanti hanno diritto a 100.000 euro.

(pagina 7-8)

12.13. Art. 50-52 — Requisito minimo, importo del bail-in e trattamento di azionisti e creditori

12.13.1. Art. 50 (Requisito minimo di passività soggette a bail-in)

Comma 1: Per assicurare l'applicabilità del bail-in le banche rispettano, su base individuale e consolidata, un requisito minimo di passività soggette al bail-in.

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

12.13.2. Art. 51 (Importo del bail-in)

Comma 1: L'importo del bail-in è determinato in base alla valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e tiene conto: a) della necessità di ristabilire nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell'ente sottoposto a risoluzione o nell'ente-ponte e di permettere a tali enti di rispettare per almeno un anno i requisiti prudenziali; b) di una stima prudente del fabbisogno di capitale della società veicolo per la gestione delle attività, se il programma di risoluzione prevede la cessione a essa ai sensi dell'articolo 46; c) del contributo del fondo di risoluzione erogato ai sensi dell'articolo 49, comma 5, lettera b).

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

12.13.3. Art. 52 (Trattamento degli azionisti e dei creditori)

Comma 1: (...)

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

(pagina 8)

12.14. Art. 95 — Tutela giurisdizionale contro le misure di gestione della crisi

Comma 2: Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti della Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle finanze sarebbe contraria all'interesse pubblico; nei medesimi giudizi non si applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del Codice del processo amministrativo.

Nota: invece di esserci un processo vero e proprio, al massimo può esserci la sospensione.

(pagina 8)